



la crítica

del derecho

"Hice parte de este paisaje usando una foto de las pertenencias que se encontraron en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Izaguirre era usado por el CJNG como centro de entrenamiento, tortura, exterminio, crematorio. El gobierno negó que lo fuera, luego abrió una investigación que quedó abandonada. En nuestro paisaje está presente una guerra de la que ningún gobierno se ha hecho cargo".
Catalina Pérez Correa, febrero de 2026.

año 2, Vol. 2 – febrero de 2026

Contenido

ESPECIAL LEY PENAL JUVENIL

El eterno debate por la baja en la edad de punibilidad	4
<i>Fernando Gauna Alsina</i>	
Una vez más: ¿Debe bajarse la edad de imputabilidad? Siete brevísimas críticas	7
<i>Roberto Gargarella</i>	
El problema de la impunidad juvenil: una defensa incómoda de la justicia retributiva	10
<i>Tomás Fernández Fiks</i>	
Punitivismo ineficiente	14
<i>Valeria Vegh Weis</i>	
Un régimen penal juvenil para la opinión pública	17
<i>Sebastián Guidi</i>	
Infancias heridas	23
<i>Máximo Lanusse Noguera</i>	
La "Magia Veneno" de la República	27
<i>Mariela Puga</i>	
La penalización de la biografía	32
<i>Adriana Soria</i>	

DEBATES

Historia Mínima del rock en América Latina	34
<i>Abel Gilbert · Pablo Alabarces</i>	
La degradación constitucional de Estados Unidos	37
<i>Irwin Stotzky</i>	
Presentación y crítica de las "Major Questions Doctrine"	39
<i>Roberto Gargarella</i>	
El Fondo de Asistencia Laboral	43
<i>Mario Ackerman</i>	

ENSAYOS

Nada, nada más que tristeza... ¿y quietud?	49
<i>María Valeria Berros</i>	
Advertencias de John Ford y Clint Eastwood para el nuevo mundo	54
<i>Antonia Fratini Lagos</i>	
Leer a C. Wright Mills en la era de Trump	58
<i>Clyde W. Barrow</i>	
El rol de los grupos de interés en la conversación pública	66
<i>Emiliano Vitaliani</i>	
Una Noche en el Honorable Senado Argentino	70
<i>Gustavo Maurino</i>	
¿Elegir al menos malo?	74
<i>Natalia Sobrevilla Perea</i>	
La crisis estructural del diseño político del Perú	78
<i>Heber Joel Campos Bernal</i>	
John Marshall y la trastienda de "Marbury v. Madison"	80
<i>Gustavo Arballo</i>	
Castigar más, comprender menos	88
<i>Luciana Ginga · Marco Gaiero</i>	
Eliminar al líder	94
<i>Catalina Pérez Correa</i>	

RESEÑAS

Puntos de vista	96
<i>Ramiro Álvarez Ugarte</i>	

El eterno debate por la baja en la edad de punibilidad

por Fernando Gauna Alsina

Una iniciativa ilegal que se enfrenta con la realidad del sistema penal

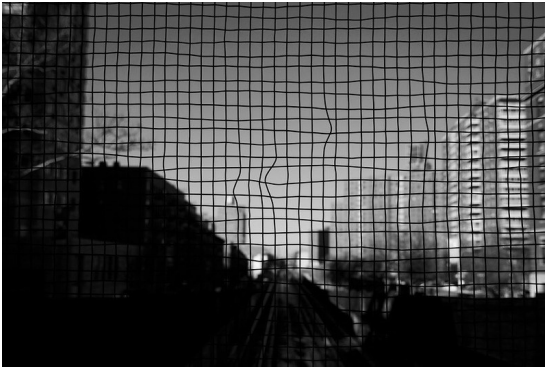
6 de febrero de 2026

Por desgracia, de vez en cuando nos enteramos de algún hecho violento, un crimen, protagonizado por jóvenes, a veces no punibles. En ocasiones, tal vez por su gravedad, crueldad u otra característica, alguno de estos crímenes se instala en la agenda pública. Ni lerdos ni perezosos, para lo que les conviene, los funcionarios de turno echan culpas sobre gestiones de gobierno pasadas y vuelven sobre proyectos de ley que buscan bajar la edad de punibilidad. A los quince, a los catorce o incluso a los doce. Estos niños —porque en la Argentina quienes no alcancen los 18 años son niños—, que en el común de los casos están atravesados por un contexto de profunda vulneración de derechos, ahora sí reciben la atención de las autoridades. Y pretenden darles atención enseñándoles su costado más crudo: *delito de adulto, pena de adulto*.

Este eslogan, con pretensiones de convertirse en norma, se enfrenta con un insalvable obstáculo legal. Los niños no pueden recibir, ni merecen, la misma respuesta penal que una persona adulta, aun cuando hayan cometido un delito similar. La sanción tiene que ser diferenciada y proporcionalmente más leve (Art. 37 Convención sobre los derechos del niño, entre otros). La ley recoge prácticamente una obviedad: su madurez, desarrollo y hasta la comprensión del injusto son *menores* que los de un adulto. No de casualidad recién a los 16 años están habilitados a tomar

con plena capacidad decisiones vinculadas con su propio cuerpo, como consentir tratamientos invasivos o interrumpir un embarazo, y ejercer el derecho a votar (Art. 25 CCyC), entre otros asuntos cuyo reconocimiento legal, dicho sea de paso, generaron intensos debates.

Sería bastante curioso, entonces, por no decir una contradicción legal, que se considere a los menores de 16 con capacidades cognitivas, intelectuales y morales suficientes para responsabilizarse por su intervención en un hecho delictivo, sobrellevar un proceso penal, seguramente encerrados preventivamente, y pagar sus culpas en prisión. A esto se suma que la baja de la edad de punibilidad implica un retroceso en materia de derechos. En definitiva, implica que podrán ser alcanzados por el sistema penal cuando antes estaban excluidos, cosa que constituye una vulneración flagrante del principio de no regresividad penal (Arts. 26 Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).



Así las cosas, existen buenas razones para sostener que la modificación legal de la edad de punibilidad se contrapone con normas de raigambre convencional y constitucional. Por lo que, más allá del problema que eso de por sí solo implica, no sería descabellado concluir que los jueces estarían obligados a declarar su inconstitucionalidad. Sobre todo, si se tiene en cuenta la cantidad de agrupaciones de jueces que se han pronunciado en contra.¹

Por otra parte, no se puede perder de vista una cuestión siempre soslayada, no solo por integrantes del mundo de la política o de los medios de comunicación, sino también por profesores de derecho y abogados penalistas, a la hora de promover o avalar modificaciones de la legislación penal. El sistema penal argentino no está en condiciones de ampliar su ámbito de acción. Dicho de otro modo, no tiene capacidad para hacerse cargo de nuevos *clientes*. Los informes de los organismos especializados dan cuenta que las prisiones argentinas, o como se las quiera llamar para matizar lo que ocurre allí dentro, ya sea para mayores o menores, no tienen lugar para recibir más personas.²

Los espacios de privación de libertad en nuestro país tienen personas alojadas por encima de su capacidad, tanto declarada como real, lo que se traduce en hacinamiento y en condiciones insalubres de detención. Y esto no es una cuestión

coyuntural, sino de larga data y que se viene profundizando hace tiempo. En este sentido, una derivación de ese problema es la cantidad de personas detenidas en comisarias o alcaidías policiales a lo largo del país, cosa que no solo implica que se tergiverse el destino de esos espacios, con precarias condiciones de encarcelamiento a cuestas.³ También supone que funcionarios policiales actúen como penitenciarios —algo para lo que no están capacitados—, en vez de estar en la calle evitando la comisión de delitos. Incluidos, los que intenten cometer jóvenes no punibles.

De manera que la baja de la edad de punibilidad se enfrenta con obstáculos legales, como así también con la realidad del sistema penal argentino. Y creo que debo reiterarlo: no se trata de una situación pasajera, sino de una característica que, a esta altura, se la puede calificar de estructural. Por lo que ampliar, aun mínimamente, el campo de actuación del sistema penal reduciría el contexto de vulneración de derechos de quienes ya están detenidos, y afectaría a un sector de la población —los niños— que merecen protección especial por disposición legal (CDN, Ley 26.061, entre otras).

Por último, quiero detenerme en otro aspecto de la realidad que, además de haber sido descuidado, en el último tiempo ha sido cuestionado por algunos sectores del penalismo argentino, mayormente preocupados por el *derecho en los libros*, por el deber ser.

A diferencia de los números que presenta con bastante ligereza el gobierno o que circula con fuerza en el imaginario popular, las estadísticas enseñan que la intervención de niños no punibles en la comisión de hechos delictivos y, en especial, de homicidios —supuestos en los que se reducen significativamente las cifras negras— es baja. Y lo relevante es que se trata de un es-

¹Se puede ver al respecto, entre muchos otros, el comunicado de la Red de Jueces Penales Bonaerense en contra de la baja de la edad de punibilidad de fecha 15 de agosto de 2024.

²En el sitio web oficial del Comité para la Prevención de la Tortura se puede acceder al último informe (2024) sobre la situación de las personas privadas de libertad en Argentina, entre otros.

³Al respecto, se puede consultar el Monitor Federal de presos en Comisarias elaborado por INECIP.

cenario que se mantiene medianamente estable desde hace años.⁴

Con esto, no es mi idea quitarle relevancia a episodios violentos que, justamente, fueron protagonizados por menores de edad. Para quien lo sufre en carne propia y su familia, seguramente el hecho sea en la mayor parte de los casos irreparable. Sin embargo, como lo puntualizamos alguna vez y con más profundidad con Mariano Gutiérrez,⁵ si lo que se están discutiendo son soluciones en términos de políticas públicas en general y de control del delito en particular, se debe aceptar que los jóvenes no punibles no constituyen un fenómeno preponderante o central en materia de criminalidad.

Por lo demás, vuelvo a insistir, lo que está en juego es ampliar el ámbito de acción de un área del Estado, el sistema penal, que exhibe muestras a diario de que no cumple los propósitos ni las funciones que le asigna la ley. No reintegra, no resocializa, no ofrece herramientas para volver con mayor autonomía al medio libre. Y para quienes están interesados por el costado retributivo del castigo, tampoco constituye un espacio adecuado para materializar un reproche social legítimo. Eso, claro está, salvo que seamos indiferentes frente a las vulneraciones de derechos y las condiciones indignas de detención que caracteriza a cualquiera de nuestros lugares de encierro.



Esto no es un asunto ajeno al mundo del derecho. O por lo menos no debería serlo. Las penas de prisión no pueden llevarse adelante a como dé lugar. Son innumerables las leyes que establecen cómo deben ser los espacios de privación de libertad, qué derechos tienen que garantizarse durante el tiempo de encierro y cuáles son sus propósitos. De manera que la realidad del sistema carcelario, *el derecho penal en los hechos*, en cuyo marco es una constante la vulneración de la legalidad, no puede obviarse a la hora de sentar posición en este debate.



Y aquí no estoy proponiendo que no se envíe gente a prisión. Solo estoy diciendo que si no podemos respetar estándares legales mínimos de detención mal podríamos avalar ampliar la capacidad del sistema penal. Sobre todo, si está en juego un sector que merece protección especial, como son los niños. ■

«Por desgracia, de vez en cuando nos enteramos de algún hecho violento, un crimen, protagonizado por jóvenes, a veces no punibles.»

⁴Al respecto, se pueden comparar los informes y datos relevados en el trabajo citado en la nota 5, que data de 2014, con las cifras oficiales que enseñan los organismos públicos citados en la actualidad.

⁵Ver “El eterno retorno de las falsas ilusiones” en “Por una agenda progresista para el sistema penal: una propuesta de la Asociación Pensamiento Penal, Siglo Veintiuno Editores, 2014, accesible online en el sitio web de APP.

Una vez más: ¿Debe bajarse la edad de imputabilidad? Siete brevísimas críticas

por Roberto Gargarella

En el marco de un debate a las apuradas, algunos problemas de una propuesta que siempre vuelve.

12 de febrero de 2026

Señalo, a continuación, y de manera muy sucinta, 5 primeros problemas que advierto en las propuestas oficiales destinadas (¡una vez más!) a bajar la edad de imputabilidad.

¿Debe asimilarse el régimen de los menores al de los adultos? Los problemas de la “asimilación” (“crímenes de adultos, penas de adultos”). La proposición que sugiere que si un menor comete un crimen “de adulto” debe ser así penado, es muy controvertida. Ello así, por varias razones, que sumariamente enumero: i) La propuesta de “asimilación” es imprecisa y confusa, desde su mera formulación (los crímenes no se definen por la edad de quienes los cometen); ii) se trata de una invitación fundamentalmente mal orientada, porque el punto de partida, en esta área, requiere de una reflexión sobre la responsabilidad legal (o no) del ofensor, y no una sobre el particular castigo que podría corresponderle al mismo -cuestión, esta última, que supone lo que aquí es principal objeto de debate (si el menor es legalmente responsable, o no); iii) en términos normativos, se trata de una propuesta inconsistente, teniendo en cuenta que, en todas las demás áreas del derecho, reconocemos y admitimos diferencias relevantes en las capacidades, madurez, y finalmente el tratamiento que damos a adultos y menores (ie., en la firma de contratos de trabajo, las compraventas, el matrimonio, etc.). La propuesta de la “asimilación”, además, iv) se encuentra en tensión con el derecho constitucional y convencional. Para comenzar, la Convención de los Derechos del Niño, incorporada en la Constitución, explícitamente exige (en su art. 37) un tratamiento diferente de menores y adul-

tos, en cuanto a la severidad de las respuestas coactivas que pueden recibir los menores por parte del Estado. Debería ser difícil, entonces, para los jueces, considerar legalmente válidas las iniciativas de “asimilación”, en el marco de este contexto legal.

El menor como sujeto de derechos, y no como objeto de tutela. Dados los compromisos internacionales asumidos por el país, los menores ya no pueden considerarse -como alguna vez lo fueron- objetos de tutela por parte del Estado o el juez: se trata de personas con derechos propios, que incluyen el de opinar y ser escuchados, el derecho de defensa, el del debido proceso, etc. Ellos no pueden ser tomados como incapaces que el Estado debe corregir, para decidir por ellos y “por su bien”. Esta cuestión, más bien cerrada ya, en términos doctrinarios, milita fuertemente en contra de la idea de la “asimilación”.

¿Deben aplicarse -entonces- regímenes diferentes para menores y adultos? Los problemas de la “diferenciación” (*Régimen Penal Especial para menores*). La confusión y los errores que son propios de la propuesta de “asimilación” tienden a extenderse también, sobre quienes, desde posiciones más liberales, favorecen un tratamiento “diferenciado” entre adultos y menores. Ello así, al menos, en la medida en que la existencia de un Régimen Especial para menores implique -como ocurre en nuestro país- centros de detención orientados a reproducir, en los hechos, formas de violencia y maltrato paralelos a los que distinguen a los centros de detención para adultos. Es decir, la “diferenciación” de tratamiento entre adultos y menores también queda vacía de sentido si es

que el trato que va a darse a los menores, en sus diferentes estadios, va a incorporar modalidades igualmente injustificadas del castigo, como las que se reservan para los adultos.

Sobre la (no) justificación de nuestra práctica del castigo. En relación con el castigo penal, debe notarse que las formas habituales del mismo enfrentan problemas teóricos serios: objeciones morales y constitucionales. Por un lado, i) no todas las faltas reconocidas en una comunidad merecen ser reprochadas; ii) no todos los reproches implican ni deben implicar el establecimiento de castigos (entendido como “imposición deliberada de dolor”); y iii) no todos los castigos deben requerir la privación de la libertad. Y, sin embargo, la línea que va desde la “falta comunitariamente reconocida” a la “prisión” suele aparecer sugiriendo una continuidad obvia. De ese modo, iv) la propia idea del derecho penal como *ultima ratio* queda subvertida, de una manera injustificada. Mucho peor que lo dicho, v) el tipo de privación de libertad que resulta más común, en nuestro país, se encuentra en directa tensión con la letra explícita de la Constitución. Ello así porque la Constitución Argentina se exploya larga y claramente sobre la cuestión del reproche penal (típicamente, en el art. 18): establece cárceles “sanas y limpias”, prohíbe los “tormentos” y “mortificaciones”, y toma como objetivo principal la “seguridad” y “no el castigo de los reos” detenidos en cárceles. Dado todo lo anterior, no parece una buena idea el asimilar al castigo de adultos el reproche que puede corresponderle a los menores. Ello implicaría imponer, sobre los menores, una práctica, más que controvertida, ilegal e injusta.

La alternativa de la justicia restaurativa está al alcance. El tipo de castigo prevaleciente en nuestro país resulta, por lo dicho hasta aquí, injustificado, pero esa falta de justificación resulta mucho más notoria cuando existen alternativas disponibles, eficientes, exitosas, y completamente respetuosas de los valores constitucionales. En este sentido, debe subrayarse que contamos, en la Argentina, con excelentes ex-

periencias de justicia restaurativa (aplicadas en áreas del Gran Buenos Aires, Córdoba, por ejemplo), que procuran la re-integración de los menores, en ámbitos sociales, culturales, deportivos y familiares, diferentes de aquellos en los cuales se socializaron, al margen del derecho. Tales experiencias parecen resultar, a todas luces, valiosas (ver, en particular, las prácticas y estudios analizados por Raúl Calvo Soler, en la Argentina, ie., <https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5481>).

Los menores como meros medios. Los modos en que este gobierno -y los últimos gobiernos, en general- se acercan a la cuestión de la inseguridad y el derecho penal para menores resultan inadmisibles. Aunque, en los hechos, la participación de menores en delitos graves parece, proporcionalmente, muy baja (como bien remarca Fernando Gauna Alsina, en su nota para *lacritica*.ar: <https://lacritica.ar/post/sobre-el-eterno-debate/>), el uso del derecho penal *contra* menores parece resultar muy atractivo para quienes ocupan posiciones de poder: una manera de llamar la atención (apelando al espectáculo); ganar la atención de los medios de comunicación; y, finalmente, mejorar en sus índices de popularidad ante, al menos, una parte de la opinión pública. Esta utilización de los menores como “meros medios”, se acompaña, por lo demás, con un empleo semejante de los menores (otra vez, como “meros medios”), por parte de bandas criminales, que apelan a ellos como escudo, o como “correo”, amparados en las torpezas con las que se mueve el derecho en el área. Sin embargo, la ineficiencia o las ambigüedades de nuestro derecho en este ámbito, no debería convertirse en excusa para cargar responsabilidad (penal) sobre los menores, sino razón para reprochar adicionalmente a los mayores que quieran utilizar a los más jóvenes o niños como “meros medios.”

Derecho penal en lugar de políticas sociales. Aunque resulte un truísmo decirlo, debe insistirse con la idea -siempre correcta- de que los problemas sociales no merecen ser resueltos con las herramientas torpes y violentas del derecho penal.

Por el contrario, debe resultar claro que los problemas sociales requieren de atención, cuidados y políticas sociales. Señalar esto es compatible con asumir, en ciertos casos, la responsabilidad de los menores en relación con sus actos, y la reprochabilidad misma de tales acciones. Pero, otra vez, la responsabilidad no llama a la intervención coercitiva del estado, como la reprochabilidad de algunas de sus conductas no exige una respuesta punitiva, en la forma tradicional del castigo.



En todo caso, valgan estos argumentos para quienes quieran participar de un debate en el área. De parte del oficialismo (del actual, como de los anteriores) no parece que pueda esperarse lo propio, ya que, como resulta común, la opción es por las respuestas cómodas, irracionales, improvisadas, efectistas e irresponsables, que toman a los menores como “meros medios”. ■



«Señalo, a continuación, y de manera muy sucinta, 5 primeros problemas que advierto en las propuestas oficiales destinadas (¡una vez más!) a bajar la edad de imputabilidad.»

El problema de la impunidad juvenil: una defensa incómoda de la justicia retributiva

por Tomás Fernández Fiks

Cuando quienes comprenden la gravedad de sus actos no pueden ser castigados, algo parece fallar en nuestra idea de justicia.

13 de febrero de 2026

La discusión en torno a la determinación de la edad de punibilidad provee un terreno fértil para las disputas ideológicas. En efecto, suele funcionar como una especie de campo de batalla entre posiciones que podrían caracterizarse, de manera simplificada, como conservadoras y progresistas: las primeras, inclinadas a promover la reducción del umbral etario; las segundas, empeñadas en resistir esa modificación. Este trasfondo dificulta el análisis crítico de los argumentos de una y otra postura y genera que el debate público se desplace desde el *contexto de justificación* hacia el *contexto de descubrimiento*: en lugar de evaluarse si las razones invocadas son moral o jurídicamente aceptables, se indaga cuáles son las motivaciones, intereses o inclinaciones ideológicas de quienes las formulan.

Lo que es peor: la adopción de una determinada posición respecto del problema de fondo suele conducir a la inmediata adscripción del interlocutor a uno de los bandos en disputa, con independencia de los matices o fundamentos que ofrezca. Se promueve así una práctica deliberativa que podría calificarse como *anti-rawlsiana*: en vez de reconstruir el argumento del oponente en su versión más fuerte para someterlo a crítica, se lo caricaturiza y se discute contra su formulación más débil. Así, por ejemplo, con frecuencia los defensores de la reducción de la edad de punibilidad acusan a sus críticos de “defender a los delincuentes en lugar de las víctimas”; a su turno, quienes se oponen a la reforma a menudo caracterizan a sus adversarios como sujetos intrínsecamente malvados, partidarios de “encar-

celar pibes que deberían estar en la escuela o jugando en plaza”. Este tipo de apelación a frases emotivas empobrece, mucho más de lo que enriquece, el debate democrático sobre un tema tan importante.

Más allá de estas malas prácticas dialógicas, lo cierto es que los argumentos esgrimidos por ambos sectores suelen ser bastante pobres. Quienes propician la reducción del umbral etario suelen presentar la medida como una *solución* al problema de la inseguridad, acompañando la propuesta con consignas tales como “ley y orden”, “el que las hace, las paga” o incluso el sinsentido “delito de adulto, pena de adulto”. Frente a ello, la réplica habitual consiste en afirmar que el derecho penal es ineficaz como instrumento preventivo, dado que siempre “llega tarde” y que, por ende, la solución al fenómeno delictivo debe buscarse en políticas sociales de otra índole.

Detrás de esta forma de plantear la discusión subyace una concepción del castigo penal estrictamente instrumentalista: este es concebido como una herramienta para la prevención y reducción del delito cuya legitimidad depende, en última instancia, de su efectividad para cumplir con ese objetivo. En ese marco, sorprende la escasa presencia, en ambos lados del debate, de consideraciones vinculadas con la justicia retributiva. Contra esta tendencia, me propongo desarrollar dos argumentos en favor de la reducción de la edad de punibilidad —al menos para ciertos supuestos y dentro de determinados límites— basados en la idea de merecimiento y en una concepción retributiva del castigo.

Para visualizar las implicaciones del argumento, considérese el siguiente caso: Juan y Pedro (de quince años cada uno), en connivencia con María (de dieciséis años), realizan una emboscada a Raúl (también de dieciséis), quien pensaba que se iba a reunir a solas con María en un galpón. Juan y Pedro sorprenden a Raúl, lo desnudan, amordazan y apuñalan reiteradas veces, causándole la muerte. Todo queda registrado por los mismos autores del homicidio, quienes se filman jocosamente mientras torturan y asesinan a la víctima. El ejemplo es una reconstrucción libre del caso real que, en gran medida, impulsó la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad. Dado que se trata de un hecho que todavía está siendo investigado, no pretendo aseverar que haya sucedido de esta forma. En cualquier caso, el argumento que sigue no depende de la exactitud de mi reconstrucción. Léase entonces, simplemente, como un ejemplo hipotético que sirve para ilustrar ciertas intuiciones básicas.

Dado que la ley argentina establece la edad de punibilidad a partir de los dieciséis años ¹, Juan y Pedro resultarían impunes. Sin embargo, si se asume que comprendían la criminalidad de sus hechos y podían dirigir sus acciones ², existen buenas razones para considerar que *deberían* ser castigados. Si ello es así, la imposibilidad jurídica de imponerles una pena constituiría un importante déficit de justicia que merece ser examinado. Veamos entonces cuáles son esas razones.

En primer lugar, Juan y Pedro deberían ser castigados porque ello constituye una muestra de respeto hacia las víctimas del crimen que cometieron (entre las que se encuentra Raúl, principalmente, pero también los familiares y seres

queridos de este). Al castigar adecuadamente a los asesinos, la comunidad política, actuando a través del Estado, se *disocia* normativamente de los actos de aquellos y se solidariza con las víctimas; les comunica a los criminales que lo que hicieron es inadmisible, que la norma de comportamiento que violaron se mantiene plenamente vigente y que el mensaje de superioridad respecto de las víctimas que expresaron a través de su acto ilícito es *falso* ³.

Ahora bien, frente a mi argumento podría cuestionarse: ¿por qué la disociación con el delito tiene que venir de la mano de la aplicación de una *pena* a sus responsables? ¿Por qué no emitir un pronunciamiento público condenando los hechos sin tener que castigar a nadie? ¿Por qué no sería posible *reprochar sin castigar*? La razón es que el castigo es el dispositivo convencional que, como sociedad, utilizamos para expresar un reproche a quienes realizan los actos más graves (Feinberg); si lo hiciéramos de otro modo, el reproche en cuestión no podría ser transmitido con el mismo grado de seriedad y contundencia. Es la forma que tenemos para hacerle entender al delincuente la gravedad de sus actos y para persuadirlo de que se arrepienta y se someta a una especie de “penitencia secular” (Duff). No se trata meramente de hacerlo sufrir, sino de emitir un pronunciamiento autoritativo que permita nivelar a la víctima y el victimario, removiendo la vergüenza en la que quedan sumergidas las víctimas como consecuencia del acto al que fueron sometidas (Malamud Goti).

Una segunda objeción contra mi planteo podría consistir en señalar que no deberíamos diseñar ni implementar políticas públicas en función de los deseos o emociones de las víctimas. Se suele afirmar, en este sentido, que hay que

¹art. 1º, Ley N° 22.278.

²art. 34 inc. 1º del Código Penal.

³Quien desee profundizar en esta línea puede encontrar la génesis del argumento esbozado en la variante del retribucionismo que pone el énfasis en el efecto simbólico del castigo, formulada originariamente por Hegel —y defendida hoy en día por Pawlik—, como también en la reinterpretación de esta teoría que, desplazando el foco hacia las víctimas, elaboró en un primer momento Jean Hampton y actualmente sostienen autores como Leora Dahan Katz. En nuestro país, una teoría retribucionista de este tipo, aunque mayormente centrada en las *emociones* de las víctimas, ha sido defendida por Jaime Malamud Goti.

respetar el dolor de las víctimas sin que ello determine la forma en la que deben resolverse los conflictos que las involucran, y se subraya la baja incidencia estadística de los delitos cometidos por menores no punibles. El argumento entonces es que, dada la excepcionalidad de estos delitos, la palabra de las víctimas no debería ser determinante a la hora de establecer políticas públicas.

*«Quienes propician la reducción del umbral etario suelen presentar la medida como una *solución* al problema de la inseguridad, acompañando la propuesta con consignas tales como *ley y orden*, *el que las hace, las paga* o incluso el sinsentido *delito de adulto, pena de adulto*.»*

El problema de esta respuesta es que incurre en una forma de condescendencia hacia las víctimas, al no tomar en serio los legítimos reclamos de justicia retributiva que estas—junto a gran parte de la sociedad que se solidariza con ellas—realizan. Quienes razonan de esa forma adoptan una postura de superioridad moral o epistémica desde la cual anuncian: “entiendo tu dolor y tu sed de venganza, pero así no es como las personas racionales actuamos.” Sin embargo —y sobre este punto volveré enseguida— no hay nada irracional en desear que quienes nos victimizaron sean castigados. Por otra parte, el hecho de que los delitos cometidos por menores no punibles sean escasos en nada afecta la magnitud de la injusticia que se produce cuando no se castiga a alguien que debería ser castigado. Las consideraciones de justicia —al menos desde una perspectiva deontológica— no dependen de números ni estadísticas.

Esto me da pie para introducir el segundo argumento, el cual se funda en la idea de merecimiento. Si el castigo es moralmente justificable porque el autor lo merece, entonces la existencia de sujetos que satisfacen las condiciones de la responsabilidad penal pero permanecen jurídicamente impunes representa un déficit de justicia. Una razón para bajar la edad de punibilidad podría encontrarse, entonces, en la posibilidad de subsanar ese déficit, asumiendo que la adopción de dicha medida permitiese castigar a personas que deberían ser castigadas y hoy en día, bajo las leyes actuales, no pueden serlo. ¿Pero quiénes serían esas personas?

Aquí es donde el ejemplo provisto puede servir. En efecto, según creo, Juan y Pedro —adolescentes de quince años que asesinan sádicamente a otro joven— deberían ser castigados simplemente porque lo merecen, con independencia de las consecuencias que su castigo pudiera generar. En pocas palabras, un mundo en el que estos individuos son castigados —y sufren, como consecuencia de su castigo, en proporción al daño que causaron— es moralmente mejor, *ceteris paribus*, a un mundo en el que no son castigados. No castigarlos implicaría, además, en términos kantianos, una violación pública de la justicia. La fuerza de esta intuición moral puede apreciarse al adoptar, como propone Michael Moore, la perspectiva de la primera persona: si nosotros mismos hubiéramos cometido un crimen atroz, el sentimiento de culpa que experimentaríamos nos conduciría a reconocer que merecemos ser castigados, aun si el castigo no produjera beneficios adicionales en términos preventivos. ¿Por qué entonces deberíamos ser más flexibles con los demás? ¿Acaso ellos, a diferencia de nosotros, son defectuosos en algún sentido que impide que los responsabilicemos por sus actos?

Ahora bien, llegado este punto, la respuesta habitual es que los menores de edad no merecen ser castigados con la misma intensidad que los mayores. Al fin y al cabo —continúa el argumento—, la medida del castigo que una per-

sona merece es una función de la incorrección del acto que realizó y el nivel de culpabilidad con el que obró. Resulta claro que las personas de quince años son, al menos en términos generales, menos culpables que las personas de treinta, debido al desarrollo madurativo y las capacidades cognitivas y emotivas propias de su edad. Por lo tanto, aun si fuera cierto que una persona mayor de edad que comete un terrible crimen merece ser castigada, esto no necesariamente ocurre cuando quien realiza un acto semejante es un menor.

Creo que esta objeción tampoco es convincente. La razón de ello es que resulta posible incorporar en la ley mecanismos que permitan trazar la diferencia existente, en lo que a la medida del castigo merecido se refiere, entre las personas que están por debajo de un determinado umbral etario y las que lo superan. En efecto, en este espíritu, el proyecto de ley que está siendo debatido en el Congreso contempla penas mucho menos severas para las personas de catorce a dieciocho años que para aquellas mayores de dieciocho años (por ejemplo, la pena máxima prevista para los menores de edad es de quince años, mientras que para los mayores es la prisión perpetua) y establece que los menores no podrán cumplir pena en los mismos lugares que los mayores. Por otra parte, el proyecto establece que los menores de edad inimputables no podrán ser sancionados, y para determinar la inimputabilidad exige al juez la realización de informes periciales y ambientales. Es decir, no se contempla la posibilidad de condenar a alguien que no satisfaga las condiciones generales de imputabilidad establecidas en el Código Penal —y, por tanto, que no merezca ser castigado—.

Aun así, se podría insistir en que un menor de edad —supongamos, un joven de quince años— que delinque es *siempre*, en última instancia, el producto de condicionamientos estructurales que anularon su capacidad de decisión. Sin embargo, encuentro este razonamiento problemático por dos motivos. El primero es que resulta irrespetuoso de la dignidad y agencia moral de los adolescentes, al caracterizarlos como sujetos incapaces de tomar decisiones autónomas. El segundo es que se apoya en una especie de determinismo causal que, si se lleva hasta sus últimas consecuencias, debería conducir a la imposibilidad de responsabilizar *también* a los mayores de edad. Ello por cuanto no existe una transformación ontológica automática al cumplir los dieciocho años que permita afirmar que antes no había agencia y después sí la hay. Si se admite la responsabilidad penal adulta pese a la existencia de condicionamientos sociales, resulta difícil negar toda forma de responsabilidad en adolescentes capaces de comprender la ilicitud de sus actos.

A modo de conclusión, los argumentos expuestos no pretenden agotar la cuestión ni sostener que la reducción de la edad de punibilidad esté, sin más, justificada. Se trata de un problema complejo que involucra consideraciones empíricas, institucionales y presupuestarias que aquí no han sido abordadas. Mi propósito ha sido meramente introducir en el debate una perspectiva retributiva que permita advertir un aspecto normativamente relevante —y con frecuencia ignorado— de la reforma propuesta: la posibilidad de corregir situaciones de impunidad que, desde una concepción del castigo basada en el merecimiento, constituyen un déficit de justicia. ■



Punitivismo ineficiente

por Valeria Vegh Weis

Por qué bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito

15 de febrero de 2026

La reforma de la baja de la edad de imputabilidad en Argentina se inscribe en una deriva punitivista y una agenda de “mano dura”, especialmente promovida por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el lema “delito de adulto, pena de adulto”. La reforma contradice evidencia empírica acumulada durante décadas a nivel global sobre criminalidad juvenil y los estándares internacionales de derechos humanos que protegen la condición especial de niños y adolescentes. A la vez, esta deriva punitivista desplaza el foco desde las responsabilidades estatales de inclusión socio-económica y educativa de sectores vulnerables hacia la responsabilización penal temprana de adolescentes y niños, la selectividad penal y la estigmatización social.

Qué sucedía hasta ahora?

Hasta ahora, el régimen penal argentino establecía que las personas menores de 16 años no eran punibles; entre los 16 y 18 solo podían ser juzgadas por delitos graves con penas superiores a dos años, y las penas privativas de libertad debían cumplirse en institutos de menores (para nada ideales) hasta los 18 años. La reforma impulsada por el gobierno del Presidente Javier Milei crea un nuevo régimen penal juvenil, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y permite imponer penas de hasta 15 años de privación de libertad a adolescentes de 14 y 15 años.

Evidencia empírica y el mito positivista de la “peligrosidad”

La reforma busca crear lo que un criminólogo contemporáneo, Stanley Cohen, denominó “pánico moral”, la idea de que una emergencia terri-

ble pone en riesgo la moral social y hay que responder con premura con las herramientas más severas a disposición. En este caso, el “pánico moral” que alimenta el gobierno refiere a jóvenes supuestamente determinados a cometer hechos atroces y que se aprovechan de la “benevolencia” de la ley para salir impunes. Esta narrativa es falsa. Se alimenta de unos pocos casos con mucha repercusión mediática y encuestas de opinión, más que por datos oficiales consolidados y basados en estudios científicos. Si en lugar de arrastrarnos por los discursos de emergencia prestamos atención a los datos duros veremos que la gran gama de delitos graves cometidos por menores de 16 años en Argentina es comparativamente bajo y no explica las principales preocupaciones de seguridad ciudadana, que se concentran en delitos complejos, economías ilegales y violencia armada, todos hechos protagonizados mayoritariamente por adultos y, más específicamente, por adultos con poder que raramente son perseguidos por el sistema penal.



Es más, si miramos hacia el mundo, la baja de la edad de imputabilidad no ha solucionado los problemas de seguridad y delincuencia juvenil. En otras palabras, aquellos países que han

establecido edades de punibilidad muy bajas, en torno a los 12 o 13 años, no muestran menores tasas de criminalidad, y en algunos casos presentan índices de homicidios significativamente superiores a los de Argentina. Aún peor, las investigaciones criminológicas advierten que el encarcelamiento temprano incrementa la reincidencia (la vuelta al delito), refuerza trayectorias delictivas y puede consolidar identidades criminalizadas que solo se ven a sí mismas como delinquentes sin otras opciones biográficas posibles. En fin, es una encerrona: lo que muestran las investigaciones científicas es que la baja de la edad de imputabilidad y el tratamiento punitivo de los jóvenes se convierta paradójicamente en factor de más delito y no de prevención. Todo ello se agrava por las condiciones deplorables en las que se alojan estos niños y adolescentes, donde la garantía de un trato diferenciado y la prevención de malos tratos y torturas son una quimera. La práctica carcelaria argentina muestra violaciones sistémicas a los derechos humanos de todas las personas. Niños y adolescentes no son la excepción.

En cambio, países como Alemania, establecen que partir de los 14 y hasta los 17 años se aplica un derecho penal juvenil específico (*Jugendstrafrecht*) con énfasis en el abordaje educativo y una amplia discrecionalidad judicial para adecuar la respuesta al desarrollo y entorno de las infancias (p. ej., trabajos comunitarios, programas de formación) en lugar del encierro. Solo recurren a la privación de libertad en una minoría de casos (2-5%) con penas relativamente cortas y que se cumplen en establecimientos especializados y se conciben como último recurso, en coherencia con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Es más, a los jóvenes de 18 a 20 años se les puede seguir aplicando el derecho penal juvenil si su grado de madurez se asemeja al de un menor de 18 años, lo que supone una concepción flexible de las infancias.

Delinquentes o simplemente pobres?

Un aspecto crítico de la reforma es el impacto selectivo que tendrá sobre niños y adolescentes de sectores populares, particularmente varones jóvenes de barrios periféricos, que ya son objeto privilegiado de persecución y violencia policial, sobrecriminalización judicial y maltrato penitenciario. En otras palabras, la baja de la edad de imputabilidad tiene un target específico: no se va a criminalizar a los “peores delinquentes” sino a los jóvenes pobres sin recursos para defenderse de la selectividad miope de las agencias de persecución penal. Mientras, aquellos involucrados en la criminalidad de cuello blanco, la violencia empresarial, los daños contra el ambiente y la explotación laboral ilegal continuarán impunes a las presiones del poder punitivo. Nada nuevo bajo el sol.



Todo ello se agravará por las condiciones deplorables en las que se alojan estos niños y adolescentes, donde la garantía de un trato diferenciado y la prevención de malos tratos y torturas son una quimera. La práctica carcelaria argen-

tina muestra violaciones sistematicas a los derechos humanos de todas las personas. Niños y adolescentes no son ni serán la excepción.

Qué hacer?

Por el contrario, la literatura identifica que las vías para abordar seriamente la delincuencia juvenil deben centrarse en más presencia estatal desde un abordaje socio-económico integral. Esto significa responder al abandono escolar, la precariedad laboral, la violencia institucional y la segregación territorial como variables centrales de la conflictividad juvenil.

Desde la perspectiva de los tratados de derechos humanos, múltiples organizaciones con una larga trayectoria en el abordaje de la delincuencia juvenil y los derechos de niños y adolescentes han advertido que bajar la edad de imputabilidad supone un retroceso respecto de los estándares construidos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución. Estas regulaciones promueven más medidas socioedu-

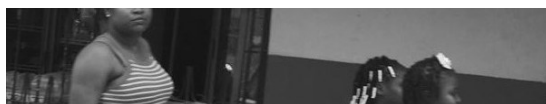
cativas, abordaje integral, participación comunitaria y mínima intervención punitiva. Se trata de fortalecer equipos interdisciplinarios, crear programas de mediación y reparación, ampliar las medidas en medio abierto y reservar la privación de libertad como último recurso, por el menor tiempo posible y en condiciones estrictamente controladas judicialmente. Lo que exige la ley internacional es articular la política penal juvenil con políticas integrales de educación, salud mental y empleo joven, de modo de prevenir mucho antes que exista el conflicto penal. En fin, todo lo contrario a la reforma que protagoniza nuestro país.

En concreto, los derechos previstos en tratados internacionales y en nuestra Constitución Nacional implican respetar que se trata de personas en pleno desarrollo, muchas veces con carencias estructurales producto de la ausencia de políticas estatales de distribución de la riqueza. Son se trata del derecho a ser penado como adulto. Se trata del derecho a ser tratado con la dignidad que su edad y situación de vulnerabilidad requieren. ■

«La práctica carcelaria argentina muestra violaciones sistematicas a los derechos humanos de todas las personas.»



«Es más, si miramos hacia el mundo, la baja de la edad de imputabilidad no ha solucionado los problemas de seguridad y delincuencia juvenil.»



Un régimen penal juvenil para la opinión pública

por Sebastián Guidi

Una ley penal juvenil que nadie pidió y que todavía se puede corregir.

17 de febrero de 2026

1. ¡Hicieron lo que dicen las encuestas! ¿Hicieron lo que dicen las encuestas?

El jueves pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil. Dos narrativas compiten para explicarlo. La primera, la de los impulsores del proyecto, es que la política ha finalmente accedido a un reclamo añejo de la ciudadanía. La mayoría de los diputados ha entendido que no puede seguirle dando la espalda al sentido común y la opinión pública, que en porcentajes avasallantes inundaba las encuestas con respuestas afirmativas a la pregunta de si bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años. Se trató, como suele decirse, de saldar una “larga deuda” que la política mantenía con la sociedad.

La segunda narrativa es su reverso: los representantes han sucumbido ante la ira de una turba punitivista e irreflexiva. En lugar de ejercer su rol responsablemente, templando las pasiones públicas y encauzándolas en programas de gobierno civilizados, los diputados han elegido actuar como meros amplificadores de la concupiscencia populista. No faltan ejemplos de las mayorías apoyando atrocidades de las cuales luego se arrepienten, nos recuerdan; las élites políticas deberían hacer su parte para impedirlo.

Creo que ambas comparten una premisa equivocada: que la Cámara de Diputados se haya hincado ante la opinión pública. No soy ingenuo: conozco las encuestas que se blanden, con un 60, 70, 80% de respuestas a favor de bajar la edad, y no tengo motivos para descreer de ellas ni para descalificar a los encuestados. Ni siquiera tengo una objeción de principio a utilizar, en oca-

siones, encuestas bien realizadas como insumo para la acción de gobierno: que los ciudadanos sientan que los gobernantes están alineados con sus creencias y deseos, e incluso hacen algo para alcanzarlos, es una fuente de legitimidad y estabilidad para cualquier sistema político.

Sin embargo, el tránsito de una encuesta a una política pública o a una ley no es lineal: hay una ardua tarea interpretativa para ir desde las dos o tres respuestas binarias que pueden obtenerse en una encuesta a la complejidad que tiene una política pública que enfrenta los dilemas del mundo real. En las encuestas, la gente quiere bajar impuestos y subir el gasto al mismo tiempo. En general, esa opción no está disponible para los dirigentes políticos, y, sin embargo, ahí está la opinión pública esperando ser complacida.

Tal vez un ejemplo ilustre las complejidades de legislar con base en encuestas. El constitucionalista estadounidense Cass Sunstein en algún momento [se burló](#) de que el 80% de los encuestados se declaraba a favor de etiquetas frontales para los alimentos “*que contienen ADN*”. Para Sunstein, sería absurdo que los legisladores o las agencias reguladoras se dediquen a cumplir con este aparente mandato mayoritario: solamente la sal de mesa escaparía del temible octógono negro.

Sin embargo, creo que también es un error limitarse a desestimar a los encuestados con una burla: evidentemente ese porcentaje quería decir algo, y muy probablemente, por el contexto en el que se realizó la encuesta, indicara que los encuestados desean saber cuándo los alimentos fueron genéticamente modificados. Uno puede discutir si esta etiqueta es útil o no (después de todo, dice Sunstein, no hay evidencia científica

de que los alimentos genéticamente modificados planteen mayores riesgos a la salud). Sin embargo, lo que no puede hacerse es nada: debe entenderse el resultado de esa encuesta (¿qué es realmente lo que quisieron decir?) y debatir con el público (¿habrá algo que no entiendan?). Llegado el caso, si tras una deliberación la mayoría es persistente, acaso no quede más remedio para los representantes en una democracia que hacer algo al respecto.

Mi hipótesis es que, ante lo contundente de las encuestas, muchos de nuestros legisladores no buscaron comprender a la opinión pública ni mucho menos interactuar con ella, sino que, acorralados por una dinámica política patológica, se pusieron a discutir el tamaño de la etiqueta. Por ponerlo en términos más formales: creo que el proyecto que se aprobó no solamente es malo, sino que ni siquiera respeta a la opinión pública de la que se presenta como súbdito.

2. ¿De qué está hecho el 70%?

No he tenido acceso a la metodología de las encuestas que han circulado en estos días, y presumo que habrá algunas más serias que otras, pero probablemente la pregunta haya sido si *“usted está a favor de bajar la edad de imputabilidad para los menores que cometen delitos”* o algo parecido. El 70 u 80% de los encuestados, aparentemente, dijo que sí.

Está claro que esa respuesta no se da en un vacío: siempre que se habla de este tema en los medios de comunicación se lo vincula con hechos escalofriantes, generalmente asesinatos. Creo que es seguro asumir que son hechos como esos los que tienen en la cabeza quienes responden: si un chico de 13, 14 o 15 años mata a alguien, ¿tiene que sufrir un castigo? Evidentemente, por lo menos sin pensarlo demasiado, una gran mayoría cree que sí. Uno puede, desde ya, creer que muchos de ellos darían otra respuesta si se sentaran a pensar sobre el tema o si la pregunta hubiera sido otra (*“¿usted cree que es útil que un adolescente pase varios años en una cárcel por haber cometido un delito?”*). También uno podría asumir que

los encuestados responderían diferente si tuvieran presentes las estadísticas al respecto sobre participación de adolescentes en hechos delictivos graves o sobre la influencia del sistema penal en la posibilidad de reincidencia.

Hagamos, de todos modos, el ejercicio de tomar las encuestas por lo que dicen que valen: una enorme mayoría de los encuestados cree que a los 13 o 14 uno entiende la criminalidad de ciertos actos y puede recibir un reproche estatal al respecto. Por ahora, eso parece todo. Bajo algunas condiciones, por cierto, yo estaría en ese 70%: creo que un chico de 14 años, efectivamente, está en condiciones de hacerse cargo de algunas de sus conductas. El diablo, claro, siempre está en los detalles: de qué conductas, con qué garantías, bajo qué condiciones.

A falta de estudios más detallados, entonces, les propongo un experimento mental. Pensemos en qué opinarían los encuestados de los siguientes diez casos que voy a proponer. No lo que nosotros pensamos ni lo que pensamos que otros deberían pensar: intentemos imaginar qué piensa, de verdad, el 70% ante cuyo altar se ha ofrecido este proyecto.

- Un adolescente de 15 años falsifica un DNI para aparentar 18 y entrar al boliche. No lo usa para ninguna otra cosa. (Se trata de falsificación de documento público, agravada por tratarse de un documento de identidad, y tiene una pena de 3 a 8 años de prisión).
- Otro adolescente imprime en su casa las “consumiciones” del boliche, que luego usa para conseguir tragos gratis para sus compañeras. (Delito de estafa, un mes a seis años de prisión).
- Un adolescente, muy ducho en informática, quiere impresionar a sus amigos y hackea el sistema informático de la escuela. Les pone 10 a todos en Educación Física. (Hackeo agravado, un mes a un año de prisión).
- Un adolescente desea escapar de una prueba de Historia y llama al colegio diciendo que hay una bomba, por lo que el establecimien-

to debe ser desalojado. (Intimidación pública, dos a seis años de prisión).

- Dos adolescentes se pelean por algún asunto menor. En un mal movimiento, uno le quiebra la muñeca al otro. (Lesiones graves, uno a seis años de prisión).
- Dos adolescentes están enemistados. Uno escribe un graffiti en la pared de la escuela a la que concurre el otro, insultándolo. (Delito de daños agravado, prisión de 3 meses a 4 años).
- Una chica de 12 años comienza a salir con un compañero de su curso que tiene 14 (repitió el año). Una noche, en la casa de ella y de común acuerdo, se tocan por debajo del pantalón. El padre de ella ve la escena en las cámaras de seguridad de su casa y denuncia al chico, contra la voluntad de su hija, afirmando que los menores de 13 no pueden consentir ninguna relación sexual. (Abuso sexual simple, 6 meses a 4 años de prisión).
- Un grupo de adolescentes está molestándose entre sí. Uno, pensando que es una broma, le baja los pantalones al otro y un tercero, siempre en actitud bromista, intenta colocar algún objeto en su recto. El adolescente se libera inmediatamente, se sube los pantalones y se va. La madre se entera y, contra la voluntad de su hijo, los denuncia por tentativa de abuso sexual con acceso carnal (6 a 15 años de prisión).
- Un adolescente sale en auto (se lo prestan o se lo saca a sus padres sin permiso, irrelevante por ahora). Va escuchando música fuerte, se distrae, pasa un semáforo en rojo, causa un accidente. Su hermano, que iba con él, queda internado y termina por perder el sentido del olfato. No hay otros heridos. (Lesiones gravísimas culposas agravadas, dos a cuatro años de prisión).
- Finalmente, durante una epidemia un grupo de adolescentes organiza una guitarreada en una quinta, violando las normas sanitarias de aislamiento. (Violación de medidas sanitarias, seis meses a dos años de prisión).

Naturalmente, los ejemplos podrían seguir. Me gustaría saber qué piensan: del 70 u 80% que contestó que deseaba bajar la edad de punibilidad, ¿cuántos creen que desearían que el sistema penal se involucre en esos casos? Imagino que no todos; de hecho, sospecho que más bien pocos. Intuyo que la mayoría creerá que son asuntos que no merecen un reproche penal, que merecen ser resueltos en la casa, ayudado por los adultos de su comunidad a reparar el daño que hicieron. De ninguna manera, por ejemplo, creo que la mayoría considere que los adolescentes de los ejemplos tengan que conservar un antecedente penal de por vida que, por ejemplo, cualquier futuro empleador verá.

Supongamos que me equivoco, y que un grupo grande de estas personas sí cree que los episodios que mencioné merecen una intervención estatal en forma de reproche penal. ¿Cuántos de ellos -de esos mismos que creían que un adolescente que mata a alguien tiene que sufrir un castigo- creerán que la prisión es la respuesta adecuada? Es decir, ¿cuántos creen que el joven que cometió el hecho tenga que interrumpir su escolaridad, abandonar a su familia y amigos, atravesar un trauma monumental, para pagar por lo que hizo? ¿Cuántos de ellos creerán que la pena de prisión lo educará para ser un mejor ciudadano? De nuevo: discúlpennme si estoy viviendo en una burbuja, pero creo que casi nadie.

Una última pregunta, para el núcleo duro que todavía crea que alguno de los delitos que mencioné debería ser castigado con prisión: ¿habrán hecho el ejercicio de pensar que los imputados podrían ser sus hijos, especialmente si son adolescentes varones? ¿O que podrían haber sido ellos mismos hace unos años? Me permito agregar algo: la mayoría de los ejemplos los tomé de situaciones que he visto o me han contado durante mi propia adolescencia de clase media. Ninguno de sus protagonistas, por cierto, continuó una carrera delictiva.

3. El texto y el palacio

El gobierno parecía entender lo mismo: a la opinión pública la conmueven los delitos graves. Sus voceros ponían una y otra vez de ejemplo excluyente el homicidio: “*Matan y vuelven a su casa como si nada*”, escribió Patricia Bullrich militando el proyecto, junto a una foto abrazando a la madre de Jeremías Monzón. La asesora comunicacional Eugenia Rolón fue más explícita: “*Se aplica a delitos graves. No estamos hablando de una simple travesura sino de delitos graves como robo a mano armada, violaciones, asesinatos... Delitos que del otro lado tienen una víctima real que merece justicia*”. El eslogan “*delito de adulto, pena de adulto*” siempre, pero siempre, era ejemplificado con un homicidio.

Dado que éste era el marketing del proyecto, uno podría haber esperado que el texto de lo que se votó fuera en esa línea: baja de edad de imputabilidad únicamente para delitos muy graves (podría, incluso, haberse limitado a esos que enumeró Rolón) o, por lo menos, con penas de prisión sólo para ellos. No fue lo que ocurrió: parafraseando a Roberto Gargarella, se permitió el lenguaje de la resocialización, la tutela estatal y la dignidad de los adolescentes en la “*sala de juegos*” de la ley, al establecer principios rectores y cosas así. A la hora de los bifes, la “*sala de máquinas*” es implacable: salvo el límite superior de los 15 años de prisión, y algunas salvaguardas condicionales (volveré a esto), efectivamente se prevé prisión para todos los delitos y en condiciones similares (¡a veces peores!) que los adultos.

«El proyecto que se aprobó no solamente es malo, sino que ni siquiera respeta a la opinión pública de la que se presenta como súbdito.»

Era fácil percibir la incomodidad de la política con esta duplicidad. Con pocas excepciones, los sectores que apoyaron el proyecto (casi to-

da la Cámara salvo el peronismo y la izquierda) enfatizaban la necesidad de que el Estado apoye y contenga a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Una anécdota: mientras yo escuchaba el debate, mi mujer estaba haciendo otra cosa, prestando atención flotante. En algún momento escuchó a una diputada de La Libertad Avanza hablar sobre la necesidad de rescatar a los niños de la droga, de rehabilitarlos, darles herramientas... Sin ninguna ironía, observó “*qué raro que una diputada de La Libertad Avanza vote en contra*”. Me despabiló: si uno escuchaba lo que decían muchos diputados, resultaba disonante que votaran a favor del texto que, en efecto, votaron.

Para empezar, el proyecto contempla *las mismas penas* que el Código Penal de los adultos, para todos los delitos. Volvamos al experimento mental del apartado anterior: todos esos chicos, potencialmente, atravesarían un proceso penal y podrían ir a la cárcel. Es verdad que en ciertas circunstancias hay algunas salvaguardas para evitarlo. Por ejemplo, para los delitos cuya pena máxima es de tres años (es decir, sólo uno en los ejemplos de arriba) debe aplicarse una pena alternativa, como amonestación o servicios comunitarios. Para delitos más graves, con penas entre 3 y 10 años de prisión, incluso si son culposos, se dispone la aplicación de penas alternativas únicamente si “*no existieran lesiones gravísimas*” ni se hubiese causado “*la muerte o un daño psíquico grave a la víctima*”.

Sin embargo, incluso con estos límites, esto solamente es cierto si se trata del único delito que comete el joven (si, por ejemplo, es el mismo joven el que pinta el graffiti y el que le quiebra la muñeca al otro, ya no evitará la prisión). Además, tampoco podrá hacerlo si resultó la muerte, lesiones gravísimas o un grave daño psíquico: varios de los ejemplos de arriba podrían caer en esta bolsa, incluso en delitos culposos como los que se cometen al volante. Prisión.

Tampoco alcanza la salvaguarda del “*principio de oportunidad*”. El art. 41 de la media sanción permite al fiscal prescindir de la acción penal únicamente en delitos cuya pena máxima no su-

pere los 6 años y con las mismas condiciones que describimos en el párrafo anterior. Un adolescente que comete un homicidio o lesiones culposas, por ejemplo, debe ser perseguido sí o sí, con pena de prisión sí o sí. Lo mismo si el adolescente ya tiene un procesamiento (ni siquiera condena: procesamiento) anterior: a partir de ese momento, por leve que sea el delito, el fiscal deberá perseguirlo sí o sí, con pena de prisión sí o sí.

Esto es particularmente impresionante porque, en este punto, el régimen penal juvenil es *más severo* con los chicos que con los adultos. En la mayoría de las regulaciones procesales aplicables a adultos (incluyendo el Código Procesal Penal Federal) la discrecionalidad del fiscal para aplicar criterios de oportunidad está mucho menos limitada. Así, por ejemplo, son varios los códigos procesales locales que admiten que el fiscal no persiga por “pena natural” (es decir, que el autor haya sufrido un grave sufrimiento a causa del mismo hecho). Si un adulto, digamos, mata culposamente a su hermano, o queda paralítico en el mismo accidente en el que mata a otra persona, el fiscal puede elegir no perseguirlo por haber sufrido lo suficiente. Si se trata de un adolescente, en cambio, debe perseguirlo sí o sí. Hasta donde sé, además, ningún código procesal impide al fiscal ejercer la oportunidad procesal porque exista un procesamiento previo, como hace la media sanción. *A delito de adulto, más pena que un adulto.*¹

Me atrevo a conjeturar que la opinión pública no exige estas regulaciones y que la mayoría de los diputados tampoco las habría querido. Creo que un proyecto que, por ejemplo, elimine la pena de prisión para la mayoría de los delitos, o las reduzca a, digamos, la mitad de lo que sería la pena de un adulto gozaría de por lo menos la misma aceptación social que este proyecto, si no más, y habría dejado más tranquilos a la mayo-

ría de los diputados. ¿Por qué no obró, entonces, la mano invisible del mercado?

Sunstein, a quien ya cité más arriba, describió un fenómeno ubicuo: la polarización de grupos. Una vez que un grupo ha adoptado una determinada orientación, su dinámica colectiva tiende a llevarlo cada vez más lejos en esa dirección: se genera un clima que penaliza a los que, incluso acordando en general, plantean matices o prevenciones, y privilegia a los que se presentan como heraldos de la postura ya adoptada. Una vez que el proyecto estaba en la Cámara, y ya era claro que iba a ser aprobado, los diputados (¡incluso los que estaban a favor!) percibían como riesgoso alertar sobre sus excesos, incluso si el resto habría estado de acuerdo con él. En esas condiciones, el proceso legislativo avanzó con la determinación de una tragedia griega: la media sanción de la Cámara de Diputados, a punto de convertirse en ley, es más severa que lo que la mayoría (y no solamente el progresismo, la Iglesia o UNICEF) habría querido.

4. ¿Cómo seguir?

Acaso debamos aceptar que en las próximas semanas este proyecto se convertirá en ley. No parece realista creer que el gobierno no replicará en el Senado el casi 60% que obtuvo el proyecto en la Cámara Baja. Sin embargo -¿seré muy ingenuo?- sí puede esperarse que el Senado modifique el texto que recibió de la Cámara de Diputados. De hecho, el oficialismo aceptó a último momento algunas modificaciones propuestas por la oposición, por ejemplo, para aclarar que los menores de edad no pueden ser detenidos en el mismo establecimiento que los adultos, o para permitir la probation de los menores de 18 en las mismas condiciones que los mayores.

Si tengo razón, y el texto de lo que se aprobó es más severo que lo que la mayoría de los legisladores querría, y de lo que la opinión pública

¹Algo similar ocurría en el dictamen original con la *probation*. En el régimen de adultos (art. 76 bis del Código Penal), no se exige el consentimiento de la víctima para que un imputado acceda a la *probation*. En cambio, el dictamen preveía que la querrela sí podía vetar la *probation* de un adolescente. Afortunadamente, el oficialismo aceptó modificar este aspecto en el recinto, a propuesta del bloque Provincias Unidas.

demanda, el Senado tiene una oportunidad para corregir el texto y llevarlo a algo más cercano a lo que mi hipotética mayoría espera de él.

Por ejemplo: ¿por qué no limitar la pena de prisión, o todo el régimen, únicamente a los delitos muy graves? Esta modificación sería casi gratuita: el oficialismo ha sostenido la reforma prácticamente haciendo de cuenta que esto ya es así. No sería para nada difícil de explicar que la redacción sobreinclusiva actual fue un error bien intencionado de la Cámara de Diputados, pero que a la luz de las restricciones presupuestarias es preferible limitar el régimen a los casos más graves, y destinar la mayoría de los recursos a resocializar a los adolescentes que cometen delitos graves. No hay plata.

Otro ejemplo: eliminar las restricciones al ejercicio de la oportunidad procesal por parte del fiscal, dejando que cada provincia lo regule libremente (¡como ocurre con los adultos!). Esto tiene la ventaja de que la Constitución exige que las cuestiones procesales sean reguladas por las provincias, y hay consenso en que el principio de oportunidad es una cuestión procesal. Además de salvar la constitucionalidad de este aspecto del proyecto, dar una mayor discrecionalidad a los fiscales permitiría que limiten su actividad a los delitos más graves.

Un último ejemplo: podrían incluir una cláusula asegurando que después de un tiempo corto se eliminará todo registro de antecedentes penales para los adolescentes que fueron condenados. Nada de lo que hagas como adolescente puede perseguirte toda tu vida, y tener que dar explicaciones sobre una entrada en el registro complica para siempre a cualquiera, por más leve que haya sido el delito. Un adolescente tiene derecho a dejar atrás su pasado de un modo más radical que un adulto, y creo que esto podría explicarse fácilmente ante la opinión pública.

Para que estos cambios se produzcan, hay dos opciones. La primera es que los bloques que todavía se presentan como centristas se planten en lograr algunas modificaciones: régimen penal juvenil, sí; cualquier cosa, no. Si logran articularlo bien, podría servirles para mostrar un resto de coraje y autonomía frente a un gobierno que ya se presenta en público como controlando los dos tercios de las Cámaras. Llegado el caso, cuando la historia pegue la vuelta, les permitirá mostrar que impusieron límites, que no permitieron cualquier cosa, que siempre estuvieron a favor de lo bueno y en contra de lo malo.

La alternativa, creo que en definitiva más plausible, es que el cambio venga del propio oficialismo: nadie va a correr por derecha a Patricia Bullrich. Algunas reformas quirúrgicas, con la excusa de buscar que el régimen funcione mejor y enfocado en lo importante, de que el presupuesto no es suficiente, de que la implementación gradual es la única manera de asegurar que al menos para algunos delitos el régimen entre en vigencia inmediatamente. Es más: en la insólita negociación de penas que estos usualmente incluyen, podría compensarse simbólicamente subiendo las penas a quienes “usan menores para delinquir”.

En definitiva, hoy el Senado tiene la oportunidad de dar mayor racionalidad a una ley que, en su forma actual, ni siquiera es una demanda intensa. Pueden hacerlo sin renunciar a su discurso de mano dura, a su imagen de sheriffs implacables. Si el proceso sale bien, no solamente la ley será apenas más aceptable para el progresismo y para los operadores que, después de todo, son los que deberán hacer funcionar el sistema todos los días: la acercarán a lo que, uno asume, la mayoría de la opinión pública realmente querría si se le preguntara. Acaso una democracia como la nuestra podría contentarse con esa aspiración tan modesta. ■

Infancias heridas

por Máximo Lanusse Noguera

La pena y la infancia son dos o más rectas situadas en un mismo plano que, por más que se prolonguen, nunca se deberían cruzar.

19 de febrero de 2026

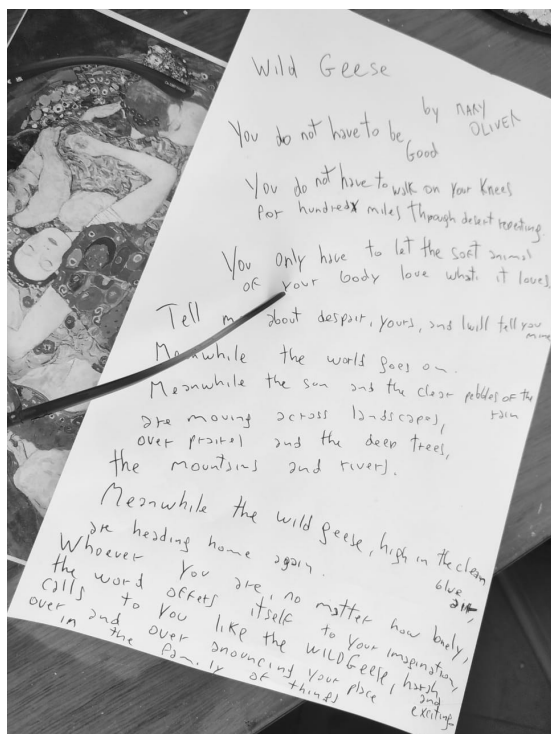
Cuando me invitaron a escribir esta columna mi primera reacción fue: ¡qué difícil escribir sobre infancias y dolor penal! ¡Qué adverso el ejercicio de pensar las violencias y las infancias! No desde su (lamentablemente no poco habitual) lugar de víctimas de tantos abusos del sistema-mundo adulto, sino desde el impulso político recurrente de colocarlos en el rol de posibles victimarios con responsabilidad criminal.

Me atrevo a creer que no estoy solo cuando la imaginación (y cierta ineludible tristeza) me empuja, a una analogía con la vieja definición euclidiana de las líneas paralelas: [la pena y la infancia] *son dos o más rectas situadas en un mismo plano que, por más que se prolonguen, nunca se [deberían] intersec[ar], cruza[r] o toca[r], al menos en lo que no se vincula con los inevitables efectos directos o indirectos al recaer sobre sus responsables parentales. La reducción del tópicico a la “edad de inimputabilidad” trabaja acaso en ese registro de lo impensable, de la frontera absoluta. Como casi toda frontera, allí se juegan los confines últimos de una cultura y una identidad colectiva, un nosotros. De allí que no sea casual que, en este tema, como en otros de similares alcances simbólicos, se alcen voces como la de la Conferencia Episcopal Argentina, aun contra cierta expectativa de secularización del debate público (UNICEF también hizo lo propio).*

Sin embargo, la geometría proyectiva, admite un punto en el plano, en el infinito, en el que las paralelas se encuentran. En el laberinto del tiempo, heme aquí, forzado a revisitar y tomar prestado un sentido y profundo título de Eligio Resta “*La infancia herida*”.

También se ha utilizado la noción de *paralelismo* para explicar la sustancia en Spinoza y sus infinitos atributos. Una ética y una ontología que impugnó el sistema del juicio (moral) e invitó a concebirla como una comprensión relacional e intensiva del ser, donde la alegría expresa la potencia que somos y la tristeza la disminución que en el extremo nos descompone.

Ahora bien, en otro pliegue, sería ingenuo ignorar a su vez que, por algún (no tan extraño) motivo, en la imaginación popular ha sido más que recurrente asociar el problema de la inseguridad al de la inimputabilidad, como si allí se jugara nuestra impotencia colectiva cuando alguna ola de violencia nos toma por (cínica) sorpresa. Y alcanza con observar los sondeos de opinión o encuestas, para verificarlo. El vínculo caprichoso entre políticas de seguridad, política criminal y derecho penal, merita un tratamiento independiente y más profundo.



Vencidas algunas de estas necesarias inercias, la lectura del proyecto que se encuentra en debate legislativo, y que ya ha conseguido media sanción en la Cámara de Diputados, se vuelve imperativa, para un abordaje (adulto y responsable) de tamaño asunto que abre la posibilidad de responder penalmente para quienes aún carecen de derechos civiles y políticos plenos.

Más de una diputada y/o diputado, durante el debate, reparó con énfasis en una reacción acaso sintomática que genera una primera lectura: “el proyecto está muy lejos de los slogans políticos que se escuchan: delito de adulto, pena de adulto...”. Hasta se escuchó decir algo así: “tiene un horizonte mucho progresista que lo que se dice para la tribuna”. Y hay que admitirlo, lejos de simplemente modificar la edad mínima de imputabilidad penal o la frontera inimputabilidad, el proyecto aspira a instituir un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil cuya finalidad queda delineada en su artículo cuarto:

¹Eligio Resta, *La infancia herida*. Ed AD HOC, Bs. As. 2008, p. 39. El autor utiliza, en rigor, las voces latinas puer y senex, para referirse a niños y adultos, evocando los arquetipos junguianos, porque le interesa, tal vez, imprimir la reflexión en el terreno de lo real, lo imaginario y lo simbólico.

“...fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito...”

Más allá de los siempre posibles matices con las palabras, difícil disenter con aquel horizonte, como también arduo no sospechar una vez más, del recurso al poder penal como pharmakon. Solo que, como civilización, hemos olvidado la polisemia griega de esa palabra (remedio/ antídoto, veneno, pero también, chivo expiatorio) que debería prevenirnos de la arrogancia de cualquier racionalidad instrumental.

Eligio Resta, evocando a Kafka y también a la fábula del “Rey desnudo”, recuerda que “[e]l [niño] es el verdadero, y quizá el último, crítico de la ideología de memoria marxiana al adulto por aquello que él es o hace y no por aquello que él dice ser o dice hacer. Y que nuestras instituciones son una red compleja de ‘doble discurso’ es una historia cotidiana”¹

De manera sintomática también se instaló, esperemos que como algo más que una chicana política (aunque la velocidad de su tratamiento legislativo permiten dudar), la interpelación a las versiones iniciales en torno a las previsiones presupuestarias que debían incorporarse el proyecto de ley, si se pretendía imprimir alguna pretensión de seriedad a los objetivos y mecanismos establecidos en el nuevo régimen. Es que en un ejercicio de realismo penal marginal ante un asunto tan relevante como la posibilidad de criminalizar infancias, hasta el cinismo (esta vez no en sentido griego sino moderno) y la hipocresía que vienen con la vida adulta tiene un límite. La entrada en vigencia 180 días después de la publicación se inscribe en el mismo gesto de hacer “como si” creyéramos en la letra de la ley en un contexto de contracción sistemática de cualquier idea de estado (social) de derecho.

Doloroso es constatar que el interés superior del niño, como tantos otros objetos de “tutela” (también lo subraya Resta), demasiado habitualmente significa otras cosas y, raramente su interés concreto. Cualquier pretensión de colocar la pena al servicio de la pedagogía acrecienta los temores y las sospechas de arrogancia, prepotencia y doble discurso.

Huelga advertir que la discusión de fondo, lejos está de una frontera etaria, también que sería absurdo negar la necesidad de una reforma (con el debido respeto al principio de progresividad en materia de derechos humanos) de una legislación que data de comienzos de la década de 1980, es decir de antes de la suscripción y ratificación de la Convención de derechos del Niño, así como de Ley de protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

«El vínculo caprichoso entre políticas de seguridad, política criminal y derecho penal, merita un tratamiento independiente y más profundo.»

Pero sí, es necesario colocar bajo un fuerte escrutinio crítico-democrático cualquier pretensión de utilizar a la política criminal, es decir a la violencia estatal (entendida como la coerción fundada en el monopolio del uso de la violencia legítima), para fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social y ... procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia. No en términos de colocar en dudar ese horizonte como deseable, sino de interrogarnos seriamente sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, del instrumento punitivo para realizarlo. Es que el llamado poder penal ha fracasado sistemáticamente como política de gestión de la conflictividad y de absorción y minimización de la violencia, y el de-

recho penal, como conjunto de límites para reducir su arbitrariedad (Alcanza con contrastar la ley de ejecución penal, bajo sus propios postulados y compromisos constitucionales y convencionales, con las prácticas punitivas). Nótese, además, que el único argumento divulgado de “política criminal” propiamente dicho, se reduce al aprovechamiento por parte de las crecientes estructuras de criminalidad organizada de menores inimputables para perpetrar crímenes violentos. Argumento cuyo absurdo salta a la vista, en la legislación comparada, cuando tal fenómeno a lo sumo se desplaza hacia franjas etarias por debajo del mínimo legal, lo cual acrecienta en lugar de mitigar los riesgos (lo que se forzaba a realizar a los de 15 se desplaza a los de 13).

El proyecto de ley, y aquí se juega una importante disputa hermenéutica y práctica todavía por darse, abre sin lugar a dudas una posibilidad punitiva donde antes, no la había. Sin olvidar con ello, los riesgos del siempre vigente poder punitivo subterráneo que en más de una oportunidad alzó voces en contra de los sistemas tutelares, que, con la excusa de las situaciones de riesgo, servían para institucionalizar infancias sin ninguna de las garantías del debido proceso, casi rogando que fueran tratadas como adultos (cuando más que ello, lo que había que impugnar era el poder punitivo en sí mismo). Pero también deja en claro, un orden de prelación (arts. 4, 5 y 12 del proyecto de ley), que la pena es última ratio y la privación de la libertad, extrema ratio. Puede leerse entre líneas un horizonte restaurativo en lugar de punitivo, con una importante consideración hacia la víctima, con espacio para el ejercicio del principio de oportunidad por parte del Ministerio Público Fiscal, así como para la mediación penal. Instituciones que han buscado abrirse camino, no sin dificultades, entre la hiperinflación penal y su crisis de legitimidad y eficacia, en el sistema penal de adultos. El horizonte posible de una pena privativa de la libertad efectiva de hasta 15 años debe ser leído como una aberración que se deberá trabajar por

evitar a toda costa, para lo cual los peldaños esgrimidos en la propia ley deben convertirse en insumos.

Paul Ricoeur, en una serie de trabajos destinados a magistrados y funcionarios publicados bajo el título *Lo Justo*², señaló la importancia de una gramática del sujeto capaz (de hacer, de decir, de narrar-se), para pensar la autonomía en su relación paradójica con la vulnerabilidad o fragilidad. Curiosamente, aquella autonomía de raíz kantiana opera como presupuesto de la praxis ética, pero a la vez, su desarrollo, se trata de una tarea, todavía por realizarse. El problema de la imputabilidad desafía la posibilidad de llamar a responder, no podemos juzgar sin juzgar las precondiciones y las condiciones para juzgar. Cualquier práctica de asignación de responsabilidad exige trabajar y construir un lenguaje con autoridad en el que lo que hacemos, lo que decimos y la forma en que nos narramos está mediada por un otro y una ética del reconocimiento. Toda autonomía supone vulnerabilidad y toda autoridad, comunidad. La ética expresa esa decisión de vivir juntos, deseo que para materializarse exige obligaciones, que median la relación de la ipseidad con la alteridad. Es por ello que es preciso pensar juntas la identidad narrativa y las prácticas de la responsabilidad. Desgraciadamente, la práctica de la inculpación penal da por descontado el como sí que liga agencia, imputabilidad y responsabilidad criminal.

Si el derecho es forma y estructura, que no está al servicio meramente nominal de aquello que

como comunidad política (decimos) nos importa, sino que persigue brindar garantías que hagan más probable lo improbable, resulta elemental alejarnos de la ingenuidad y el cinismo, y trabajar con compromiso irónico para que ninguna infancia se vea restringida en sus derechos en nombre de la tutela de algún bien, cuyo valor positivo (posiblemente) no le hemos podido asegurar, como experiencia, en sus lazos cotidianos y comunitarios (una vida libre de violencia donde el juego del niño tiene la virtud de donar dignidad a todos los objetos y consciente del modo en que en la infancia la curiosidad convierte todo en nuevo y cotidiano, cada gesto, cada historia, es siempre la misma y siempre nueva³). Si como sugiere el proverbio africano (también recogido por una canción popular) it takes a village to raise a child a la hora de pensar en formas de instituir un modo más responsable de ser y estar en el mundo, siquiera preguntarnos por la responsabilidad criminal de un niño o niña debería colocar en el centro nuestra propia oscuridad y los modos en que expiamos nuestra monstruosidad cotidiana. Caso contrario, en la medida que nos seguimos entregando a la aceleración tecnológica, privando del tiempo de los afectos, y renunciando a la disolución del tiempo (o esa eternidad) en el juego de las infancias, olvidamos el secreto que el zorro le transmitió al principito de Saint Exupéry, sobre la dignidad y el reconocimiento, que nada expresa mejor que los lazos de amistad y el cultivo del tiempo compartido que somos. ■

«Más allá de los siempre posibles matices con las palabras, difícil disentir con aquel horizonte, como también arduo no sospechar una vez más, del recurso al poder penal como pharmakon.»



²Paul Ricoeur, *Lo justo*, Ed Jurídica de Chile, 1997. Paul Ricoeur, *Lo justo 2*, Ed. Trotta, 1999.

³Eligio Resta, *La infancia herida*. Ed AD HOC, Bs. As. 2008, p.42 y 43

La "Magia Veneno" de la República

por Mariela Puga

Sobre la edad de punibilidad, y la reforma a la Ley Penal Juvenil.

20 de febrero de 2026

No entiendo suficiente de derecho penal, ni de política criminal o de seguridad. Sin embargo, arrimo mi lente constitucional para comentar lo que leí sobre el proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil. Y por ahí, para proponer otra perspectiva para pensar.

El proyecto que ya tiene media sanción, esta mostrando lo que podría nombrarse como la "magia-veneno" de nuestra República. Esa hermosa ambivalencia de los valores republicanos que legitiman la coacción, no como fuerza que causa dolor, sino como justicia pública sobre los miembros, libres e iguales, de una comunidad política.

Con este lente entiendo que podría NO ser constitucional hacer punibles a sujetos que, aunque imputables, no tienen iguales derechos políticos en nuestra comunidad. Pero para empezar habrá que decir que si la ley no prevé sus costos, y el financiamiento acorde, su aplicación va a estar en fuerte entredicho constitucional. Sobre estos dos asuntos, argumento aquí.

Entre lo dicho y lo hecho...

El asunto del régimen penal juvenil estuvo ardiendo en *La Crítica*. Aprendí mucho con el fenomenal ensayo de Sebastián Guidi, me preocupé bastante por la asimilación de la que advierte Roberto Gargarella, me hizo mucho sentido la apelación a la "justicia retributiva" de Tomás Fernández Fiks. "Veo en parte" lo que ellos ven, como diría Catupecu Machu, pero también noto algo implícito en sus argumentos, la contradicción "entre lo dicho y lo hecho" por los promotores de la reforma.



Nos prometieron "penas de adultos, para delito de adultos" (asimilación, para Gargarella). No sin insistir que "solo para *delitos graves*, como el homicidio" (siguiendo lo que piden las encuestas, según la hipótesis de Guidi). Sin embargo, los reformadores diseñaron y votaron un proyecto por el cual los adolescentes *no* tendrán la misma pena que los adultos, justo en los *delitos graves*; y, en cambio, serán excepcionalmente perseguidos (y en esto sí con las mismas penas), por los delitos leves que cometan. ¿Qué pensará Tomás F.F. de esta desigualdad retributiva en el castigo?

Si como cuenta Sebastián G., los menores podrían ser perseguidos con más ahínco que los mayores en ciertos casos, en los que se obliga al fiscal a hacerlo, y a la vez no pueden recibir una pena que sea mayor de 15 años (porque es el estándar constitucional que no pudieron evadir), entonces, la combinación es *puro veneno*: Más persecución a menores por delitos leves con penas de adultos, y los menores que cometen delitos graves, en cambio, no tendrán la misma sanción que los mayores.

"De lo oscuro hacia la luz", ejemplificaría con el menor que comete un homicidio, o cualquier

delito grave. Nunca podrá tener una condena de más de 15 años en prisión. De modo que armar chicos y mandarlos a matar todavía puede ser un buen negocio para el jefe narco, *certeris paribus* un adulto (si la razón para hacerlo fuera su menor punibilidad, como sostienen algunos). En cambio, siguiendo el ejemplo de Sebas, el adolescente de 14 años que falsificó su documento para entrar a un boliche, arriesga seriamente ir a la cárcel si además se le ocurre pintar un grafiti en la puerta del boliche. Y acá lo burdo del asunto: Dos tonterías juveniles usuales, se anteponen en la cartera de casos del fiscal cuando se acumulan, porque la ley lo dice. Decantarán condenas, no por su peso, sino por el orden de obligación que impone la nueva regla de persecución a la fiscalía. Me da la sensación de que la justicia retributiva anhelada, empezara a heder como injusticia distributiva.

Los finales abiertos

No me interesa denunciar la traición a las promesas de los reformistas. Lo que me preocupa son los efectos colaterales de la contradicción “entre lo dicho y lo hecho”. El más claro de esos efectos es el aumento de delitos leves en la cartera de casos del Ministerio Público Fiscal, y en los expedientes de Tribunales Penales. Ese aumento no es gratis ¿Qué pasa si no se asignan recursos extras a los tribunales penales para procesar a la nueva delincuencia adolescente?, y ¿al Ministerio Fiscal para perseguir de la forma indeclinable e irreflexiva que manda la nueva ley?, La implementación de esta eventual ley, sin recursos ¿arriesga empeorar la persecución penal a otros delitos?, ¿aumentará el retardo de la justicia penal en casos más graves? Parece claro que el asunto del financiamiento no puede faltar.

El Ministerio Público de la Defensa también sumará nuevos clientes sin secundario completo. ¿Se les dará los recursos necesarios a los defensores públicos para que los defiendan? Es previsible una **sobrecarga** de demanda sobre la defensa pública ¿está cuantificada y prevista por la ley? Es que cuando hay sobrecarga hay me-

nor calidad de asistencia legal, tanto para los nuevos clientes, adolescentes pobres, como para los usuarios habituales del sistema: imputados e imputadas de escasos recursos. ¿Cuánto puede esto aumentar la desigual aplicación de las leyes? ¿Cuánto una ley de la república puede debilitar a las bases igualitarias de esa república? El financiamiento no puede faltar.

En cualquier caso, los menores no podrán compartir espacios de encierro con mayores. Ya está dicho en la futura ley. Así que habrá que tener instalaciones específicas para recibir a los adolescentes y jóvenes penados con la privación de su libertad. ¿Se invertirá en nueva infraestructura e instalaciones especiales para cumplir con la regla? O, ¿caso se dejará que las Provincias sean las responsables de más incumplimientos de este tipo? (como lo han sido hasta ahora). Una ley de la democracia sin financiamiento, podría devenir en la ley de la selva para la adolescencia, ahora considerada delincuente.

Todo nuevo comienzo, no obstante, siempre puede verse como una nueva oportunidad. Aca-so ésta no será la oportunidad de revivir el viejo reclamo constitucional de que las cárceles deben servir para la rehabilitación y no el mero castigo. Siendo adolescentes los encarcelados la cosa retumba en nuestro sentido de justicia liberal: ¿se invertirá en infraestructura de servicios, en penitenciarios entrenados, profesionales adecuados para cumplir la aspiración de la constitución que no se cumplen con los mayores? Y aquí el asunto. Si no se invierte, la “causa” de los menores puede reverdecer el “litigio carcelario a gran escala”. Las ONG argentinas son de las mas entrenadas en esta litigiosidad. Re-empoderadas por las normas de protección internacional-constitucional de adolescentes, podrían abarrotar tribunales en menos de un año, con demandas por el sufrimiento de menores sin infraestructura de servicios adecuada para su rehabilitación. Sin financiamiento, el bardo va sobre el poder judicial, que tarde o temprano te lo va a cobrar.

Por último, es intrigante saber ¿cuál será la tecnología jurídica del gobierno para reglamentar esta ley? Probablemente una que considere el peligro razonable de que una medida cautelar suspenda la aplicación de la ley hasta tanto se aseguren los recursos. Es que el peligro en la demora en un caso así, es tan indudablemente grave, que pocos jueces estarían dispuestos a guardarlo en su cajón de responsabilidades. Recordemos esa "innovadora" carta jurídica que el gobierno puso a girar para no tener que implementar las leyes de discapacidad y de presupuesto universitario. Eso de que "una ley sin recursos asignados por el Congreso no se ejecuta." ¿Se le dará vuelta este argumento? Podrá decir ahora "yo ejecuto leyes sin presupuesto cuando quiero". O, si el congreso me dice que yo asigne recursos, "yo puedo no asignar nada". O, "esta ley no necesita recursos para ser aplicada." Intrigante...

Ojo que la hipotética medida cautelar podría ser la antesala de una acción declarativa de certeza, de las que te marcan la cancha. Una que busque determinar las condiciones financieras para que se pueda implementar una ley como esta. Y si un juez hiciera lugar a algo de esta lógica, ¿cuántos progresistas saltarán a deslegitimar la decisión, en base a la razón deliberativa del congreso? ¿Cuántos conservadores traicionarían su lealtad liberal al artículo 18 de la Constitución Nacional para adolescentes, reclamando deferencia en este caso?.

Pero si una decisión judicial indicara que se determinen racionalmente los mínimos de financiamiento para implementar esta eventual ley, quizás será el momento de preguntarse ¿Cuántas órdenes judiciales más puede seguir incumpliendo el ejecutivo? Todo suma señora, decía el almacenero cuando pasa la cuenta del fiado. ¿Cuántos flancos más puede abrir este gobierno sin pisar la cornisa de condenas penales por incumplimiento de sentencia? Qué importa! dirá alguno. Nunca se inició un juicio político por ese tipo de condenas. Sin embargo, esas condenas blandas son las que te esperan piolas, en la puerta de Casa Rosada, y te miran desde afuera,

como el personaje "el encargado" de Francella, esperando que se te debilite el apoyo político, o te quites la banda. Final abierto, si los hay...

Punibilidad e Imputabilidad

En serio no entiendo mucho de derecho penal. Por eso me cuesta entender la discusión acerca de si la reforma baja la edad de "imputabilidad", o lo que baja es la edad de "punibilidad". T. Fernández Fink parece sugerir que si fueras imputable, deberías ser punible (hacerte responsable). Sin embargo, como constitucionalista, la distinción entre imputabilidad y punibilidad me resuena como más relevante que la mera separación entre el género y la especie.

«Probablemente una que considere el peligro razonable de que una medida cautelar suspenda la aplicación de la ley hasta tanto se aseguren los recursos.»

Pensando en voz alta diría que la imputabilidad es una condición en relación al acto delictivo: "conocer la criminalidad del acto" *al momento* de realizarlo. Si el sujeto entendió lo que hizo cuando lo hizo, es imputable. Y si además el mismo sujeto fuera punible, se lo hará responsable de soportar el castigo por lo que hizo. Pero la punibilidad no puede ser nunca para el acto, es una condición político-jurídica (probablemente sea más complejo que esto, pero déjenme charlotear un rato, para abrir el debate hacia otro lado).

La responsabilidad del punible no es moral. No es responsabilidad por la justicia fenoménica. Si somos positivistas y constitucionalistas, debe tratarse de una responsabilidad jurídica, que presupone una responsabilidad política. Surge de la pertenencia plena a la comunidad política, que asume adhesión a sus reglas. Se es responsable ante esa comunidad. Digo, aunque la pena intenta restablecer la dignidad de la víctima, o sea

en solidaridad con ella (sus fines más loables), el autor del delito no responde ante la víctima, sino ante a su comunidad, por la violación de su compromiso con ella y sus reglas.

Es difícil seguir sosteniendo que los adolescentes de 14 años no comprenden la criminalidad de sus actos o que no son responsables de sus decisiones. No por la cantidad de delitos que cometen (menos del 2%), sino por la intensidad de la experiencia que tenemos en la interacción con ellos (aunque esta no sea cuantitativamente relevante).

- Hay adolescentes que asesinaron de forma sangrienta, y la escena mella nuestra percepción de su supuesta inmadurez y falta de responsabilidad en sus decisiones. Quizás no esté bien que sea así, que el drama o que nuestro instinto retributivo nuble nuestra percepción de las condiciones generales de su autonomía, pero así parece funcionar. Y así se activan las leyes de la república.
- Los adolescentes manejan mejor que los adultos las nuevas tecnologías, las que hoy gobiernan el mundo. En esa posición de poder frente al adulto, el que se va sintiendo cada vez más desfasado y desventajado frente al cambio tecnológico, es difícil que conciba a los adolescentes tan vulnerables o dependientes como antes.
- Los adolescentes son cada vez más independientes del poder tutelar de sus padres. El código civil les reconoce desde el 2015 una autonomía progresiva para decidir sobre asuntos importantes de su personalidad, y para defenderse frente a la autoridad parental arbitraria. Los vemos conducir, pagar la cuenta, manifestarse en las calles. Parece inconsistente sostener la presunción general de su inimputabilidad y su autonomía progresiva a la vez.
- Los adolescentes pobres, que **son los más**, dependen materialmente cada vez menos de sus padres. Más tempranamente salen a ganarse

la vida, y a exponerse a una independencia espiritual precoz y a veces destructiva.

En fin, las condiciones sociales cambian, y con ellas, nuestra percepción de los más jóvenes. Así, la regla que los hace inimputables de forma general, y que se asienta en la presunción de su falta de entendimiento y autonomía de decisión, se percibe ahora, injusta, y asentada en una presunción falsa. En este contexto, quizás no el ideal, la república permite activar el sentido de justicia retributiva al que apela F. Fink.

Sin embargo, tiendo a creer que hay un salto lógico-jurídico entre reconocer su inimputabilidad y pretender su punibilidad. Nosotros, la comunidad política argentina, podemos dejar atrás la presunción de inimputabilidad de los adolescentes, de la misma manera que la creamos. Así funcionan los cambios en nuestra república. Pero lo que NO podemos, es hacerlos punibles sin que sean parte activa de la comunidad política. Ellos no son responsables ante nosotros, a menos que garanticemos sus derechos políticos. Sobre esta idea, cierro esta nota.

No hay autoridad punitiva sin comunidad política

Ya editaba estas notas, cuando me tope con la frase de Máximo Lanusse: *“Toda autonomía supone vulnerabilidad y toda autoridad, comunidad”*. (La nota de Máximo **no tiene desperdicios**).

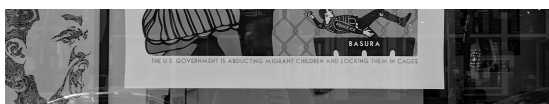
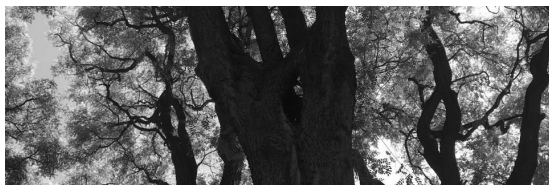
Desde esta idea propongo que intentemos entender el principio de legalidad penal, fundante del castigo. Este principio no se apoya en el amor a la seguridad jurídica o el erotismo del formalismo jurídico. Se asienta en la legitimidad política que le atribuimos a las leyes democráticas. Es, en fin, la autoridad legítima de una república.

Entiende que la potestad coactiva del Estado supone el ejercicio de un monopolio “legítimo” sobre su *constituency*, y no un monopolio arbitrario de la fuerza sobre cualquiera. Estas son las bases del constitucionalismo republicano (una redundancia, para quienes piensan que todo constitucionalismo es republicano).

Así, estamos obligados a pagar impuestos porque podemos votar a los miembros del Congreso que los crea y que podría modificarlos. Se presume la legitimidad de lo que nos cobran, porque podemos votar a quién será jefe/a de la administración, el/la que los cobra y los gasta en nuestro nombre. El constitucionalismo moderno se inició con una sangrienta revolución en nombre de *"no tax without representation"*.

Del mismo modo, somos responsables y sufrimos castigos penales porque podemos votar a quienes crean y modifican las leyes penales. Podemos elegir al/la jefe/a de la coacción penal, y lo lindo del asunto, es que el o ella ejerce su jefatura en nuestra representación, y en nuestro interés. Somos también libres de intentar que nos elijan como representantes para cambiar y/o ejecutar esas leyes. Esta es la magia del republicanism, que hace de la fuerza y la pena una forma de justicia.

Ya en la Francia revolucionaria del siglo XVIII, Olympe de Gouge reclamaba que *"si la mujer puede subir al cadalso, también debe tener el derecho de subir a la tribuna."* Ella sólo pedía el derecho político a la libertad de expresión, y por eso la subieron al cadalso. Hoy sabemos, porque el sentido de la historia nos impacta, que "no hay responsabilidad política-jurídica sin derechos políticos". Por eso, no basta la imputabilidad para ser punible. La punibilidad también requiere de responsabilidad política, esa que se adquiere con la ciudadanía política plena.



Creo que una vez que reconocemos madurez, entendimiento y autonomía en sus decisiones a los adolescentes, les estamos reconociendo la misma autonomía requerida para ser responsables ante su comunidad. Pero si su comunidad los proscribiera de lo político, no son responsables ante ella, sino subyugados por ella.

Hasta el día hoy los adolescentes de 14 años no pueden votar porque los consideramos aún demasiado inmaduros e irresponsables para una decisión tan importante. Su autonomía está en desarrollo, decimos. Esta es la misma generalización en la que se asienta la regla de inimputabilidad que la nueva ley intenta cambiar. Solo que en materia de derechos políticos, ella determina la restricción del derecho al sufragio (hasta los 16 años), de la competencia política para ser diputados (hasta los 25 años), o para ser senador, presidente (hasta los 30 años).

Ahora, si cayera la presunción de inmadurez e irresponsabilidad en el sistema penal, ¿cómo se seguiría sosteniendo ella en el sistema político? Sin presunción de falta de autonomía, los adolescentes son habitantes ilegítimamente proscritos. Y mientras estén proscritos, no son punibles, sólo son el objeto de fuerza ilegítima.

Si queremos aplicar "nuestra" ley penal y fiscal a los adolescentes, asignándoles madurez y responsabilidad suficiente para entenderla, pero no le permitimos que voten o sean elegibles como representantes, estamos sabotando el mágico poder de nuestra república con una ley envenenada. ■

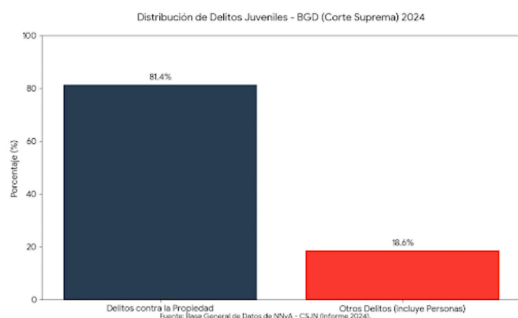
«Es que el peligro en la demora en un caso así, es tan indudablemente grave, que pocos jueces estarían dispuestos a guardarlo en su cajón de responsabilidades.»

La penalización de la biografía

por Adriana Soria

Justicia y supervivencia en el abismo económico.

27 de febrero de 2026



Argentina atraviesa una paradoja institucional alarmante. Mientras los indicadores sociales revelan una crisis de proporciones inéditas —con índices de pobreza infantil que ya alcanzan a siete de cada diez niños y una canasta básica inalcanzable incluso para el trabajo formal—, el debate legislativo parece obsesionado con una respuesta única: el endurecimiento del sistema penal juvenil. El reciente consenso parlamentario para fijar la edad de punibilidad en los 14 años se presenta como una solución de seguridad, pero un análisis profundo revela que estamos ante un intento de gestionar la miseria mediante el Código Penal.

Sociología del castigo: El chivo expiatorio en la crisis

No es casual que esta reforma cobre fuerza cuando el tejido social se desgarrar y la mortalidad infantil vuelve a ser una preocupación creciente. Cuando el Estado retrocede en su capacidad de garantizar derechos básicos, avanza con su brazo penal para disciplinar las consecuencias de su propio abandono. Como sostiene la antropóloga Rita Segato, la violencia muchas veces funciona como un “lenguaje” en contextos de exclusión; responder a ese lenguaje solo con el

encierro es negarse a entender la gramática del conflicto. Se pretende “corregir” con la cárcel lo que no se garantizó con la alimentación y la escuela.

Desde la neurociencia, la pregunta sobre la utilidad de penalizar a edades tan tempranas tiene una respuesta técnica clara. A los 14 años, el cerebro se encuentra en una etapa de “remodelación” crítica, donde la corteza prefrontal —responsable del control de impulsos y la planificación— aún no ha completado su desarrollo. Someter a un joven en esta etapa a la lógica del encierro punitivo no resocializa una identidad en formación; la fractura.

El muro de la Convención y la ficción de la neutralidad

En el plano jurídico, la reforma camina sobre una cornisa de inconstitucionalidad. El Principio de No Regresividad (Art. 26 de la CADH) actúa como un cerrojo: el Estado no puede desandar el camino de protección ya reconocido sin una justificación empírica. Los datos de la propia Base General de Datos de la Corte Suprema (BGD) desmienten la “emergencia”, al mostrar sistemáticamente que la participación de menores de 16 años en delitos graves es marginal, concentrándose el grueso de las causas en delitos contra la propiedad.

Jurídicamente, es imperativo advertir que esta reforma nace con una hipoteca de inconvencionalidad casi insalvable. Al perforar el piso consolidado de los 16 años, el proyecto colisiona frontalmente contra la jurisprudencia internacional: desoye al Comité de los Derechos del Niño, que en su Observación General N° 24 insta explícitamente a los Estados a no reducir la edad

mínima bajo ninguna circunstancia, y violenta el mandato de progresividad del sistema interamericano. Estamos, pues, ante una ingeniería legislativa diseñada para el impacto político coyuntural, pero construida con pies de barro en el plano del derecho internacional de los derechos humanos, destinada a naufragar ante el primer control serio de convencionalidad.

Reducir la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años es una confesión de fracaso estatal; es admitir que las políticas de prevención primaria han claudicado. La jurista Mary Beloff advierte constantemente sobre esta “ilusión penal”: creer que el sistema punitivo puede solucionar problemas estructurales. A su vez, como señala Alda Facio, la pretendida neutralidad de la ley penal es una ficción: un sistema que penaliza por igual sin considerar la asimetría de origen — donde el hambre y la exclusión han marcado la biografía— es, por definición, violento.

Aquí cobra relevancia la perspectiva de Mariela Puga, quien nos advierte sobre el peligro de una “justicia remota” que solo aparece en los barrios para castigar, perdiendo toda legitimidad democrática ante la comunidad. Una justicia efectiva debe ser una justicia de proximidad, capaz de entender el tejido social del territorio y actuar como un remedio estructural. Penalizar la biografía de un adolescente sin proponer una

transformación de sus condiciones de vida es vaciar la función judicial de su sentido más profundo: la resolución real del conflicto.

Conclusión: El deber de no abandonar

Frente a la retribución ciega, la Justicia Restaurativa surge como la única respuesta estratégica. Siguiendo la “Ética del Cuidado” de Carol Gilligan, debemos mover el eje: pasar de la pregunta sobre qué castigo corresponde, a la pregunta sobre quién fue dañado y cómo podemos reparar ese vínculo roto. La verdadera “respuesta ágil” no es el encierro temprano, sino los mecanismos de Remisión que obligan al adolescente a enfrentar la consecuencia humana de sus actos, fomentando una responsabilidad activa que la cárcel nunca podrá generar.

La verdadera seguridad ciudadana no se construye con el sacrificio de la infancia en el altar de la demagogia punitiva. El Estado tiene la obligación ética y legal de generar políticas de cuidado antes de activar su maquinaria sancionatoria.

“Porque la justicia, si no es una pedagogía de la esperanza, termina siendo el mordisco que el poder reserva para los descalzos; transformar esa indignación en un ‘inédito viable’ es el único camino para que el Estado deje de ser el eco de su propio abandono”

«Cuando el Estado retrocede en su capacidad de garantizar derechos básicos, avanza con su brazo penal para disciplinar las consecuencias de su propio abandono.»



Historia Mínima del rock en América Latina

por Abel Gilbert · Pablo Alabarces

Sobre las posibilidades de una historia del rock. Tramas y límites.

3 de febrero de 2026

Construir una historia del rock en América Latina implica un problema que se reitera en cada intento de *latinoamericanizar* la narrativa o el análisis de un fenómeno: la pregunta sobre su mera existencia. Sabemos que existió algo a lo que podemos llamar *música rock* en toda América Latina —con dificultades para definirla, como veremos; pero son dificultades mucho más ligadas a su amplitud y abundancia, a su extensión temporal y geográfica, que a su escasez—. Sabemos, también, que esa producción musical, y a la vez poética, está asociada a movimientos ampliamente culturales y generacionales —que, también, se definieron como francamente contraculturales y se construyeron, simultáneamente, como contra-generacionales: movimientos juveniles, enfrentados al mundo adulto; el tenor de ese enfrentamiento es un punto clave para analizar—. Sin embargo, nunca ha sido estudiado el modo en que, si así ocurrió, esos lenguajes se pusieron en movimiento a través del continente: de qué maneras, en qué direcciones, con qué acentos y con qué lenguas.

Esa mescolanza parece contradecir la posibilidad de construir historias estrictamente locales: sin el diálogo que las músicas entablaron, una historia meramente local es fatalmente incompleta —incluso la argentina, que se autopercebe y se autopresenta como autosuficiente, como discutiremos—. Y ese recorrido ocurre casi desde el mismo momento en que se grabó “Rock around the clock” y se difundió por todo el con-

tinente entre 1954 (la grabación de Bill Haley), 1955 (la grabación de Nora Ney en Brasil), 1957 (la grabación del argentino Eddie Pequenino y sus Rockers) y 1958 (la grabación de la mexicana Gloria Ríos) — si aceptamos esa canción y su puesta en escena en los títulos del filme *Blackboard Jungle*,* de 1955, como un punto de partida consensuado.



(Ese consenso, sin embargo, no ha reparado en que dos de las tres primeras grabaciones de rock en América Latina fueron interpretadas por mujeres. Como veremos, la ignorancia frente al rol de las mujeres en el rock no es para nada distinta a la que impera en otras áreas de la vida latinoamericana).

Una trama (pero no un catálogo)

Una historia del rock en América Latina, entonces, puede ser escrita, pero sólo si se organi-

za en la explicación de una trama, antes que en “historizar” una larguísima lista de discos, autores, intérpretes. Larguísima y fatalmente incompleta: sólo un mapa de China del tamaño de China podría dar cuenta de todo lo que se presentó, escuchó, escribió o simplemente percibió como “rock” en toda América Latina desde finales de los años 50.

La hipótesis que organiza esta historia, entonces, es que el rock latinoamericano se despliega en procesos de modernización truncos y en relación con estados de excepción políticos. En todos los casos *nacionales* es notorio un momento epigonal inicial, una invención ligada a la reproducción de la escena *rocker* iniciada en torno a Elvis Presley en los EE.UU.: lo que el historiador estadounidense Eric Zolov llamó el *Refried Elvis*, los refritos de Elvis. Pero, luego, el desarrollo de cada escena del rock está en profunda conexión con los modos de modernización de esas sociedades a lo largo y ancho del desarrollismo de los años sesenta, modernizaciones contradictorias, variadas, *electrónicas* (según afirmara José Joaquín Brunner) o híbridas (siguiendo la categoría popularizada por Néstor García Canclini).

Los que los finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta pusieron en juego a través del rock & roll fue, como es bien sabido, una serie de imaginarios y otra serie de datos económicos. Entre los primeros, la invención de la juventud como actor social, político y cultural; entre los segundos, la invención de la juventud como sujeto de consumo, al que se podía dedicar una parte, incluso importante, del mercado de bienes materiales y simbólicos. Autos, ropas, filmes o discos, todo formaba parte de los nuevos productos especialmente pensados para su consumo masivo por los y las jóvenes, incluso cuando no estuvieran incorporados al mercado productivo —pero sí sus padres—. La velocísima adquisición e incorporación de estas novedades en los países latinoamericanos se explica por varias razones: la primera es la difusión de la industria cultural a través del cine y la radio —los discos extranjeros estarían reservados, durante

mucho tiempo, a los grupos de alto poder adquisitivo o con acceso a los viajes internacionales—, pero junto a ella es decisivo el impacto de la fantasía modernizadora. América Latina se percibía como un continente atrasado, rural, tradicional —una percepción compartida por sus elites y por sus clases populares—. Modernizarse, entonces, fue el imperativo del momento.

La fricción rockera con la fracción de izquierda



Por eso, esta historia postula una suerte de segunda hipótesis: la de una reiterada fricción del rock con las izquierdas continentales, tanto las educadas en los mandatos del realismo cultural soviético como las seducidas por la experiencia de la Revolución Cubana. El castrismo provoca ondas tectónicas en la región. Se podía llegar al socialismo saltando etapas. Es en la isla donde se configura un modo de recepción del rock que, con mayor o menor reconocimiento de sus argumentaciones condenatorias, se replicó hacia el sur. El recelo de las izquierdas hacia el rock se extiende en América Latina hasta el final de las transiciones democráticas en los años ochenta del siglo pasado, donde pueden aparecer ciertas aproximaciones —o, incluso, el desplazamiento de esas izquierdas a manos de movimientos juveniles despolitizados—. Como veremos, el rock latinoamericano se cuida, en general, de ser capturado por los protocolos de la Guerra Fría: le concede ese privilegio a la canción de protesta,

aunque a veces coquette, ocasionalmente, con ella —con más franqueza, hacia el final de las dictaduras y el inicio de los procesos de transición, ya cuando ninguno de los dos (ni el rock ni la protesta) son los mismos—. Lo suyo es, fundamentalmente, una paradoja que no se organiza políticamente: ser una crítica a la cultura de masas creada en el centro de la cultura de masas y sin tener otra aspiración que ser cultura de masas. En ese lugar y esa aspiración, el rock afirma que “rompe estructuras”, pero no se asume como insurreccional, sino sólo como contravencional: el corte de cabello y una noche o dos en una cárcel es suficiente.

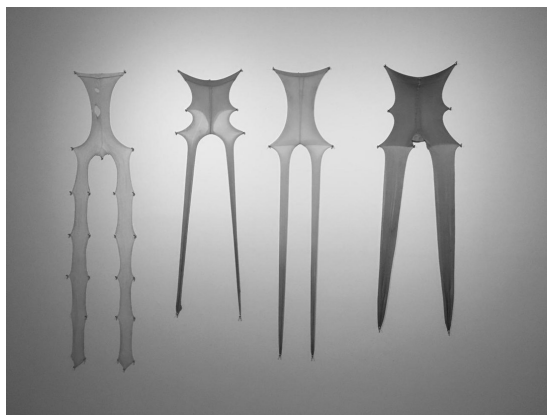
El martirio en 1973 de Víctor Jara, figura central de la Nueva Canción chilena, pero con sus simpatías y entreveros con el rock de su país, funciona como alerta, antes que como modelo; como límite, no como posibilidad. Lo mismo ocurre con el encarcelamiento, en 1967, de los brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil: se trata de situaciones excepcionales que definen una posibilidad que será minuciosamente evitada —y por

eso mismo, no repetida—. Quince años más tarde, los distintos rocks nacionales podrán construir, sin ninguna vergüenza o pudor revisionista, hagiografías autobiográficas y geográficas que insistan sobre una resistencia que no se verifica en demasía; cuarenta años después, ese relato puede consagrarse como leyenda y como documental de Netflix. Pero los propios narradores, esas voces “nativas” de los rockeros —¡todos hombres, para colmo!—, ya se han transformado en rockstars, en estrellas del espectáculo; han sido actores de dramas políticos que no reclamaron su martirio, o que supieron apartarse a tiempo de su posibilidad.

Esta es, entonces, una historia descentrada, que no sólo no comienza en Buenos Aires, y que ni siquiera comienza en el continente, sino en las islas. Después de todo, hay cierto consenso en las historias políticas latinoamericanas en que, para hablar de la cultura en la década de 1960, hay que comenzar por La Habana en 1959. No tenemos por qué transgredir ese acuerdo. ■

«Una historia del rock en América Latina, entonces, puede ser escrita, pero sólo si se organiza en la explicación de una trama, antes que en “historizar” una larguísima lista de discos, autores, intérpretes.»

«Sin embargo, nunca ha sido estudiado el modo en que, si así ocurrió, esos lenguajes se pusieron en movimiento a través del continente: de qué maneras, en qué direcciones, con qué acentos y con qué lenguas.»



La degradación constitucional de Estados Unidos

por Irwin Stotzky

Las instituciones que se suponía que debían restringir el poder, proteger los derechos y prevenir los abusos no solo están fallando, sino que se están derrumbando a la vista de todos

6 de febrero de 2026

Lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos no es una crisis constitucional. Es la desintegración abierta del gobierno constitucional. Las instituciones que se suponía que debían restringir el poder, proteger los derechos y prevenir los abusos no solo están fallando, sino que se están derrumbando a la vista de todos y, en algunos casos, allanando activamente el camino para el dominio ejecutivo. Los asesinatos de dos civiles desarmados por parte de agentes del ICE no son aberraciones. Son la prueba más clara posible de que el monopolio de la fuerza por parte del gobierno federal se ha escapado del alcance de la ley, la supervisión o el control democrático.

En ambos asesinatos, los agentes federales dispararon a civiles desarmados que no representaban una amenaza inminente. No se trató de accidentes imprevisibles. Fueron el resultado previsible de un sistema federal de aplicación de la ley al que el Congreso, los tribunales y la cultura política le han dicho que no tendrá que rendir cuentas. Cuando el Estado puede quitar una vida y el sistema responde con silencio, el estado de derecho no solo se debilita. Muere.

El Congreso tiene la responsabilidad directa de esta muerte. Se ha convertido en la legislatura más temerosa y auto-neutralizada del mundo democrático. Ante el uso represivo del poder ejecutivo, las prácticas abusivas de aplicación de la ley y el asesinato de civiles por parte de agentes federales, el Congreso no hace nada. No legisla restricciones. No ejecuta citaciones. No lleva a cabo una supervisión significativa. No utiliza las asignaciones presupuestarias para frenar el abu-

so de poder del presidente. No defiende su propia autoridad constitucional. Ha renunciado a su función de control de tal manera que ya no se comporta como un poder del Estado en igualdad de condiciones. Se comporta como un observador asustado, que ve cómo se producen los abusos y espera no ser visto. Según informes de principios de 2026, el Congreso, a través de una importante ley de política fiscal y de inmigración, asignó 75 000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante cuatro años. Esta financiación forma parte de un paquete más amplio de 170 000 millones de dólares destinado a la aplicación de la ley de inmigración, de los cuales los 75 000 millones destinados específicamente al ICE suponen un aumento significativo y, a menudo, se denominan «fondo para sobornos». El ICE es el grupo que mató a los dos civiles inocentes en Minnesota.

El Tribunal Supremo ha ido aún más lejos. En un momento en que el país necesita desesperadamente un poder judicial dispuesto a articular límites, defender derechos y frenar los abusos de poder, la mayoría conservadora del Tribunal ha adoptado doctrinas que concentran el poder en la presidencia y vacían de contenido cualquier otro control. Su jurisprudencia sobre la «teoría del ejecutivo unitario» ha desmantelado las restricciones internas al poder ejecutivo, ha debilitado la supervisión independiente y ha ampliado el control presidencial sobre el Estado administrativo.

Y luego llegó la decisión sobre la inmunidad.

En ese fallo, el Tribunal sostuvo que un presidente goza de una inmunidad total frente al enjuiciamiento penal por acciones consideradas «oficiales». La decisión sitúa efectivamente amplias categorías de conducta presidencial fuera del alcance del derecho penal. Crea una presidencia que puede ordenar, dirigir o autorizar acciones que llevarían a cualquier otro ciudadano a la cárcel, y hacerlo sin temor a ser procesado. Académicos, comentaristas políticos y amplios sectores de la ciudadanía de todo el espectro ideológico han advertido que esta sentencia otorga al presidente algo parecido a la invulnerabilidad legal mientras ocupa el cargo e, incluso, potencialmente después de dejarlo.

Es irrelevante si los jueces pretendían este resultado, que claramente sí. Las consecuencias de su decisión son inequívocas: un presidente envaletonado por saber que el derecho penal no puede tocarlo fácilmente. Un presidente que puede poner a prueba los límites del poder sin temor a ser acusado. Un presidente que puede tratar la maquinaria del Estado como un instrumento personal, protegido por una doctrina que eleva los «actos oficiales» por encima de la rendición de cuentas.

Esta postura judicial tiene consecuencias reales y letales. Cuando el Tribunal señala que el presidente está aislado de la rendición de cuentas, envaletona al poder ejecutivo. Cuando debilita los controles internos del Estado administrativo, empodera a las agencias federales para que actúen sin temor a la supervisión. Cuando restringe la legitimación, limita la revisión judicial o evita los casos que exigen claridad, deja al público indefenso ante los abusos de poder. Los asesinatos cometidos por agentes del ICE no están desconectados de este entorno legal. Son el punto final lógico del mismo.

Todo esto se desarrolla ante un público que está fracturado. Muchos estadounidenses quieren justicia, responsabilidad y el restablecimiento de las normas constitucionales. Pero una parte considerable de la población se ha vuelto abiertamente hostil al liberalismo, al pluralismo, a la restricción institucional, a la idea de que el po-

der del gobierno debe estar limitado por la ley. Esta hostilidad crea un entorno político en el que los abusos de poder no solo se toleran, sino que se celebran. Cuando una sociedad no puede ponerse de acuerdo en que el asesinato de civiles desarmados es inaceptable, el Estado de derecho se vuelve imposible de mantener.

Su referencia a la Carta Magna es un recordatorio de lo que se pretendía lograr con el constitucionalismo: la subordinación del poder a la ley. Pero la experiencia estadounidense actual demuestra que ningún texto constitucional, por muy venerable que sea, puede imponerse por sí mismo. Las instituciones deben actuar, y no lo están haciendo. El Congreso ha abandonado su función de control. El Tribunal Supremo ha adoptado doctrinas que concentran el poder en la presidencia. Las agencias federales operan con una discreción letal. Y la opinión pública está dividida entre quienes exigen justicia y quienes rechazan los principios liberales que la hacen posible. Todos estos desastrosos resultados forman parte de los planes de este presidente para maximizar su poder y tomar represalias contra cualquier persona o institución que considere que le ha insultado. Es una figura política extremadamente peligrosa.

El desánimo que muchos sentimos no es un signo de debilidad. Es una señal de que todavía creemos en la promesa del constitucionalismo. La lucha entre el poder y la ley no ha terminado. Se está desarrollando ahora, en los tribunales, en el Congreso, en las calles y en la conciencia pública. Si Estados Unidos podrá renovar sus compromisos constitucionales, o si continuará por el camino de la erosión institucional, sigue siendo una pregunta sin respuesta. Pero nombrar claramente la crisis es el primer paso para enfrentarla.

Si el «pueblo» luchará por sus derechos o capitulará ante la destrucción absoluta del sistema democrático es una pregunta sin respuesta. Pero creo que la organización política y las manifestaciones públicas masivas acabarán imponiéndose. ■

Presentación y crítica de las "Major Questions Doctrine"

por Roberto Gargarella

Ante el fallo de las tarifas, contra Trump, un examen crítico de su principal fundamento: las "Major Questions Doctrine"

21 de febrero de 2026

Presentación y crítica de la Major Questions Doctrine, a partir del fallo *Learning Resources, Inc. v. Trump*

De la doctrina de la non-delegation a la de la major questions

En el reciente caso sobre los aranceles establecidos por Trump -“*Learning Resources, Inc. v. Trump*”, del 20 de febrero de 2026- la Corte norteamericana sostuvo que la mayoría de los aranceles fijados por el Presidente norteamericano en el último año son inconstitucionales. La mayoría de la Corte (en un fallo 6-3, liderado por el Juez Roberts) afirmó lo propio a través de un fallo en donde invocó, centralmente, el principio de la división de poderes y, para su sostén, la fortalecida doctrina de las “cuestiones mayores”. En lo que sigue, quiero presentar esta renovada doctrina, y luego examinarla críticamente, desde una perspectiva informada por una visión dialógica de la democracia. Desde esta visión, sostendré que hay muy buenas razones para recortar los poderes del Presidente (acompañando, entonces, al fondo del fallo), pero no, justamente, las expuestas por la Corte.

Comienzo con algunas notas breves sobre la decisión del caso. En el fallo *Learning Resources*, el presidente de la Corte, Roberts, acompañado principalmente por los jueces Gorsuch y Barrett, sostuvo que la norma de emergencia en cuestión, la *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) no autorizaba claramente al Presidente a imponer aranceles, dado que el Congreso nunca había dicho que la regulación de emergen-

cia incluía la autoridad de establecer tarifas. El fundamento principal de la decisión mayoritaria fue la *Major Questions Doctrine* (MQD), a través de la cual se sostuvo que los aranceles eran una cuestión de relevancia económica “mayor”, y que por lo tanto requería una “clara autorización legislativa”, antes de que el Ejecutivo pudiera actuar. Por lo demás -agregó Roberts en su fallo- otras normas arancelarias previas se habían ocupado de autorizar explícitamente tales tarifas, algo que la IIEPA no había hecho (lo cual robustecía las razones en contra de la decisión presidencial). El juez Gorsuch, en particular, acompañó la opinión de Roberts con una muy extensa opinión (46 páginas) en donde se exployó sobre el principio de la separación de poderes, la doctrina de la “no-delegación”, y el principio de que el Congreso no puede delegarle poderes legislativos a las demás ramas de gobierno. Las jueces Kagan, Sotomayor y Jackson participaron también de la decisión mayoritaria, aunque disintiendo con la línea argumentativa principal (las MQD) según veremos.

«Recién bajo la dirección del Justice Roberts, la Corte de los Estados Unidos comenzó a hacer un uso frecuente y sistemático de la doctrina.»

La *Major Questions Doctrine* puede verse como un nuevo principio interpretativo utilizado por

la mayoría conservadora que hace años domina la Suprema Corte de los Estados Unidos, para combatir al “Estado regulador.” Utilizada explícitamente por el tribunal, por primera vez, en *West Virginia v. EPA* (2022), la fórmula dice que cuando una agencia ejecutiva asume una amplia autoridad sobre una cuestión de “vasto significado económico o político”, la misma debe contar con una clara autorización por parte del Congreso. Si esa autorización no se encuentra, los tribunales pueden bloquear la acción ejecutiva -invalidar la norma.

La MQD implica, desde hace años, un nuevo y exitoso intento destinado a revivir la moribunda “doctrina de la no-delegación” (non-delegation doctrine), que prevaleciera en los Estados Unidos durante el largo período conservador que tuviera su coronación con el fallo *Lochner*, y que llegara a su final en 1935/1937. Durante ese período conservador, la Corte apareció como la principal oposición al nacimiento y consolidación del “New Deal” de Roosevelt, sosteniendo que el Congreso no podía delegar sus poderes al Presidente. Como sabemos, la Corte terminaría por abdicar de esa batalla, luego de la amenaza de Roosevelt de ampliar el número de sus miembros. El enfrentamiento culminó con la Corte poniendo en marcha un nuevo estándar (el “*intelligible principle test*”), conforme con el cual la delegación debía considerarse válida en la medida en que el Congreso proveyera un “principio inteligible” para guiar la acción de la agencia.

La MQD implicó, medio siglo después de aquella “batalla perdida” por los conservadores, un ardoroso renacer de la disputa, contemporáneo con la nueva hegemonía que la derecha jurídica iba alcanzando, otra vez, en el tribunal supremo. La idea de *major questions* había aparecido, por primera vez, en un artículo doctrinario escrito por el liberal Stephen Breyer, en 1986, antes de su pasaje por la Corte Suprema (1994-2022). Sin embargo, prontamente, la idea se convirtió en doctrina, y fue apropiada por círculos conservadores orientados a dotar de fundamentos a la agenda desreguladora de la primera presidencia

de Trump. Recién bajo la dirección del Justice Roberts, la Corte de los Estados Unidos comenzó a hacer un uso frecuente y sistemático de la doctrina. Notablemente, la doctrina de las “cuestiones mayores” apareció articulada bajo el principio de la separación de poderes: la idea era que ninguna rama de gobierno debía asumir como propias tareas que la Constitución había reservado a otras ramas

Inicialmente, la doctrina pudo verse como un embate jurídico directo frente al legado del fallo *Chevron*, de 1984 -fallo celebrado por autores liberales como Cass Sunstein- que había establecido un criterio general de “deferencia” hacia las agencias de gobierno. Según este criterio, los tribunales federales debían “deferir” al razonable criterio de las agencias reguladoras la interpretación de las leyes de delegación ambiguas. En un principio, según el propio criterio de Sunstein, la Corte conservadora puso en marcha una versión moderada de la doctrina (“*Chevron carve-out*”), en donde las *major questions* aparecieron como una excepción frente al establecido principio general de “deferencia.” Sin embargo, con el paso del tiempo, y a través de una serie de casos (*West Virginia v. EPA*; *NFIB v. OSHA*; *Alabama Ass’n of Realtors v. HHS*; *Biden v. Missouri*) la excepción se transformó en una regla fuerte: la exigencia de afirmación manifiesta. Así, pasó a sostenerse que la ley debía autorizar expresamente a la agencia el ejercicio de su pretensión regulatoria. Ahora, entonces, la idea es que la Corte directamente prohíbe a las agencias que interpreten las leyes ambiguas como concediéndoles autoridad regulatoria sobre el sector privado. (Nota: Conviene subrayar que la MQD ha venido muchas veces de la mano con el uso de los “expedientes de emergencia” o “expedientes en las sombras” (*shadow dockets*) a través de los cuales la Corte (sobre todo, desde 2017) emite órdenes de emergencia (como suspensiones o mandatos) salteándose los meses de argumentos orales o escritos propios de los procesos ordinarios. Así, en casos como los relacionados con el mandato de vacunación contra el COVID-19, o

las moratorias de desalojos, la Corte recurrió a estas órdenes de emergencia, para sostener que se trataba de "cuestiones mayores" que las agencias no estaban facultadas para decidir por sí solas).

Para el ala liberal del derecho norteamericano -la que defiende al "estado administrativo", la deferencia hacia la experiencia de las agencias reguladoras, la flexibilidad en el manejo de asuntos complejos que el Congreso no puede prever- la MQD aparece como una directa afrenta. Se trata, según ellos, de un instrumento político a través del cual los conservadores buscan limitar las acciones del gobierno en temas como el cambio climático, la salud, o la regulación económica. Ellos no ven un fundamento constitucional adecuado para la doctrina; y entienden que sus defensores no han provisto a la misma de una definición objetiva acerca de lo que significa una *major question*. Todo ello (les) permite una aplicación inconsistente de la doctrina; y un creciente "activismo judicial" conservador, contra la política democrática. Adviértase, por ejemplo, que Brett Kavanaugh (uno de los tres jueces que votó a favor de Trump en el caso de las tarifas, y que el presidente norteamericano elogió por ello) supo definir a la doctrina, en su audiencia de confirmación para llegar a ser juez de la Corte, como un principio "know-it-when-you-see-it" ("lo sabemos cuando lo vemos").

Por lo dicho, no extraña que la jueza Elena Kagan -quien firmara con la mayoría "*Learning Resources, Inc. v. Trump*"- adhiriera a la conclusión del fallo mayoritario afirmando, a la vez, que para hacerlo no se necesitaba recurrir a la MQD. Junto con las juezas Sotomayor y Jackson, ella sostuvo que bastaba con el uso de las herramientas tradicionales de la interpretación constitucional (lectura textual, análisis de la historia legislativa, etc.) para decidir el caso (Jackson, en particular, hizo referencia a la historia legislativa). Para ella, la MQD es una invención sin base constitucional, destinada a limitar a la rama ejecutiva, antes que un método legítimo de interpretación constitucional; y además una ma-

nera de transferir poder, desde el Congreso y las agencias administrativas, hacia la Corte Suprema -ello, para permitir que esta última invalide regulaciones legítimas (por lo mismo, ella critica el uso que la mayoría conservadora ha hecho de la MQD para apoyar los "expedientes de emergencia" o "shadow dockets").

Algunas notas críticas sobre la MQD

Son muchas las cuestiones que pueden presentarse en crítica de la nueva doctrina de la Corte. Sintéticamente, diría que la misma es objetable por tradicionalista; rígida; dirigida a fortalecer injustificadamente los poderes de la Corte (y así, una lectura vieja y conservadora del *judicial review*, como la que primara en la era de la *non-delegation doctrine*); que se basa en una noción perimida y absurda del principio de separación de poderes; que es insensible al contexto; y poco atenta a la democracia. Me detengo brevemente en estas consideraciones.

Ante todo, subrayo lo obvio y ya expuesto en las páginas anteriores. Estamos ante una herramienta interpretativa inventada por la Corte, que le sirve fundamentalmente a ella, para recuperar poder de decisión frente a las ramas "más democráticas" del poder, sobre todo, gracias al carácter arbitrario del parámetro que utiliza (una fórmula del tipo "lo sé cuando lo veo"). La idea de las "cuestiones mayores" es altamente indeterminada, y por lo tanto apropiada para su uso discrecional por parte del tribunal. El mismo parece decir: "cuando no me gusta la decisión regulatoria la anulo, invocando una cuestión mayor, pero cuando me gusta no la uso, o la uso para afirmar la decisión del caso". En lo personal, tengo pocas dudas de que un principio semejante (las "cuestiones mayores") podría haberse utilizado provechosamente (y a partir de un razonamiento similar) para invalidar las detenciones arbitrarias dispuestas por el Ejecutivo, a través de su política y policía inmigratoria -ICE- que actúa de modo irrespetuoso de los derechos, sin identificaciones, con el rostro cubierto, y siempre con excesiva violencia. Sin embar-

go, en lugar de ello, la Corte ha usado a su gusto la doctrina, para invalidar las regulaciones que le desagradan (COVID, cambio climático, ahora tarifas).

La doctrina se basa, además, en una noción algo sorprendente del principio de la “separación de poderes”: los Estados Unidos, desde el momento de su independencia, no adoptaron una lectura rígida de la “separación estricta” de poderes, sino una versión del *checks and balances*, que requiere cooperación y mutua interferencia entre los distintos poderes de gobierno. Los “frenos y contrapesos” asumen que todos los poderes participan, en parte, con los demás, en las funciones de los otros, y colaboran en el esquema de controles mutuos. Por lo cual, la postura (más bien torpe y retrógrada) asumida por la doctrina encaja muy mal con la tradición histórica de los Estados Unidos. Sobre todo, agregaría, dicha posición se lleva mal con nuestras intuiciones básicas sobre la democracia, que en principio sostienen que son las ramas políticas, antes que la Corte, las que deben definir cómo se obra frente a las regulaciones.

Lo dicho recién, por lo demás, resulta particularmente relevante cuando nos encontramos frente a una situación de “duda interpretativa” como la del caso y muy en particular cuando partimos -como aquí lo hago- de un entendimiento “conversacional” o “dialógico” de la democracia. Frente a genuinas dudas interpretativas, como las que podía presentar el caso (“puede el Presidente definir un esquema tarifario como el examinado?” “es que se encuentra legislativamente autorizado?”), el tribunal, en todo caso, debió haber actuado de un modo muy diferente al que lo hizo. En lugar de arrogarse ella -la Corte- el poder de decidir sobre la respuesta debida, el tribunal pudo y debió haber consultado a la legislatura, si es que quería tomarse en serio la democracia, sus poderes limitados, y el sistema de “checks and balances”.

Es en este punto donde quiero hacer alguna referencia a la cuestión contextual, y al modo en que consideraciones tales podrían aconsejar una

decisión como la del fallo pero (no sólo no invocando sino) rechazando la base argumentativa de la decisión: las MQD. Según entiendo, el análisis constitucional en general, y la función judicial en particular, deben llevarse adelante desde una concepción teórica informada por el contexto. En mi caso, a partir de una visión procedimentalista -en este sentido “Elyana”- y dialógica del constitucionalismo- la lectura contextual que asumo señala que los controles al poder deben activarse conforme a los grandes problemas o “dramas” de la época. Cuando John Ely escribió su obra sobre *Democracy and Distrust*, tales problemas contextuales y “de época” tenían que ver con la opresión de las minorías raciales y sexuales, en particular, por las mayorías dominantes; y también con la indebida influencia ejercida por los lobbies económicos, sobre la democracia. Hoy, entre los “dramas” que enfrentamos, algunos muy prominentes tienen que ver con la “auto-expansión” de los poderes presidenciales, sus abusos de poder (y el llamado “populismo” político) y -a partir del crecimiento del poder del Ejecutivo- el surgimiento del denominado fenómeno de la “erosión democrática” (el Presidente buscando socavar los poderes de las demás ramas de gobierno, y tratando de ganar control sobre los organismos capaces de limitar su poder). En dicho contexto, los tribunales deberían actuar con una presunción negativa frente a toda medida del Ejecutivo destinada a expandir aún más su autoridad, debilitar a los organismos de control, y a imponer discrecional o caprichosamente su autoridad. Desde esta perspectiva (que, en mi caso, busqué desarrollar inicialmente pensando en casos como el argentino o el latinoamericano) la Corte norteamericana hace bien en frenar iniciativas caprichosas y auto-expansivas como la examinada en el caso, a través de los discrecionales aumentos de aranceles. Puede decirse, por lo tanto, que vale la pena dar la bienvenida la decisión de *Learning Resources*, pero a la vez dando el adiós a las MQD -dejando de lado su principal fundamento. ■

El Fondo de Asistencia Laboral

por Mario Ackerman

Un negocio financiero y el fin de la protección contra el despido arbitrario.

25 de febrero de 2026

Si la primera impresión que provoca el *Fondo de Asistencia Laboral* creado por la reforma autodenominada de *Modernización Laboral* es que se trata de un desembozado e indecente negocio financiero —que recaudará alrededor de dos mil quinientos millones de dólares por año—, diseñado a expensas de los recursos del régimen jubilatorio, antes aún subyace algo más profundo, inmediato y siniestro, que es su propósito de arrasar con la protección contra el despido arbitrario, garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Intentaré explicar brevemente las razones de este final anunciado

El FAL y sus propósitos aparentes

El Título II de la inminente ley de Reforma Laboral, bajo el epígrafe *Fondo de Asistencia Laboral* (FAL), con sus artículos 58 a 77 crea los *Fondos de Asistencia Laboral* (art. 58).

La diferencia entre el singular del título y el plural de la regulación puede encontrar su explicación en el mecanismo operativo de lo que en realidad se trata esta rara novedad jurídico-financiera —en realidad, muy poco *jurídica* y fundamentalmente *financiera*—, que comparte con otras alimañas depredadoras su carácter autóctono, pues no parece encontrar antecedentes similares en la experiencia comparada.



En una síntesis de extrema simplificación, puede describirse al FAL como una *cuenta individual abierta a nombre de cada empleador destinada al pago de diferentes indemnizaciones que él debe asumir en varias y heterogéneas hipótesis de extinción de la relación de trabajo*.

Esta casi aséptica presentación, sin resultar inexacta, al omitir los elementos fundamentales del diseño normativo de la conformación y administración del FAL y, especialmente, de su impacto en las relaciones individuales de trabajo, esconde las devastadoras consecuencias que su puesta en práctica podría tener sobre los derechos de los trabajadores y en sus siempre precarias posibilidades de defensa frente a incumplimientos o abusos de poder de sus empleadores.

Consecuencias éstas a las que debe prestarse especial atención, porque es de ellas de donde debería deducirse la inevitable invalidez constitucional de este exótico intento normativo.

En el *mensaje* con el que el Poder Ejecutivo nacional presentó el proyecto de ley de *modernización laboral* al Congreso de la Nación, se informa que:

- los Fondos de Asistencia Laboral constituyen instrumentos financieros destinados a favorecer el adecuado cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias por parte de los empleadores del sector privado;

- la administración de los Fondos de Asistencia Laboral estará a cargo de entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) sujeta a comisiones máximas y a estrictos estándares de transparencia y trazabilidad;

- se ratifica que se mantiene la obligación del empleador de satisfacer íntegramente las indemnizaciones correspondientes, pero accede a un esquema que le permite prever y gestionar de manera más ordenada sus costos laborales, con la finalidad de brindar la mayor seguridad al trabajador en la percepción de los montos que le son debidos;

- este diseño contribuye a reducir el riesgo contingente asociado al cese laboral, desincentiva la litigiosidad y elimina una de las principales barreras a la contratación en sectores intensivos de empleo.

A poco que se examina el marco normativo que aporta el diseño general del FAL se puede observar que sus reglas confirman los dos primeros puntos de cuanto expuso el Poder Ejecutivo nacional en su mensaje de elevación del proyecto al Congreso de la Nación, en orden al carácter de *instrumentos financieros* de los nuevos fondos y a su administración por entidades habilitadas por la CNV, así como la preservación de la obligación del empleador de abonar las indemnizaciones que le impone la legislación.

Esta última obligación, sin embargo, queda severamente atenuada cuando se observa que esos pagos no los va a hacer *el empleador* con recursos *genuinamente* propios, dado que esa erogación será hecha por la *entidad administradora* con las sumas deducidas de las contribuciones que él debería haber abonado al sistema previsional y que estuvieran acumuladas en su *cuenta individual del Fondo* al que él las haya incorporado.

¹Que según lo establecido en el artículo 58 suponen incumplimientos de variada gravedad, casos de fuerza mayor y hasta pagos voluntarios del empleador no contemplados en la legislación.

²En puridad, la *litigiosidad* que se pretende *desincentivar* con el nuevo régimen es la originada en incumplimientos del empleador, como lo son los despidos sin causa o indirectos o la omisión de otorgamiento del preaviso. Bien entendido que

Deducción que caducará en caso de mora del empleador en el pago de su contribución al FAL.



Es inexacto, así, afirmar que *este esquema le permite gestionar de manera más ordenada sus costos laborales* pues, más allá de la indisoluble heterogeneidad de las hipótesis indemnizatorias¹ a las que podría aplicarse, no se trata de un *ordenamiento* de los costos del empleador sino de su *eliminación*, en cuanto ellos van a ser afrontados, total o parcialmente, por una *entidad administradora* con los recursos deducidos de las obligaciones contributivas de aquél al sistema de seguridad social.

Y si bien es correcto afirmar que *este diseño contribuye a reducir el riesgo contingente asociado al cese laboral*, porque las siempre eventuales obligaciones indemnizatorias de los empleadores —aunque muchas veces dependientes de sus propias decisiones— van a ser canceladas sin costo para ellos, es completamente dogmática y sin sustento en ningún dato de la realidad la afirmación en el sentido de que aquél *elimina una de las principales barreras a la contratación en sectores intensivos de empleo*.

Argumento éste que se repite, como un credo místico —tan carente de necesidad de demostración para quienes lo sostienen como huérfano de verdad—, en cada oportunidad en la que se pretenden desbaratar derechos de los trabajadores.

Por fin, no es menos falso el pronóstico, promesa o expresión de deseos —según se quiera ver— sobre el *desincentivo de la litigiosidad*² pues la insalvable inconstitucionalidad de este *original* sistema, como es de esperarse en un Estado de Derecho, no podrá sustraerse al tránsito por los tribunales de justicia para su control y necesaria declaración de invalidez.

Conclusión ésta que se explica por la consecuencia necesaria de la mera existencia del FAL, y que es la eliminación de la función más importante del pago de la indemnización por despido arbitrario.

Veamos las razones de esta afirmación.

Recordemos y concluamos

Como bien decía hace ya casi un siglo Hugo Sinzheimer³, y sus observaciones conservan intactas su actualidad,

la relación que liga al trabajador con su empresario no es sólo una relación obligacional ... es, ante todo, una relación de poder

vínculo en el que, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones civiles o comerciales, el trabajador *no compromete su voluntad* y sí, en cambio, *la somete*⁴.

tal hipotético *desincentivo* viene acompañado de una *promoción* de los incumplimientos de los empleadores por la vía de su impunidad.

³A lo que agregó inmediatamente que “[l]a dependencia del trabajador es por ello no sólo una dependencia económica, social o técnica, que sólo sea un hecho que no concierna al Derecho. La dependencia del trabajador es una relación jurídica de poder que tiene determinados efectos jurídicos, que se apartan sin embargo de los puros efectos jurídicos obligacionales. Pensemos en el poder de mando del empresario. Ningún acreedor puede dar órdenes al deudor. El Derecho de obligaciones no conoce el poder de obediencia del deudor. Nadie duda, sin embargo, que el empresario puede dar órdenes al trabajador y que éste tiene la obligación de obedecer. Esta sumisión aclara que en el mundo del trabajo no sólo tiene un derecho como acreedor, a la manera obligacional, sino un derecho de poder, de carácter jurídico personal”. Ver Sinzheimer, Hugo, *La esencia del Derecho del Trabajo, en Crisis económica y derecho del trabajo; cinco estudios sobre la problemática humana y conceptual del Derecho del Trabajo*, IELSS, Madrid, 1984, pág. 67 y ss., esp. pág. 75.

⁴Como con precisión señala Supiot, “[e]l Derecho del Trabajo procede igualmente de la incapacidad del derecho civil de las obligaciones por aprehender una relación dominada por la idea de subordinación de una persona a otra. Mientras que en el contrato civil la voluntad se compromete, en la relación de trabajo la misma se somete. El compromiso manifiesta la libertad; la sumisión la niega”. Supiot, Alain, *¿Por qué un derecho del trabajo?*, en Documentación Laboral, ACARL, Madrid, 1993, Nro. 39, pág. 11 y ss., esp. pág. 19.

⁵Si acaso esto ocurriera en una relación civil o comercial, la otra parte podría exigir el cumplimiento de lo acordado y reclamar una reparación por el daño causado por el incumplimiento o disolver el vínculo contractual con el derecho al pago por el incumplidor de los daños y perjuicios ocasionados. Dicho sea de *paso*, este artículo también es modificado en la ley de *Modernización Laboral*, pues se elimina la exigencia de que al ejercer esta facultad *los cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad*, con lo que se promueve la *prepotencia* y se convalida la *arbitrariedad* del empleador en el ejercicio de sus poderes jerárquicos.

Tal relación de poder, que implica porque *exige* la sumisión del trabajador a los poderes jerárquicos del empleador, exhibe así una radical diferencia con cualquier vínculo contractual regido por el Derecho Civil o Comercial y es la razón profunda de la propia existencia del Derecho del Trabajo, nacido de la necesidad de una convivencia civilizada y equitativa en una sociedad democrática comprometida con la *justicia social*, en la que se respete y proteja la libertad y la dignidad de las personas que trabajan *para otro*.

Esa posición de *subordinación* tiene como manifestación extrema, absolutamente impensable en cualquier otra vinculación *contractual*, la admisión de que el empleador —y sólo él— pueda modificar unilateralmente *la forma y modalidades de la prestación del trabajo* —en las palabras del actual artículo 66 de la LCT—⁵.

Facultad ésta que, por cierto, en la lógica de la relación de trabajo subordinada, jamás podría ser concedida al trabajador.

La inevitable constatación de ese vínculo desigual en el elenco de poderes y deberes entre personas teóricamente tan libres como iguales, que reclama que una de ellas entregue una porción de su libertad —el trabajador— a la otra —el

empleador— a cambio de un salario, explica que el Derecho del Trabajo se haya erigido como un sistema de límites a la amplitud de posibilidades emergentes de la posición jerárquica del empleador, cuya demarcación inicial fue producida por las normas de fuente estatal.

El marco normativo, sin embargo, como toda regulación, es un ideal que no garantiza su cumplimiento espontáneo y si bien, frente a la transgresión de aquellos límites o ante otros incumplimientos del empleador, siempre quedará al trabajador la vía judicial para canalizar su protesta y sus reclamos, la respuesta que pueda obtener de los tribunales será siempre tardía, apenas compensatoria y rara vez suficiente.

Además, ese camino probablemente⁶ estará precedido por la pérdida del puesto de trabajo.

«Esta sumisión aclara que en el mundo del trabajo no sólo tiene un derecho como acreedor, a la manera obligacional, sino un derecho de poder, de carácter jurídico personal'.»

Es por eso que, frente a la pretensión o amenaza de abuso de poder por el empleador o ante la violación por éste de sus obligaciones legales, convencionales o contractuales, el ordenamiento jurídico debe proveer al trabajador instrumentos de eficacia inmediata, para que él tenga la posibilidad de defender sus derechos y proteger los ámbitos de libertad personal no resig-

nados en la vinculación laboral, sin que ello acarree poner en riesgo la conservación del empleo.

Y esto es así porque el Derecho debe proteger en el trabajador la expresión más pura y simple de su libertad, que es la de *poder decir que NO*⁷ frente a la arbitrariedad o la prepotencia.

Negativa que, para su eficacia, reclama la certeza de que el trabajador, sin riesgos ni temores, pueda exigir al empleador el cumplimiento de las obligaciones que le imponen las normas heterónomas y autónomas así como resistir cualquier pretensión de éste de abusar de sus poderes jerárquicos o desbordar los límites que le fija el ordenamiento jurídico para su ejercicio.

Para que tal posibilidad de negativa y resistencia pueda materializarse y no quede flotando en los vapores de la teoría y la formalidad de las normas, el instrumento *individual* más eficaz es la *protección contra el despido arbitrario*, que le permitirá exigir lo que en derecho le pertenece y corresponde, sin el temor de perder el empleo.

Porque también *el miedo*, como *la necesidad*, reprimen la libertad.

Y la protección más eficiente contra el despido arbitrario o, tal vez, la *única protección real*, es la garantía de *estabilidad en el empleo*.

Para que la conclusión anterior no se preste a confusión, debo aclarar que me refiero aquí y ahora a la *verdadera estabilidad*, que *consiste en el derecho que se reconoce al trabajador a continuar en su empleo hasta cuando quiere y puede hacerlo*⁸, que en la doctrina presentamos como *estabilidad propia*⁹ y que en sus dos manifestaciones —*absoluta y relativa*—, tornan ineficaz al despido sin justa causa para poner fin a la relación de trabajo.

⁶Y, como consecuencia de la modificación del artículo 66 de la LCT, la pérdida del empleo mutará de la *probabilidad* a la *inexorabilidad*.

⁷En la irreductible síntesis de Albert CAMUS, en su *El hombre rebelde*, Losada, Buenos Aires, 2003, pág. 19.

⁸Según la simple y precisa definición de Deveali en DEVEALI, Mario L., *Estabilidad*, en *Enciclopedia Jurídica Omeba*, Omeba, Buenos Aires, T. X, pág. 789, reproducido en DEVEALI, Mario L., *El Derecho del Trabajo en su aplicación y sus tendencias*, Astrea, Buenos Aires, 1983, T. I, ps. 547 y ss., esp. pág. 548.

⁹Ver sobre estas categorías conceptuales mi ACKERMAN, Mario E., *La extinción de la relación de trabajo; segunda edición ampliada y actualizada con las reformas producidas por el DNU 70/2023 y la Ley 27.742*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2024, T. I, pág. 45 y ss.

¹⁰Con la excepción del empleo público y, limitada en el tiempo, de los trabajadores amparados por la *tutela sindical* (art. 52 y concordantes de la Ley 23.551).

No es éste, sin embargo, el modelo seguido actualmente por la legislación laboral en la Argentina¹⁰ que, para las relaciones de trabajo del sector privado, optó por un régimen general de *estabilidad impropia*¹¹, que admite la eficacia extintiva del despido sin justa causa y sólo impone al empleador el pago de una indemnización tarifada que toma como referencia la remuneración y la antigüedad del trabajador.

En estos términos, como es sabido y admitido, la nota diferencial entre la *estabilidad propia* — sea ésta absoluta o relativa— y la *impropia* radica en que mientras que en la primera el despido sin causa justificada es ineficaz para romper el vínculo laboral, todo lo contrario ocurre con la segunda¹².

Como consecuencia de esta diferencia esencial, el instrumento protector en la primera es el derecho del trabajador a la reinstalación en el puesto de trabajo y, en cambio, en la *estabilidad impropia* el protagonismo lo tiene la *indemnización tarifada*.

Quiero destacar aquí y poner especial énfasis en recordar que, junto a la finalidad *punitiva* y *reparadora* de la indemnización por despido, sobresale el propósito *disuasivo* de la tentación del empleador de abusar de su supremacía en el vínculo laboral que le reconoce el ordenamiento jurídico.

En tal situación el *costo económico* que supone el pago de la indemnización opera como un factor que desalienta tanto la ruptura *directa e incausada* del contrato de trabajo, como el eventual ejercicio abusivo de sus facultades y poderes por aquél o, incluso, el incumplimiento de sus obligaciones legales, que podrían provocar un *despido indirecto*.

Así, si bien la doctrina y la jurisprudencia suelen prestar más atención a la función *reparadora*, el FAL obliga ahora a jerarquizar y dar la mayor

relevancia al propósito *disuasivo*, que es en puridad el que puede considerarse que cumple con la función que la Constitución Nacional le encomienda al legislador, en orden a *asegurar al trabajador ... protección contra el despido arbitrario*.

Es por esto que debe subrayarse que para cumplir, aunque más no sea de manera imperfecta e insuficiente, con el mandato constitucional de protección contra el despido arbitrario y, al mismo tiempo, asegurar al trabajador *condiciones dignas y equitativas de labor*, es ineludible que el pago de la indemnización esté, exclusivamente, a cargo del empleador.

Bien entendido que el cobro de la indemnización tarifada por el trabajador sólo cumple — en general parcialmente— la función reparadora, pero *no lo protege contra el despido arbitrario*, ni lo desalienta

En una comparación más evidente, la *protección* contra la caída de un balcón no es una ambulancia ni un quirófano sino una baranda suficientemente fuerte.

La finalidad y función de esta imposición, frente a la inexistencia de la eficacia cierta que otorga la *estabilidad propia* para que el trabajador pueda *reclamar sin riesgo ni miedo*, es lo que en términos militares y de política armamentística se conoce como *defensa por disuación*.

La *obligación de pago* de la indemnización es así una garantía silenciosa que tiene una *función preventiva* en cuanto opera como advertencia al empleador sobre los riesgos económicos que acarrea la transgresión de los límites de sus poderes, con el avance sobre territorios de libertad del trabajador no resignados en la relación de dependencia o simplemente dejando de cumplir con sus obligaciones legales, convencionales o contractuales.

Es así entonces la *anulación del efecto disuasorio* que tiene la actual imposición del pago de

¹¹ACKERMAN, M. E., *La extinción de la relación de trabajo ...* (cit.), pág. 50 y ss.

¹²Esto es siempre así, con independencia de que se considere *lícita* o *ilícita* la decisión extintiva del empleador. Yo, por cierto, estoy enrolado en la posición mayoritaria que entiende que el despido arbitrario es un ilícito contractual pero esta es una discusión que en esta primera aproximación tiene, por ahora, menos relevancia. Sobre las dos grandes posiciones en la doctrina en torno de esta cuestión y los argumentos en favor de una y otra ver mi ACKERMAN, M.E., *La extinción de la relación de trabajo ...* (cit.), T. I, pág. 179/185.

la indemnización al empleador, que es la consecuencia primera e inmediata del diseño del proyectado *Fondo de Asistencia Laboral*, lo que obsta a que se lo considere compatible con las garantías que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional le impone al legislador.

En suma

En el año 1937, mientras Adolfo Hitler daba los primeros pasos hacia un impensable baño de sangre y horror, advertía ya Aldous Huxley¹³ que

Los buenos fines sólo pueden ser logrados usando los medios adecuados.

El fin no puede justificar los medios, por la sencilla y clara razón de que los medios empleados determinan la naturaleza de los fines obtenidos.

Por esta razón, agrego yo, el *medio* elegido permite reconocer el *fin* perseguido.

En el caso del *Fondo de Asistencia Laboral*, el *medio* es la liberación del empleador del pago de la indemnización por despido sin justa causa¹⁴,

cuya imposición a aquél es, hasta hoy y entre nosotros, el principal instrumento para la *protección contra el despido arbitrario*.

El *fin* no es sólo eliminar, o cuando menos reducir sustancialmente, el costo que puede implicar para los empleadores la terminación de una relación de trabajo sino, antes aún, arrasar con la débil resistencia que los trabajadores aún pueden oponer a los incumplimientos de aquéllos y al ejercicio abusivo de sus poderes jerárquicos.

En efecto, el *Fondo de Asistencia Laboral* es uno de los pilares fundamentales de la *modernización* laboral impulsada por el actual gobierno, cuya finalidad es liberar al empleador de la *asunción del costo* —entre otras— de las indemnizaciones que le puedan corresponder al trabajador frente al despido sin justa causa, para neutralizar de este modo la función disuasoria de aquéllas.

Más allá de la contradicción con la garantía constitucional, se trata así de un *medio* inoculablemente *perverso* frente al que, como podría decir Huxley —y yo me sumaría a él—, el *fin* no puede ser menos infame. ■



«La dependencia del trabajador es una relación jurídica de poder que tiene determinados efectos jurídicos, que se apartan sin embargo de los puros efectos jurídicos obligacionales.»

«Facultad ésta que, por cierto, en la lógica de la relación de trabajo subordinada, jamás podría ser concedida al trabajador.»

¹³Huxley, Aldous, *El fin y los medios; Una encuesta acerca de la naturaleza de los Ideales y de los métodos empleados para su realización*, 3ra. Ed. Pocket, Sudamericana, Buenos Aires, 2000, pág. 15. Versión original publicada por Chato and Windus, en Londres en 1938, como *Ends and Means; an enquiring into the nature of ideals and into the methods employed for their realizations*,

¹⁴Junto con otros supuestos de terminación de la relación de trabajo, originadas en diferentes causas, de importancia desigual.

Nada, nada más que tristeza... ¿y quietud?

por María Valeria Berros

El derretimiento de los glaciares y las posibilidades del derecho y la ley.

3 de febrero de 2026

La gesta de lo que fue una de las leyes pioneras en el mundo sobre protección de glaciares fue extraordinaria. Improbable y difícil pero extraordinaria como tantas otras experiencias de aprobación de leyes que abrieron caminos, emocionaron y generaron orgullo en Argentina. Debates, discusiones, reuniones de comisiones en la cámara alta y baja, manifestaciones, argumentos, publicaciones, saberes en juego. Algunos legisladores recuerdan que estudiantes de las escuelas llegaron a sus despachos, movilizados junto con organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas por la defensa de los glaciares. Todo en movimiento hace tan solo quince años.

La lucha por el cuidado de los glaciares en estas latitudes se explica de varias maneras. Una de ellas es que somos uno de los países con mayor cantidad de glaciares a nivel global, por detrás de Chile en nuestra región. Estos ecosistemas forman parte de la geografía de muchas provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Gracias a esta ley hoy sabemos que convivimos con 16.968 glaciares, responsables de alimentar cerca del 40 % de las cuencas hídricas del país. Estos heterogéneos cuerpos de hielo sostienen, entre otras funciones vitales, nuestro derecho de acceso al agua y tejen el entramado vital de miles de seres.

Los glaciares no tienen repuesto, si dejamos que se pierdan volveremos arrepentidos y ya se-

rá demasiado tarde. Si desaparecen lo hacen para siempre, es imposible pensar en la reconstrucción de este tipo de ecosistema. Son tan frágiles como centrales en este momento: en ellos se resguarda el 70% del agua dulce del mundo según informa la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Al compás del cambio climático estos delicados ecosistemas están en retroceso y el pronóstico es una **avalancha de efectos en cadena** y un próximo siglo en el que se pondría **fin al hielo eterno**. Un futuro sin glaciares implica el aumento del nivel del mar con las consiguientes crecidas de cursos de agua, así como el agotamiento de las reservas de agua dulce que compromete el abastecimiento de un número creciente de personas.

No existen controversias al respecto: los glaciares requieren de urgente y especial tutela y Argentina fue pionera en aprobar una normativa en ese sentido. El fundamento para lograr herramientas de protección resulta una obviedad a la luz de décadas de producción de saberes sobre el tema. Sin embargo, estamos en un momento de la historia en que parece que aquello que se explicó, acordó y legisló, incluso de manera muy reciente, dejó de estar anudado a algún consenso de base como, por ejemplo, que estamos realmente destruyendo nuestro planeta. Sólo basta con prestar atención a lo que sucede en la patagonia argentina en este momento: se calculan alrededor de 220.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Algo parecido sucede al otro lado de la

cordillera en Chile. Episodios de este y otro tipo se cuentan a diario.

Cada año registra temperaturas récord mayores al anterior, vivimos realmente en una carrera contra el tiempo. Los desplazamientos de personas que ya no pueden vivir en sus territorios van en aumento. Las inundaciones, sequías prolongadas, incendios forestales van a ser cada vez más numerosos y virulentos si no reaccionamos ahora. Se calcula que un millón de especies están en peligro de extinción. Cada hebra que se cae del entramado que sostiene la existencia nos lleva a un escenario más difícil. A su vez, implica la pérdida de múltiples maneras de relacionarnos con los demás seres. Pone en riesgo la posibilidad de vivir en vinculación con ríos, montañas, lagos, glaciares, animales de todo tipo. Un mundo considerablemente más triste.

Las evidencias sobran. Sin embargo, esta trágica escena se está desplegando en el mismo momento en que cada vez más sociedades eligen gobiernos que, entre otras características, son negacionistas del cambio climático o de la cuestión ecológica general. Debates que hasta hace pocos años eran casi caricaturescos hoy regresan. De las discusiones por la construcción de estrategias políticas y jurídicas para aportar a procesos de desmercantilización de la naturaleza, pasamos a escuchar casi de manera impasible que para proteger a las ballenas hay que encerrarlas entre alambrados o privatizar el mar.

Este dato no es simplemente anecdótico. En cada país en que gobierna un negacionista los retrocesos en una multiplicidad de ámbitos son notorios. Y la cuestión ambiental no es una excepción. El libreto se repite casi en tiempo real: se desfinancian áreas clave, se degradan ministerios y secretarías, se modifican competencias, se bajan los presupuestos, se despide personal, y también se busca derogar o reformar leyes en un sentido regresivo.

Existen esfuerzos sostenidos por dejar constancia de esos retrocesos. Muchos de ellos fueron y son realizados por universidades y diversas instituciones del sistema científico, espacios

que también son atacados por este tipo de gobiernos en ejercicio. No solo reducen las partidas presupuestarias vinculadas con la educación y la ciencia, sino que sostienen ataques del orden de lo simbólico especialmente en relación con las ciencias sociales y humanidades. Sin embargo, desde herramientas metodológicas provenientes de esas áreas es que se está consolidando una estrategia de seguimiento de retrocesos con dos fines. Por un lado, brindar herramientas para actuar frente a las regresiones en curso. Por el otro, construir un estado de cosas pensando en estrategias de reconstrucción.

En Estados Unidos el Sabin Center de la Universidad de Columbia rastrea las desregulaciones climáticas del gobierno de Donald Trump por segunda vez; en Brasil varias universidades y organizaciones no gubernamentales fueron siguiendo las regresiones de Jair Bolsonaro que resultaron, por ejemplo, en la más alta tasa de deforestación de la Amazonia desde el año 2006. Argentina no es una excepción a este proceso de seguimiento. Ya se han publicado reportes que dan cuenta de los retrocesos del actual gobierno en materia ambiental en el [Primer informe del Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina](#) y en el [Informe de Regresiones Ambientales bajo el Gobierno de Javier Milei 2024-2025](#) y en materia de derechos de los pueblos indígenas en el [Informe Los Pueblos Indígenas en la Argentina de la Derecha Libertaria](#).

Es en este tiempo que se propone reformar la ley de glaciares. El momento en que se menosprecia abiertamente el trabajo de largos años de investigación y el compromiso ciudadano con procesos de generación de instancias de protección política y jurídica de este y otro tipo de ecosistemas. Es suficiente con prestar atención, no sólo estamos frente a este retroceso sobre los glaciares en el congreso nacional. En Mendoza, por mencionar uno de tantos ejemplos posibles, de espaldas a la ciudadanía, hace poco tiempo atrás la legislatura provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero de

cobre y oro conocido como San Jorge que, se sabe, pondrá en riesgo el agua en un territorio en el que ya es escasa.

En el caso de la tutela de los glaciares y el ambiente periglacial estamos ante una de las normas vigentes de presupuestos mínimos. Conforme el contenido del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, Argentina posee un conjunto de normas de este tipo que delimitan un piso de tutela ambiental que cada provincia puede igualar o superar en su propia política y legislación subnacional.

La hoy vigente [Ley Nro. 26.639](#) se sancionó en 2010 y estableció los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La norma define como glaciar a toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recrystalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Por su parte, el ambiente periglacial se define en la alta montaña como área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico, y en la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo (art. 2 Ley 26.639).

El objetivo de la ley es claro: preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Además, se establece que los glaciares constituyen bienes de carácter público.

Esta ley permitió conocer la enorme diversidad, ubicación y características de los glaciares que se encuentran en el territorio nacional a través del [Inventario Nacional de Glaciares](#) cuya confección está a cargo del [Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales \(IANIGLA\)](#). Este es un instituto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en cuyo seno conviven investigadores de di-

versas disciplinas y cuenta con un reconocido equipo de glaciólogos, un área del conocimiento muy específica en la que nuestro país se destaca internacionalmente.

En este inventario se busca individualizar todos los glaciares y las geoformas periglaciares por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial como paso necesario para su protección. Esta tutela se sustenta en una serie de prohibiciones de actividades que pueden afectar las funciones de estos ecosistemas, implicar su destrucción o interferencias en su avance.

«No existen controversias al respecto: los glaciares requieren de urgente y especial tutela y Argentina fue pionera en aprobar una normativa en ese sentido.»

Las prohibiciones que establece la ley son las siguientes: a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen tanto en glaciares como en el ambiente periglacial; b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos; c) la exploración y explotación minera e hidrocarbúfera tanto en glaciares como en el ambiente periglacial; d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.

El proyecto de reforma de la ley vigente que presentó el Poder Ejecutivo Nacional y ahora se discute en el Congreso de la Nación posee diferentes aspectos que marcan un retroceso claro de la tutela de este tipo de ecosistemas tal y como lo ha diagramado la ley vigente.

En primer lugar, reduce la protección ya que parte de un concepto más acotado y sólo establece la protección de los glaciares y geoformas

periglaciares que tengan función de reserva estratégica de recursos hídricos o se comporten como proveedores de agua de cuencas hidrográficas. A su vez, se elimina la prohibición expresa de exploración y explotación minera e hidrocarbúfera en el ambiente periglacial.

En segundo término, el proyecto coloca a las provincias en un nuevo rol ya que ellas serían las encargadas de determinar si un glaciar o un ambiente periglacial cumple o no esas funciones de reserva estratégica o de proveedora de agua de cuencas. Este esquema es contrario a la idea de presupuestos mínimos que establece nuestro pacto constitucional y plantea varios problemas. Por un lado, cada provincia podría adoptar un criterio diverso incluso en glaciares que se encuentran en diferentes jurisdicciones, un clásico tema del derecho ambiental que ha dado lugar a soluciones diversas como, justamente, esta idea de establecer estándares de protección uniformes. Por el otro lado, se perderían años de construcción de una metodología basada en criterios científicos y gestada al interior del propio sistema científico y tecnológico nacional para dar paso a un sistema atomizado. Este nuevo esquema incluso permite contraponerse al propio IANIGLA que es una institución referente en el tema a nivel regional y mundial. De hecho, la propuesta de reforma establece que si una provincia determina que un glaciar no cumple una función relevante puede solicitar al IANIGLA su eliminación del inventario y que, aún en el caso en que no lograra esta eliminación, cualquier autorización provincial de actividades que pueda afectar al glaciar en cuestión es válida. El inventario pasaría a ser una información más que las provincias podrían o no tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre los glaciares y el ambiente periglacial, debilitando y desconociendo el aporte sostenido en este tema por parte del sistema científico.

En tercer lugar, se dispone que son las provincias las que deben discernir si es necesario o no efectuar una evaluación de impacto ambiental estratégica. La ley vigente establece que se

deben realizar evaluaciones de impacto ambiental y también evaluaciones ambientales estratégicas en el diseño de políticas, planes y programas de gobierno que puedan afectar a este ecosistema.

Así, mientras convivimos con una producción constante de información sobre la relevancia clave de los glaciares y la urgente necesidad de protegerlos tanto a escala internacional como regional y local, en Argentina estamos discutiendo a contramano.

La introducción infundada de este debate en el período de sesiones extraordinarias del congreso nacional se explica como un episodio más de una propuesta de país hilvanado a partir de la lógica de facilitación de la extracción de recursos naturales para su exportación. En ese sentido, se enrola en la misma dirección que el [Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones](#) - más conocido como RIGI- que hace poco tiempo se aprobó dentro de la llamada Ley de Bases en busca de la atracción de grandes capitales extranjeros o nacionales en sectores como la minería, energía, petróleo, gas.

¿Cómo podría fundamentarse dar pasos atrás en la tutela de los glaciares en un escenario tan claro y preciso de crisis ambiental? ¿De qué manera se podría sostener esta reforma cuando nuestra propia Constitución Nacional establece que tenemos un deber respecto de las generaciones futuras? Del mismo modo podríamos preguntarnos cómo se argumenta un retroceso en los niveles de tutela cuando Argentina ha ratificado recientemente el [Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe](#) - más conocido como Acuerdo de Escazú- que incorpora de manera expresa el principio de no regresión en asuntos ambientales.

Nuestra Constitución Nacional diseña la arquitectura jurídica para la protección del ambiente mediante la incorporación del concepto de presupuestos mínimos, concebidos como un umbral normativo básico e inderogable. Estas

normas, dictadas por la autoridad nacional, pueden ser complementadas por las provincias en el marco de un sistema de competencias concurrentes que habilita la ampliación —pero no la reducción— de los niveles de tutela ambiental. Este esquema configura un límite estructural a la regresión normativa: si bien las provincias conservan margen para reforzar la protección, no se encuentran habilitadas para debilitar los estándares mínimos fijados a nivel federal. Las leyes de presupuestos mínimos operan como un piso normativo obligatorio que impide retrocesos mediante normas provinciales o locales y que establece un marco de estabilidad relativa frente a intentos de desmantelamiento de estándares de protección ambientales. En este sentido, los presupuestos mínimos funcionan como un instrumento de contención de la regresión.

Desde 2002, el Congreso Nacional ha sancionado diversas leyes de presupuestos mínimos, entre las cuales se destaca la Ley Nro. 25.675 de Política Ambiental Nacional. Esta norma define el presupuesto mínimo como una regulación destinada a asegurar una tutela ambiental común en todo el territorio nacional, orientada a preservar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y promover un desarrollo sustentable. La idea de un estándar uniforme refuerza la noción de un nivel básico de protección que no puede ser erosionado, consolidando un umbral normativo que debería operar como referencia para evaluar eventuales retrocesos. A su vez, la Resolución Nro. 92/2004 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) profundiza esta concepción al caracterizar los presupuestos mínimos como un umbral básico e inderogable de protección ambiental, concebido como un piso normativo uniforme que garantiza a todos los habitantes un nivel mínimo

de tutela, con independencia de su localización territorial. Esta definición resulta especialmente relevante para el principio de no regresión, en tanto cristaliza la idea de un estándar mínimo que no puede ser válidamente reducido.

La protección ambiental a través de regulaciones permite también concebir la idea de legado hacia las generaciones futuras: el entramado que nos permite vivir a los humanos y a una inimaginable diversidad de seres necesita pervivir. Las actuales generaciones somos responsables de ese legado y aquí está una de las claves del principio de no retroceso y la tutela de los glaciares: tenemos que asegurar que las generaciones porvenir puedan convivir con ellos. Y aún más, si nos desmarcamos de las posiciones más antropocéntricas y tendemos puentes con los debates latinoamericanos vinculados a la justicia ambiental y ecológica, estos ecosistemas por sí mismos tienen derecho a existir ahora y en el futuro, tal y como se viene trabajando en el campo jurídico latinoamericano hace más de dos décadas a nivel regulatorio y jurisprudencial. Existen experiencias constitucionales —como las de Ecuador y Bolivia— y decenas de normas jurídicas nacionales o subnacionales y sentencias judiciales que reconocen derechos de muy diversos ecosistemas y que, incluso, les nombran esquemas de representación legal como guardianías para implementar decisiones protectorias.

También esa es la escena en la que se desarrollan las regresiones: no parece haber quietud sino disputa. La particularidad es que en esta disputa se juega el futuro de los glaciares pero también de la telaraña, el yuyal, el rosal, la flor. Se juega otro de los tantos episodios que pueden conducir a un planeta envuelto en nada más que tristeza. ■



Advertencias de John Ford y Clint Eastwood para el nuevo mundo

por Antonia Fratini Lagos

Notas sobre cine, fronteras, y modernidad

3 de febrero de 2026



A la hora señalada

Existe un conjunto de películas que narran el fin del Lejano Oeste y permiten decir algo acerca de la salida del mundo natural y comienzo de la sociedad moderna. Estos westerns son como instrumentos para surcar en el paso del tiempo, analizar la persistencia de ciertos conflictos, y la inevitable frustración de algunas promesas.

***A la hora señalada* (1952) y la ilusoria transparencia de la gente decente**

En *A la hora señalada* (1952) Gary Cooper actúa de Will Kane, un sheriff que levanta su arma por última vez cuando el criminal Frank Miller, a quien había encarcelado años atrás, regresa al pueblo con su banda en busca de venganza. Su ayudante, molesto por no ser nombrado alguacil, le ofrece ayuda a cambio del cargo. Kane rechaza, sin negociar su integridad, y él lo abandona. A medida que pide ayuda a la comunidad que él había liberado de la tiranía de los criminales, esta (temerosa, egoísta o indiferente) le da la espalda y lo deja solo.

El juez, que había enviado a Miller a prisión, huye del territorio para salvarse de la venganza de los bandidos, llevándose los símbolos o disfraces de la justicia (bandera, balanza, constitución). Al mismo tiempo, varios habitantes del pueblo esperan el duelo final con un entusiasmo sádico poco disimulado. Es la ley del Lejano Oeste, en pueblos donde no pasa nada, el tiroteo siempre es bienvenido como espectáculo.

Kane se dirige a la iglesia a pedir ayuda a los creyentes (hombres y mujeres respetables). Inicialmente algunos hombres se ofrecen impulsivamente, recordando que fue Kane quien convirtió al pueblo en un lugar seguro y próspero. Pero pronto surgen voces disidentes. Ellos pagan impuestos para que se garantice el orden, y no entienden por qué los ciudadanos comunes deberían arriesgar la vida para salvar al sheriff.

El debate se extiende cruelmente mientras el tiempo se agota. Finalmente, la congregación advierte sobre el peligro económico de un tiroteo en Hadleyville, la violencia espanta inversiones y pone en riesgo el futuro común, y aconsejan que Will se vaya antes de que sea tarde. Los hombres y mujeres de la iglesia revelan su cobardía y su falta de compromiso con la civilización.

Como última alternativa, llevan a Kane a buscar a su mentor, el antiguo sheriff. Lo encuentra en una casa aislada, sentado en su mecedora, con artritis y sin gloria. El veterano, desencantado con la justicia, ya conoce su manera de actuar: liberar a los prisioneros en nombre de principios inasibles como la redención humana, solo para que regresen y busquen venganza.

Tampoco le sorprende que el pueblo no haga nada para defender al sheriff; no es solo apatía, sino un profundo desinterés por asumir la responsabilidad cívica que la ley exige. “People have to talk themselves into the law”, dice. Para romper con la inercia de la barbarie, la gente tiene que convencerse a sí misma del valor y significado de la ley. Si la cobardía y el individualismo son lo natural, lo esperable, la civilización es artificial y necesita de un proceso de socialización o apropiación.



El silbido del tren de la tarde (arquetipo del progreso y símbolo del avance de la civilización en el Lejano Oeste) anuncia la llegada de Miller y su banda salvaje al pueblo. Will Kane, como la mayoría de los protagonistas de las películas de Zinnemann, debe enfrentar su destino solo. Con la ayuda inesperada de Amy, su esposa quaker que traiciona su promesa religiosa de no violencia y mata a uno de los bandidos, Kane vence a los bandidos. Luego de la pelea, el pueblo sale de sus escondites intentando volver a la civilización. El sheriff, asqueado, tira su estrella de lata al piso y él y su esposa abandonan Tombstone para siempre.

A la hora señalada (1952) fue escrita por Carl Foreman mientras era perseguido por el macartismo. Por eso mismo, la película fue leída como una parábola sobre la cobardía y el miedo social frente a las persecuciones políticas en Estados Unidos. Más allá de ese contexto histórico, el film sigue funcionando como una exhibición de la fragilidad de las ficciones morales que sos-

tienen a las comunidades modernas. Revela que a veces, las personas no son lo que parecen, y que la imagen de una comunidad respetable y civilizada no es mucho más que una apariencia.

Cuando el aparato institucional todavía no existe como garante de la justicia, y el fervor popular le da la espalda, hace falta alguien más -el sheriff- para asegurarse que al final del día las injusticias se corrijan. Lejos de colocarnos en el lugar del sheriff, Foreman nos recuerda que lo más probable es que seamos parte del elenco del pueblo.

En 1973, Clint Eastwood dirige una secuela imaginada de *A la hora señalada* (1952). En *Infierno de Cobardes* (1973) la llegada de un Forastero enigmático al pueblo de Lago, habitado en apariencia por hombres respetables, va revelando la complicidad colectiva en el asesinato de su antiguo sheriff. Un crimen que reaparece como una pesadilla recurrente en la que todos observan cómo lo linchan en la calle.

Frente a la amenaza de que los bandidos regresen al pueblo, contratan al Forastero para que los defienda. Progresivamente, este humillará las distintas instituciones del pueblo. Se vengará de su hipocresía designando a un enano como sheriff, regalando el whisky del bar, desalojando a todos los hospedados en el hotel y desarmando los tableros de la iglesia en construcción. Imponiendo un control arbitrario y tiránico sobre el lugar, el Forastero ordena pintarlo de rojo, cuelga un cartel en la calle principal que dice “Bienvenidos al Infierno”, y, en el enfrentamiento final con los tres criminales, prende fuego las casas.

La venganza se eleva a un plano sobrenatural, un juicio final propio de las narraciones del Antiguo Testamento, y el personaje de Clint Eastwood se confunde con el de un fantasma. Solo un enviado del pasado, un muerto vivo, conoce la verdad de lo que sucedió en el Lejano Oeste. Como el Forastero, el western es un fantasma que persigue a los Estados Unidos, y otras experiencias de sociedad moderna, revela secretos y endereza injusticias.



High Plains Drifter, Larsen On Film

En los westerns clásicos, predomina una especie de convicción - un alivio - de que al final se eliminarán los elementos violentos y el mundo seguirá su cauce brillante como en *Horizontes de grandeza* (1958). Al final un cowboy vuelve a poner al mundo cabeza arriba. Sin embargo, *A la hora señalada* (1952) e *Infierno de Cobardes* (1973) nos dicen: la violencia es la violencia, no se la puede pensar como una disfunción de la que el mundo se arregla. La historia de la sociedad moderna no es una seguidilla de triunfos inevitables que nos dirigen a un futuro más brillante. La sociedad puede ser su propio obstáculo.

***Pasión de los fuertes* (1946) y el precio del orden**

En *Pasión de los fuertes* (1946), John Ford cuenta la historia que el mismo escuchó contar al mítico cowboy Wyatt Earp. El film se desenvuelve en Tombstone, un pueblo al borde de la civilización, dominado por dos formas de autoridad primitiva. Por un lado, el clan familiar de Pa Clanton, que domina el negocio ganadero; por el otro, Doc Holliday, que controla el juego y los salones. La incipiente comunidad, atrapada entre estas dos fuerzas, mira hacia el Este con fascinación. Quiere formar parte del mundo moderno, pero su ilusión de progreso es tan fuerte como torpe.

Para dar cuenta de lo cerca y lejos que está el pueblo de ser una sociedad moderna Ford incluye otros personajes y lugares híbridos. Por ejemplo, al pueblo lo visita un poeta ambulante, declamado Hamlet, que recita de memoria la obra de Shakespeare. Ese destello de erudición civilizada se ve corrompida por la tendencia a emborracharse que provoca el Lejano Oeste y la per-

sistencia de personajes del orden de lo natural (los hermanos Clanton) que encierran al poeta en un bar y se burlan de él. Otra escena ilustrativa es la inauguración de la iglesia. John Ford monta un baile en el piso de una iglesia todavía no construida, pero que ya tiene los cimientos, campanas y una estructura firme, en el medio de Monument Valley. Sin sermones, el pueblo celebra la llegada de la evangelización de la mano de las campanas a Tombstone con música y baile.



My Darling Clementine (1946)

Al enterarse de que un clan familiar de bandidos robó su ganado y asesinó a su hermano menor, Wyatt Earp acepta ser el nuevo sheriff de Tombstone. La motivación personal de venganza familiar se entremezcla con un propósito mayor. Frente a la tumba de su hermano menor Earp dice: "Cuando dejemos este país, los chicos como vos van a poder crecer y vivir seguros". Ford consigue que la lápida de piedras se entremezcle con el paisaje rocoso de Monument Valley, como si la pérdida inesperada de su hermano menor fuera un eco lejano de un trauma nacional.

Durante el enfrentamiento final, la justicia se presenta como un gesto ambiguo entre lo público y lo privado. Wyatt Earp se quita la estrella de comisario diciendo que se trata de un asunto familiar, pero antes de sacar su pistola presenta una orden de arresto a Pa Clanton por el asesinato de su hermano. Con la ayuda de Doc Holliday, un médico del Este convertido en bandido

tan temido como los Clanton, Earp vence. En el Oeste, la justicia tiene que ser aplicada por hombres tan fuertes y temerarios como los criminales, el progreso sólo puede desplegarse con ayuda de quienes aún pertenecen al viejo mundo. Finalmente, Doc Holliday y los hermanos Clanton, los remanentes del mundo salvaje, mueren, y se abre el paso a la civilización.

Por más que la película no nos hable directamente de la fundación de un Estado, sí dice algo sobre cómo se termina el mundo de las leyes naturales. Para Ford, son hombres como Wyatt Earp los que hacen que el mundo progrese. Las instituciones, si algún día llegan, serán un síntoma no las artífices de esta entrada al mundo moderno. El nuevo mundo se abre paso con actos individuales, necesarios para el progreso so-

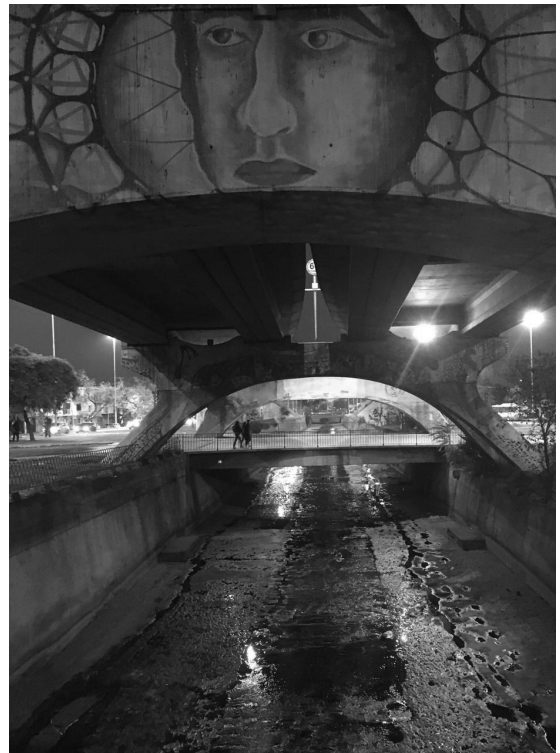
cial. La Ley como principio abstracto no existe en el Lejano Oeste, por eso, se necesita la venganza personal pasa a darle sentido.

¿Cómo construir un significado común de la Ley que se sostenga por sí mismo? Ese es el desafío del mundo moderno. La llegada del tren, la iglesia y la escuela, ¿bastan para instituir la Ley? Difícil creerlo.

Al final, el western no es un repositorio de certezas que ordenan el rumbo de una nación. Tampoco es un confesionario que perdona los pecados y a cambio de cinco rosarios olvida el pasado. Es más como el diván del analista, un lugar no tan cómodo en el que reflexionar sobre la evolución de temas sociales que nunca desaparecen, pero que en el mejor de los casos se vuelven más soportables. ■

«Con la ayuda inesperada de Amy, su esposa quaker que traiciona su promesa religiosa de no violencia y mata a uno de los bandidos, Kane vence a los bandidos.»

«Si la cobardía y el individualismo son lo natural, lo esperable, la civilización es artificial y necesita de un proceso de socialización o apropiación.»



Leer a C. Wright Mills en la era de Trump

por Clyde W. Barrow

Desde Jacobin, un rescate urgente de The Power Elite, texto fundamental de uno de los sociólogos más importantes del siglo XX.

9 de febrero de 2026

Hace setenta años, C. Wright Mills publicó *The Power Elite* (La élite del poder), una crítica mordaz contra los ejecutivos de las grandes empresas, los funcionarios estatales y sus defensores académicos. Su análisis no ha perdido nada de su fuerza ahora que nos enfrentamos a una élite del poder estadounidense cada vez más degenerada.

C. Wright Mills puso al descubierto la realidad de que los miembros de la “élite del poder” estadounidense no eran genios, ni siquiera personas con un talento excepcional. A menudo eran incompetentes y se comportaban de forma imprudente y egocéntrica, lo que les llevaba a cometer errores monumentales. C. Wright Mills publicó su libro en 1956, en una época en la que la teoría pluralista dominaba las ciencias políticas y las teorías del equilibrio, como el análisis de sistemas y el funcionalismo estructural, habían conquistado el campo de la sociología en Estados Unidos.

Los académicos dominantes, así como los políticos liberales y conservadores, afirmaban con confianza que la economía keynesiana y la expansión del estado del bienestar habían traído la prosperidad universal a Occidente y el fin del conflicto de clases en las sociedades capitalistas avanzadas. Los politólogos proclamaban que el pluralismo de los grupos de interés, aunque imperfecto, era el mejor de todos los sistemas políticos posibles y la mejor aproximación a la democracia política que se podía lograr en una sociedad moderna compleja.

Todo el mundo reconocía que todavía existía desigualdad económica, social y política en Estados Unidos, pero los académicos, los ejecutivos

de las empresas y los funcionarios del Gobierno insistían en que cualquier desigualdad restante era el resultado de una meritocracia competitiva, en la que los hombres con habilidades, autodisciplina e inteligencia ascendían a puestos de liderazgo, desde dónde gestionaban sabiamente las empresas y el Estado en interés público.

Wright Mills fue casi el único en cuestionar estas optimistas suposiciones. Fue tildado de *enfant terrible* de las ciencias sociales estadounidenses y condenado al ostracismo por la mayoría de sus colegas académicos. Mills hirió la sensibilidad de los genios estables que gestionaban las empresas y el Estado, al tiempo que cuestionaba las ilusiones más preciadas de sus acólitos académicos.

Irresponsabilidad organizada

Como él mismo dijo en *The Power Elite*:

“Los hombres de los círculos más altos no son hombres representativos; su alta posición no es resultado de la virtud moral; su fabuloso éxito no está firmemente relacionado con una capacidad meritatoria. Los que ocupan los puestos de poder y autoridad son seleccionados y formados por los medios del poder, las fuentes de riqueza y los mecanismos de la fama que prevalecen en su sociedad. ... Comandantes de un poder sin igual en la historia de la humanidad, han triunfado dentro del sistema estadounidense de irresponsabilidad organizada”.

Mills expuso brillantemente al público la realidad de que los miembros de la “élite del poder” estadounidense no eran genios, ni siquiera individuos excepcionalmente talentosos. A me-

nudo eran incompetentes y se comportaban de manera imprudente y egocéntrica, lo que les llevaba a cometer errores monumentales. Esos errores tuvieron consecuencias catastróficas para la gente común, que parecía indefensa ante el enorme e irresponsable poder que ejercía la élite del poder, mientras que quienes cometían delitos en nombre del pueblo solían salir impunes con más dinero y fama.

Mills escribió muchos otros libros durante su corta vida, pero un hilo conductor en toda su obra fue el esfuerzo por identificar un agente revolucionario capaz de encabezar una transformación estructural del sistema capitalista, que, según advertía, se estaba descontrolando y conduciendo a una catástrofe global. Hacia el final de su vida, Mills publicó una “Carta a la nueva izquierda”, en la que planteaba la pregunta en términos claros:

¿Quiénes son los que están hartos? ¿Quiénes son los que están disgustados con lo que Marx llamó “toda la vieja basura”? ¿Quiénes son los que piensan y actúan de manera radical?

Esta sigue siendo la pregunta que se plantea la izquierda. En un momento en el que los expertos nos advierten de una posible Tercera Guerra Mundial, y con las universidades, los medios de comunicación, el derecho y la ciencia bajo el ataque de la élite del poder, vale la pena revisar la respuesta de Mills a esa pregunta, porque él veía estos dos acontecimientos como el resultado sistémico de una élite del poder decadente que se había vuelto tan depravada y degenerada como la aristocracia francesa del siglo XVIII.

Un tejano diferente

C. Wright Mills nació en Waco, Texas, en 1916. Creció en un Texas diferente al que conocemos hoy en día. Muchos de los residentes del estado —pequeños agricultores, trabajadores ferroviarios, trabajadores de los campos petrolíferos, estibadores y leñadores— seguían bajo el hechizo del populismo de la década de 1890. Esta corriente política progresista resurgió durante la

Gran Depresión, cuando muchos de los congresistas del estado se convirtieron en actores fundamentales del llamado eje Boston-Austin, que impulsó el New Deal de Franklin D. Roosevelt en el Congreso.

Aunque Mills creció en el cinturón bíblico de Texas y su madre, ama de casa, era una católica devota, desde muy joven abrazó el ateísmo científico de Clarence Darrow y rechazó el fundamentalismo protestante de William Jennings Bryan. Mills se graduó en la Escuela Técnica Superior de Dallas en 1934 y pasó un año miserable en la Universidad Texas A&M, donde los estudiantes, todos varones, estaban obligados a llevar uniformes de la Primera Guerra Mundial y a obedecer una estricta disciplina militar. Mills fue sometido a novatadas despiadadas, y la experiencia le dejó una aversión de por vida hacia el ejército estadounidense.

Mills se trasladó a la Universidad de Texas después de un año y se fascinó con la sociología, que en aquella época no era un departamento independiente, sino un campo de estudio estrechamente vinculado a la economía y las ciencias políticas. Mills se graduó en 1939 con una licenciatura en sociología y un máster en filosofía, y con la notable distinción de que ya había publicado dos artículos en el *American Journal of Sociology* y el *American Sociological Review*.

Mills dejó Texas para ir a la Universidad de Wisconsin-Madison, donde se había fundado uno de los primeros departamentos independientes de sociología por parte de luminarias progresistas como Edward A. Ross, Richard T. Ely y John R. Commons. Durante su estancia en Wisconsin, Mills conoció a Hans H. Gerth, un refugiado alemán, que colaboró con él en la primera traducción al inglés de una selección de obras de Max Weber, una colección que sigue siendo un libro de texto estándar en los cursos de sociología y ciencias políticas.

Mills obtuvo su doctorado en 1942 y fue nombrado profesor de sociología en la Universidad de Maryland, College Park, donde permaneció hasta 1945. Se trasladó a la ciudad de Nueva York

para trabajar en la Oficina de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Columbia y, en 1946, fue nombrado profesor adjunto de sociología en la Universidad de Columbia.

El hombre de la motocicleta

Los perfiles de Mills a menudo lo describían como un lobo solitario enfadado y rebelde, con la imagen de los años 50 de un James Dean o un Marlon Brando intelectual. Mills alimentaba esta imagen al ir cada día a su oficina en una motocicleta BMW, vestido con una chaqueta de cuero negro y botas de trabajo, en lugar del traje, la pajarita y los zapatos Oxford habituales entre sus colegas de la Universidad de Columbia.

Mills era un hombre grande e imponente, que se parecía más a su abuelo que a su padre. Mientras que su padre era un pequeño vendedor de seguros, su abuelo había sido un ranchero peleón y un ganadero de Texas cuya vida terminó en un tiroteo. Mills luchaba con su pluma y utilizaba las palabras en lugar de los puños para combatir a la élite del poder estadounidense, a la que consideraba tan miope e imprudente que estaba dispuesta a arriesgar la destrucción del mundo entero en pos de sus pasiones egocéntricas.

Los académicos convencionales generalmente rechazaban los estudios de Mills precisamente porque escribía en un inglés sencillo que podía ser fácilmente comprendido por lectores no académicos.

Sin embargo, decir la verdad de forma clara y sencilla no es una cualidad apreciada por la mayoría de los académicos y, en consecuencia, Mills no era muy querido por sus colegas universitarios, aunque gozaba de gran popularidad entre los estudiantes, los medios de comunicación y el público en general. Mientras se recuperaba de un infarto en un hospital de Nueva York, Mills solo recibió una tarjeta de “buena recuperación” de sus colegas universitarios. Estos últimos se quejaban de que era combativo y poco colegiado, principalmente porque los mencionaba por su nombre cuando criticaba su trabajo en libros, revistas y artículos periodísticos.

Mills criticó duramente a la sociología y la ciencia política dominantes por haberse convertido en “un conjunto de técnicas burocráticas”, “pretensiones metodológicas” y “concepciones oscurantistas”, que ocultaban el hecho de que los científicos sociales contemporáneos estaban obsesionados “con problemas menores que no guardaban relación con cuestiones de interés público”. Mills descartó la mayor parte de las ciencias sociales como grandes teorías cargadas de jerga sin aplicabilidad práctica a los problemas políticos y sociales reales o, por el contrario, como un campo obsesionado con la comprobación de hipótesis triviales, igualmente irrelevantes para un mundo al borde de la aniquilación nuclear.



Para su disgusto, Mills también publicaba regularmente artículos en medios populares como *Dissent*, *The New Republic* y *The New Leader*, lo que le valió un amplio seguimiento popular entre los liberales y la izquierda. Como resultado, Mills se convirtió en un intelectual público con influencia fuera de la universidad, y se le reconoce ampliamente como una figura intelectual importante en el surgimiento de una Nueva Izquierda en Estados Unidos y Europa.

Trágicamente, Mills murió a los cuarenta y seis años en 1952, tras haber sufrido problemas cardíacos durante toda su vida. Su prematura muerte se produjo justo cuando se identificaba a sí mismo como “un marxista puro” y abrazaba con optimismo los incipientes movimientos políticos insurgentes que surgían tanto dentro como fuera de Estados Unidos a principios de la década de 1960.

El concepto de la élite del poder

Aunque Mills es más conocido por *The Power Elite*, incluso liberales como el economista Robert Lekachman criticaron el libro, porque contenía demasiados “ecos marxistas y hobsónicos”. Lekachman no era el único que se preguntaba en qué se diferenciaba la concepción de Mills sobre la élite del poder de la anterior declaración del marxista Paul Sweezy de que el Estado es “un instrumento en manos de la clase dominante para imponer y garantizar la estabilidad de la propia estructura de clases”.

Mills, que era un gran conocedor de la teoría marxista, respondió a estas críticas en los siguientes términos:

“Nunca he sido lo que se denomina ‘marxista’, pero creo que Karl Marx es uno de los estudiosos más perspicaces de la sociedad que ha producido la civilización moderna; su obra es ahora un equipamiento esencial para cualquier científico social adecuadamente formado, así como para cualquier persona con una educación adecuada. Quienes dicen que oyen “ecos” de Marx en mi obra están diciendo que me he formado bien”.

Mills no tenía reparos en llamarse socialista, pero, desde el punto de vista metodológico, utilizaba un tipo de investigación sobre las estructuras de poder más influenciada por Max Weber y los teóricos de la élite italiana que por Karl Marx. Mills partía de la posición weberiana de que las sociedades consisten en órdenes económicos, políticos, sociales y culturales *analíticamente* distintos. En lugar de asumir que existía una relación teórica inherente entre cualquiera de estos órdenes, Mills argumentó que cualquier afirmación de este tipo tendría que seguir siendo una hipótesis hasta que (y en la medida en que) pudiera demostrarse como conclusión de una investigación empírica e histórica.

Mills argumentó que las instituciones organizan y despliegan el “poder” en la sociedad al otorgar a las personas que ocupan puestos de liderazgo en esas instituciones la autoridad para tomar decisiones sobre cómo desplegar los re-

curso de poder a su disposición. Los recursos de poder pueden incluir la riqueza, los ingresos, la fuerza y la coacción, el conocimiento y la información, el prestigio y la fama.

Por ejemplo, como institución económica, la empresa moderna confiere a su junta directiva y a sus directivos la autoridad para determinar el uso de cualquier recurso económico que la empresa posea o controle. El gobierno confiere a determinados cargos públicos la autoridad para emplear la coacción administrativa o la fuerza policial contra cualquiera que incumpla la ley. Como instituciones culturales, las escuelas y universidades certifican que determinadas personas poseen conocimientos científicos en campos específicos del saber. Las instituciones organizan los recursos de poder y, por lo tanto, confieren poder e influencia a aquellas personas que ocupan puestos de mando que les autorizan a asignar dichos recursos para fines concretos.

Las personas que ocupan puestos de autoridad institucional controlan diferentes tipos de poder: económico, político e intelectual. La autoridad para tomar decisiones institucionalmente vinculantes es lo que hace poderoso a un individuo o a un grupo de individuos. Así, Mills argumentó que se puede atribuir poder a determinados grupos de individuos en la medida en que ocupan las cimas de las organizaciones sociales que controlan la riqueza, la fuerza, el estatus y el conocimiento en una sociedad concreta.

Estas son las personas que Mills identifica como “élites”, y había muchos tipos de élites en la sociedad: élites corporativas, élites políticas, élites militares, élites profesionales, élites sociales, élites famosas, élites intelectuales y élites culturales. Una *estructura de poder* es una distribución identificable de los recursos de poder organizada por las relaciones forjadas entre las principales instituciones y élites de una sociedad concreta. Siguiendo la tradición de la teoría italiana de las élites, iniciada por Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca, Mills concibió las revoluciones como una “circulación de élites”, un proceso por el cual una

élite envejecida y decadente es desplazada por una élite nueva y más vigorosa.

Alianza de poder

Sin embargo, Mills se apartó de Pareto y Mosca al argumentar que no todos los recursos institucionales son iguales y, por lo tanto, no todas las élites son iguales en las sociedades capitalistas. Argumentó que tres instituciones se sitúan por encima de todas las demás en cuanto a la enormidad de los recursos de poder que controlan en la sociedad moderna: la empresa, el Estado (la burocracia ejecutiva) y el ejército.

Así, la “élite del poder” de Mills era una alianza informal entre los directores ejecutivos de las grandes empresas, los principales mandos militares del Pentágono y la dirección ejecutiva del Estado. Las celebridades de Hollywood se mezclaban habitualmente con la élite del poder para conferir un velo de ostentación y glamour a personalidades que, de otro modo, serían morbosas, y para distraer eficazmente a las “masas” desorganizadas, luchadoras y temerosas de su existencia ordinaria y precaria.

Mills definió a la élite del poder como “compuesta por hombres” que están “en posiciones para tomar decisiones con consecuencias importantes”:

“Están al mando de las principales jerarquías y organizaciones de la sociedad moderna. Gobiernan las grandes corporaciones. Dirigen la maquinaria del Estado y reclaman sus prerrogativas. Dirigen el establishment militar. Ocupan los puestos de mando estratégicos de la estructura social, en los que ahora se concentran los medios efectivos del poder, la riqueza y la fama de los que disfrutan”.

«Mills expuso brillantemente al público la realidad de que los miembros de la 'élite del poder' estadounidense no eran genios, ni siquiera individuos excepcionalmente talentosos.»

Estas tres élites competían entre sí por el poder y la influencia, pero también cooperaban en una alianza flexible para formar lo que Mills denominó la élite del poder. El principal interés de la élite del poder era mantener y ampliar su poder mediante el enriquecimiento económico, la corrupción política y la guerra continua.

Esto requería que sus miembros crearan y mantuvieran un estado de miedo y precariedad perpetuos entre las masas, al tiempo que prometían seguridad y protección frente a los numerosos enemigos internos y externos del Estado que amenazaban el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. Aunque los diferentes elementos de la élite del poder competían entre sí por la influencia, rápidamente cerraban filas para defender el orden existente que los mantenía en el poder cuando se veían desafiados desde abajo o desde fuera. Estos desafíos dieron lugar a frecuentes estados de emergencia que se utilizaron para justificar el ejercicio del secreto y el poder sin ley.

Por otro lado, el interés de las masas era sobrevivir, pasar un día más sin perder sus empleos, sin sufrir una enfermedad catastrófica, sin ser reclutadas para una guerra extranjera o sin morir en un holocausto nuclear. En este sentido, el concepto de “poder” de Mills se acercaba mucho más al de los teóricos italianos de la élite que al de Marx, porque su teoría de la élite del poder tendía a dejar a “las masas” sin poder por decreto. Si el poder es una función de la toma de decisiones que conlleva ocupar los puestos de mando de las principales instituciones de la sociedad capitalista, entonces las masas están, por definición, prácticamente excluidas del ejercicio del poder y son impotentes.

En busca de una agencia revolucionaria

Aunque los marxistas criticaron *The Power Elite* desde una perspectiva teórica, su libro también fue muy admirado por la izquierda estadounidense. Abrió un espacio ideológico para que

los marxistas y socialistas volvieran a entrar en los debates políticos e intelectuales estadounidenses que los habían marginado desde el final de la Gran Depresión. En su análisis de la “sociedad de masas”, Mills descartó la teoría pluralista de la ciencia política dominante “como un conjunto de imágenes sacadas de un cuento de hadas”. En su lugar, afirmó que “la doctrina marxista de la lucha de clases” estaba “ahora más cerca de la realidad que cualquier supuesta armonía de intereses”.

Al principio de su carrera, Mills tenía la esperanza de que surgiera una nueva élite de líderes sindicales, a los que llamaba “los nuevos hombres del poder”, como contrapunto progresista a la élite del poder, y planteó la posibilidad de que Estados Unidos estuviera al borde de una circulación revolucionaria de élites. En 1948, Mills argumentó que los líderes sindicales eran actores políticos estratégicos, que ocupaban las alturas dominantes de los grandes sindicatos industriales. Podían movilizar a millones de miembros y millones de dólares para campañas políticas, y tenían la capacidad de paralizar la economía capitalista con huelgas industriales. Los sindicatos industriales y sociales estaban emergiendo como centros de una contracultura —una nueva sociedad en el seno de la antigua— con bancos sindicales, periódicos sindicales, universidades sindicales, canciones sindicales y teatros sindicales.

A mediados de la década de 1950, sin embargo, Mills se alejó de esta posición. Lamentó que, en lugar de participar en luchas económicas y políticas, los sindicatos se hubieran “enredado profundamente en rutinas administrativas con las empresas y el Estado”. En un nuevo acuerdo político que se conoció como “corporativismo”, los dirigentes sindicales se integraron en la estructura de poder capitalista como élites subordinadas no gobernantes, que obtenían beneficios personales de esa estructura de poder al ayudar a mantener la paz de clases y el equilibrio político.

Al mismo tiempo, los estudiosos contemporáneos a menudo exageraban el rechazo de Mills a la clase obrera como agente de transformación social. No hay duda de que Mills rechazaba la “metafísica laboral” heredada de lo que él llamaba “marxismo victoriano”. En su “Carta a la Nueva Izquierda”, Mills instaba a los socialistas a “olvidar el marxismo victoriano, salvo cuando lo necesiten, y volver a leer a Lenin (con cuidado) y también a Rosa Luxemburgo”. Al mismo tiempo, escribió: “Por supuesto, no podemos” descartar a la clase obrera”. Pero debemos estudiar todo eso, y con una nueva perspectiva. Cuando el trabajo existe como agencia, por supuesto que debemos trabajar con él, pero no debemos tratarlo como la palanca necesaria”.

Mills observó que, por el momento, el “proletariado”, tal y como lo concebía Marx, era ahora más activo como agente revolucionario en las llamadas sociedades en desarrollo del Tercer Mundo. Aunque sugirió que la clase obrera podría volver a surgir como agente revolucionario en las sociedades capitalistas avanzadas en algún momento del futuro, no veía ninguna razón para esperar un momento futuro que podría ocurrir o no durante nuestra vida. En consecuencia, Mills centró cada vez más su atención en los movimientos políticos insurgentes de los trabajadores industriales y los campesinos de América Latina, África y Asia.

Además, tras publicar *The Power Elite*, Mills comenzó a moverse en los círculos intelectuales marxistas. En 1957, viajó fuera de Estados Unidos por primera vez en su vida, donde visitó la London School of Economics y conoció al politólogo marxista Ralph Miliband. Enseñó en Dinamarca y viajó a Polonia, donde conoció a Adam Schaff y Leszek Kołakowski. Realizó dos viajes a la Unión Soviética en 1960 y 1961, y visitó Cuba en 1960 para recopilar material para su libro *Listen Yankee!*

Mills se mostraba cada vez más optimista sobre las perspectivas de una reforma política democrática en Europa del Este. Estaba convencido, aunque erróneamente, de que los intelectua-

les disidentes y liberales de Hungría, Polonia, Checoslovaquia y la URSS acabarían triunfando y liderando el camino hacia un socialismo genuinamente democrático. Durante su viaje a Cuba, entrevistó a Fidel Castro, quien afirmó haber leído *The Power Elite* y haber sido influenciado por él durante la Revolución Cubana. Por muy sombrío que pareciera el panorama a finales de la década de 1950, al menos había atisbos de esperanza en el horizonte.

La nueva clase media

Cuando las esperanzas de Mills en los sindicatos se vieron defraudadas, se preguntó si habría otras fuentes de poder popular que pudieran desafiar a la élite del poder en las sociedades capitalistas avanzadas. Si no era la clase trabajadora, ¿qué hay de la clase media, que los politólogos convencionales siempre habían descrito como la columna vertebral de la democracia estadounidense?

En su libro de 1951, *White Collar: The American Middle Classes*, Mills analizó la política y la cultura de las nuevas clases medias de cuello blanco, que incluían a todo el mundo, desde secretarías y maestros de escuela hasta vendedores, ingenieros y contables. Llegó a la conclusión de que la aparición de las nuevas clases medias contradecía la predicción de Marx de que la sociedad capitalista se polarizaría cada vez más entre un proletariado en constante crecimiento y una clase capitalista cada vez más reducida. Mills argumentó que la aparición de las clases medias de cuello blanco también puso fin al mito jeffersoniano del agricultor independiente y el pequeño empresario, que estaban siendo desplazados cada vez más por el auge de las empresas modernas y el Estado.

Mills argumentó que, en contraste con la independencia y el individualismo de la antigua clase media de pequeños propietarios, el empleado de cuello blanco era un hombre de organización. El empleado de cuello blanco era “siempre el hombre de alguien, de la corporación, del gobierno, del ejército”. Mills se burlaba de las cla-

ses medias de cuello blanco, que como grupo estaban

“... distraídas y desatentas a cualquier tipo de preocupación política. Son ajenos a la política. No son radicales, ni liberales, ni conservadores, ni reaccionarios; son ‘inactivos’, están al margen. Si aceptamos la definición griega de idiota como un hombre privatizado, entonces debemos concluir que la ciudadanía estadounidense está compuesta en su mayor parte por idiotas”.

La joven intelectualidad

No hay duda de que Mills era pesimista sobre las perspectivas de cambio estructural en las sociedades capitalistas avanzadas. Pero en 1960, tras una tortuosa década de “estado de ánimo conservador”, declaró que “estamos empezando a movernos de nuevo”. Mills sugirió que una “joven intelectualidad” estaba emergiendo como nuevo agente de cambio estructural tanto en las sociedades capitalistas como en las comunistas. Se trataba de personas cansadas de las mismas tonterías de siempre que les imponía una élite del poder irresponsable y temeraria.

La joven intelectualidad, tal y como la concebía Mills, incluía a estudiantes, jóvenes profesores, maestros radicales, periodistas, artistas y actores, y autores independientes. En su “Carta a la Nueva Izquierda”, Mills identificó a este grupo como una fuente potencial de cambio:

“Teniendo en cuenta este problema de la agencia, llevo varios años estudiando el aparato cultural, los intelectuales, como una posible agencia de cambio inmediata y radical. Durante mucho tiempo, no me gustaba esta idea mucho más que a muchos de ustedes, pero ahora, en la primavera de 1960, resulta que puede ser una idea muy relevante ... En todo el mundo —dentro del bloque, fuera del bloque y entre ambos— la respuesta es la misma: es la joven intelectualidad ... Ahora debemos aprender de su práctica y elaborar con ellos nuevas formas de acción”.

En vísperas de los años sesenta, Mills fue profético al identificar a la joven intelectualidad como los nuevos agentes de la revolución social, aunque no entendía por qué el centro de la acción revolucionaria parecía haber pasado de la clase obrera a la intelectualidad. Esta laguna en su pensamiento se debía en parte al hecho de que Mills nunca articuló una teoría del Estado ni una teoría del desarrollo capitalista.

No fue hasta una década más tarde cuando Nicos Poulantzas proporcionó la explicación que eludió a Mills. Poulantzas argumentó que, en las sociedades capitalistas avanzadas, son los aparatos ideológicos del Estado —escuelas, universidades, medios de comunicación e instituciones culturales— los que tienen el mayor nivel de autonomía relativa dentro de la estructura general del aparato estatal capitalista. Especialmente en las democracias liberales, estas instituciones solo están vagamente conectadas con los aparatos estatales represivos, ya que gozan de la protección legal y constitucional de la autonomía profesional, la libertad académica y la libertad de expresión. Por lo tanto, son más fácilmente penetradas por intereses no capitalistas que la burocracia estatal, el poder judicial, la policía y el ejército.

Mills fue profético al identificar a la joven intelectualidad como los nuevos agentes de la revolución social.

Poulantzas argumentó que “los aparatos ideológicos del Estado muestran *un grado y una forma de autonomía relativa* que las ramas del aparato represivo del Estado no poseen”. Por lo tanto, los aparatos ideológicos del Estado son los más porosos y los más fáciles de penetrar por las clases y fracciones no dominantes con el fin de deslegitimar y desafiar al Estado capitalista.

Como señaló Poulantzas, los aparatos ideológicos del Estado

“...son, de hecho, los aparatos más capaces de concentrar en sí mismos el poder de las clases y

fracciones no hegemónicas. Por lo tanto, son tanto el ‘refugio’ preferido de esas clases y fracciones como su botín preferido. Las clases y fracciones de estos aparatos pueden incluso no ser aliadas de la clase hegemónica, sino estar en amarga lucha contra ella”.

Por eso, en una transición del populismo autoritario al estatismo autoritario y luego al fascismo en toda regla, los aparatos ideológicos del Estado son objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de la élite del poder. Para esta última, se hace cada vez más necesario subordinar esos aparatos ideológicos al aparato represivo del Estado.

Mills reconoció que, a medida que la élite del poder se degenera cada vez más, a sus acólitos intelectuales les resulta cada vez más difícil formular justificaciones ideológicas razonables para sus acciones corruptas e irresponsables. En estas circunstancias, la élite del poder recurre a la represión intelectual contra aquellos que llaman la atención sobre su declive político, es decir, la intelectualidad que trabaja en universidades, museos, artes, institutos científicos, entretenimiento y medios de comunicación.

La intelectualidad estadounidense difícilmente puede considerarse hoy en día la vanguardia de la agencia revolucionaria —se encuentra muy a la defensiva—, pero no hay duda de que la élite del poder ha declarado la guerra de clases a la intelectualidad. En 1962, Mills advirtió a la intelectualidad que se encontraba en primera línea de la guerra de clases en las sociedades capitalistas avanzadas. En 2026, ya no se trata solo de una guerra de palabras, porque la coacción burocrática y la violencia policial son las herramientas inmediatas preferidas por aquellos elementos de la élite del poder que ocupan las alturas dominantes de nuestras instituciones intelectuales, educativas y culturales. ■

El rol de los grupos de interés en la conversación pública

por Emiliano Vitaliani

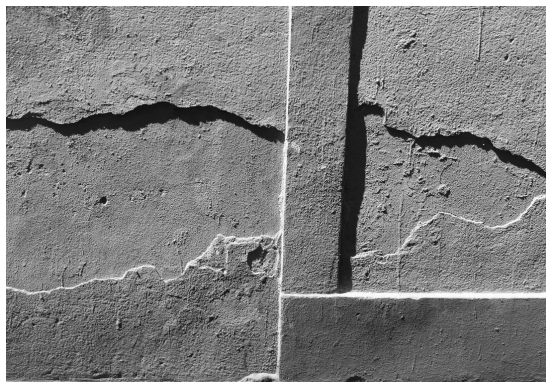
los funcionarios estatales y sus defensores académicos

10 de febrero de 2026

Es difícil sobreestimar el lugar de los grupos de interés en la política. La reforma laboral propuesta por el gobierno fue criticada por responder a los intereses de los empresarios y está siendo resistida por la CGT. Techint perdió hace algunos días una licitación para hacer un gasoducto, y tanto UIA como los sindicatos empezaron a evaluar la forma en la que iban a reaccionar, ya que la elección de una empresa india en la licitación afectaba sus intereses. Si miramos al extranjero, el acuerdo UE-Mercosur recibió una fuerte oposición de parte de los productores rurales, quienes lograron que países como Francia votaran en contra de su aprobación. El accionar de diferentes corporaciones parece estar en el centro de nuestra vida política.

La extendida presencia de grupos de interés en la vida política no parece problemática para quienes sostienen una concepción agregativa de la democracia. Al final del día, estos grupos (al menos cuando funcionan virtuosamente) defienden los intereses de aquellos a quienes representan e intentan influir en las decisiones que los afectan. El lugar de los grupos de interés en la democracia, sin embargo, despierta más riesgos para quienes sostienen una concepción deliberativa. Una concepción de este tipo espera que las decisiones surjan de las mejores razones disponibles y no de la agregación de intereses particulares. En ese sentido, la democracia deliberativa abandona el carácter individualista de las teorías agregativas y concibe a la democracia como una tarea pública. El rol de un conjunto de

grupos que están diseñados para defender los intereses particulares de un grupo representa, por lo tanto, un desafío particular para la democracia deliberativa.



Una primera aproximación a este problema podría ser simplemente rechazar la legitimidad de los grupos de interés como actores relevantes de nuestra democracia. Dado que esperamos que los actores democráticos estén preocupados por el interés general y no por sus beneficios particulares, no deberíamos promover que los grupos de interés controlen la discusión pública en la manera en la que lo hacen.

Esta respuesta, sin embargo, pecaría de simplista. En primer lugar, existen situaciones en las que el bien común está compuesto por los intereses individuales.¹ Imaginemos que estamos cursando a una materia y que la profesora no puede ir a la siguiente clase, por lo que necesitamos reprogramarla. Una solución razonable sería usar un programa en donde cada uno diga cuándo puede asistir y elegir el día que sea me-

¹Jane Jebb Mansbridge et al., «The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy», *Political Science, Raisons politiques* 42, n.º 2 (2011): 47-82.

jor para la mayoría. En un caso así, no existe una solución mejor por fuera de los intereses individuales, por lo que la expresión del interés individual es en sí misma una forma de aportar información sobre el bien común.

Hay un tipo distinto de situaciones que suele quedar opacado cuando pensamos en política pública: aquellas en las que las opciones disponibles no responden a una lógica de suma cero. Muchas veces, es cierto, decidir implica repartir recursos escasos u optar entre valores en tensión. Pero no siempre es así. En algunos casos, existen alternativas en las que todos los actores involucrados pueden ganar. En ese contexto, la expresión del interés propio deja de ser un obstáculo y pasa a cumplir una función distinta: al hacer visible una determinada preocupación, contribuye a ampliar la información disponible en el espacio público y a orientar la decisión hacia soluciones que toman en cuenta ese interés sin perjudicar a otros.

Los programas de estabilización económica ofrecen un ejemplo útil para pensar este tipo de dinámicas. Muchos de ellos incluyen acuerdos de precios y salarios, lo que permite reducir la inflación. Si esto se hace sin alterar la distribución de la riqueza, el resultado es preferible para todos frente a escenarios de inflación elevada. Sin embargo, estas soluciones no surgen de manera espontánea: requieren coordinación. Y es aquí donde los grupos de interés muestran otra de sus funciones posibles. No solo ayudan a identificar salidas que mejoran la situación general, sino que también hacen viable su implementación, al canalizar compromisos y expectativas sin los cuales ese tipo de acuerdos difícilmente podría sostenerse. Por supuesto, esto asume que todos los grupos afectados participaron de esta discusión, lo que no es siempre así. Sin embargo, es al menos posible imaginar una situación como la que describí.

A pesar de que en los contextos que acabo de describir la persecución de un interés particular en tanto tal no resulta problemática, no todos los contextos caen bajo estas descripciones. Muchas veces, la persecución del interés de un grupo de actores perjudica a otros y por lo tanto necesitamos una forma de resolver que sea distinta a la persecución de intereses particulares. Pensemos en la reforma laboral. Es posible que esta reforma afecte a los actuales trabajadores registrados. En ese sentido, el grupo de interés que representa a los trabajadores registrados tendría motivos para oponerse. Sin embargo, también es posible que afecte positivamente a los trabajadores no registrados si es que la reforma es efectivamente un buen medio para promover la formalización del trabajo. Un aumento en la demanda de trabajo incluso llevaría a que algunos desempleados se incorporen al mercado de trabajo. Más aún, tal vez sea una buena o una mala reforma en materia de aportes jubilatorios, lo que afectaría no solo a los trabajadores, sino a los jubilados.

Cuando no nos encontramos en una situación como estas, sin embargo, perseguir el interés de un grupo llevará a menoscabar el interés de otro. La persecución de intereses privados, sin embargo, puede representar una oportunidad para la deliberación pública. La reivindicación de un grupo de interés puede reflejar un problema más amplio y general. Si los docentes hacen huelga porque no pueden vivir con su salario, eso dice algo sobre la situación de la educación. Si bien el ingreso de un conjunto particular de trabajadores no es, en sí mismo, un problema público², el hecho de que tengamos un sistema educativo disfuncional, en el que existen pocos incentivos para trabajar, es una cuestión que afecta los principios básicos de nuestra organización colectiva. Así, a través de la persecución de un interés particular, podemos descubrir algo acerca de un grupo más amplio.

² Asumo que esta discusión opera por sobre el umbral del salario mínimo, es decir por sobre el umbral que el estado considera apropiado para garantizar el salario digno de forma económicamente viable. Si ese umbral no reflejara un salario digno, entonces estaríamos en presencia de un problema público como en el caso de la educación.

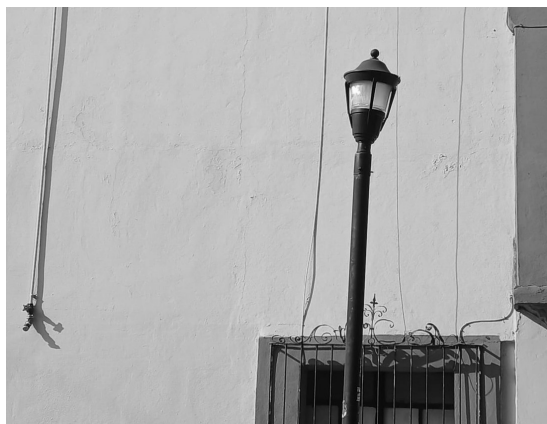
«La extendida presencia de grupos de interés en la vida política no parece problemática para quienes sostienen una concepción agregativa de la democracia.»

Sin embargo, no todos los casos son como el del reclamo salarial de los docentes. Es posible pensar en casos en los que el autointerés no está relacionado al interés público. En primer lugar, existen casos en los que está justificado afectar intereses particulares, más allá del reclamo de ese sector. Por supuesto, cuáles son esos casos dependerá de la ideología de cada uno, pero estoy seguro de que todos tenemos algunos casos en mente. Por ejemplo, subir las alícuotas del impuesto a las ganancias perjudicará a los trabajadores de ingresos más altos, pero puede estar justificado por criterios distributivos. Un segundo grupo de casos presenta un desafío mayor. En estos casos, es posible que el reclamo del grupo particular refleje un problema general, pero que la solución ofrecida no tienda a solucionarlo, sino simplemente a solucionar el problema para ese grupo. Un ejemplo de este tipo de situación apareció con el “dólar soja”. Allí, la brecha cambiaria representaba un problema para todos los que exportaban. Sin embargo, en lugar de usar el caso de los sojeros para discutir el cepo como política pública, los exportadores negociaron una solución que los alcanzó solo a ellos.

Los grupos de interés, entonces, pueden jugar un rol virtuoso en la vida pública, pero solamente en la que medida en la que actúen de forma pública. Muchas veces escuchamos que las políticas deben ser discutidas “con todos los sectores”. Sin embargo, es imposible discutir en privado con todos los sectores afectados. La centralidad de los productores rurales en la Unión Europea no debería hacernos perder de vista que todos los europeos podrían acceder a alimentos más baratos si se aprobara el tratado con el Mer-

cosur. Por el contrario, para que los intereses particulares revelen problemas generales y contribuyan a buenas decisiones, deben expresarse de forma tal que expresen una preocupación general y no sectorial.

La deliberación pública exige justificar las demandas en términos aceptables para todos, lo que excluye ciertos intereses egoístas y somete los restantes a crítica y refinamiento. Esta “traducción” de intereses privados en argumentos públicos es necesaria para la deliberación y puede vincular problemas individuales con problemas colectivos. Más aún, aunque la democracia deliberativa no reduce la participación al interés personal, los incentivos privados siguen influyendo en el comportamiento político. Los grupos de interés, precisamente porque están afectados, tienen información relevante y fuertes incentivos para participar públicamente.³ Fomentar su intervención en la esfera pública puede aumentar la participación, mejorar las decisiones y reducir la alienación ciudadana, contribuyendo a un mayor sentido de apropiación democrática.



Un problema que aparece en este punto es que no todas las personas están representadas por la suma de estos grupos. Incluso si los grupos de interés plantearan sus demandas particulares en términos públicos, estas demandas tal vez afecten a grupos no organizados, sesgando las decisiones en favor de los grupos organizados. Una forma en la que esto sucede es la falta de agru-

³Mancur Olson, *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups* (1971).

pación de algunos intereses. Tal vez el ejemplo más obvio de esta situación sean los problemas de justicia intergeneracional, ya que los nacidos y los menores no pueden organizarse políticamente. Pero también es posible pensar, en el contexto actual, en los desempleados o grupos cuyo beneficio de una cierta política será menor en términos individuales, aunque grande en un sentido agregado. Este problema parece difícilmente resoluble, y en estos casos la participación de los grupos de interés sería mucho más problemática.

Existe una segunda forma en la que la totalidad de los grupos de interés puede no representar a la totalidad de la población. Cuando pensamos en grupos de interés, pensamos en instituciones como la UIA, la CGT o la Sociedad Rural. Sin embargo, es posible que exista un problema representativo, y que esas organizaciones realmente no representen los intereses de su grupo.⁴ En un caso de este tipo, los grupos de interés ya no cumplirían las funciones virtuosas que des-

cribí más arriba, sino que simplemente operarían como distorsionadores del debate público, dejando los intereses de los representados de lado.

Obviamente ninguna práctica política no encaja a la perfección con los tipos ideales que construimos. Sin embargo, sí es posible usarlos de guía para pensar nuestra práctica política. Así, cabe preguntarnos dónde se ubica el corporativismo argentino en esta clasificación. Responder esta pregunta me excede tanto a mí como a este artículo. Sin embargo, sospecho que nos encontramos más cerca de las situaciones problemáticas que de las virtuosas. En ese contexto, creo que es momento de pensar tanto el funcionamiento de estos grupos de interés como su rol en la conversación pública. Si estos grupos no cumplen una función virtuosa, la democracia se transforma en la mera enunciación de problemas particulares seguidos de una negociación desnuda, y su carácter público desaparece. ■

«La reforma laboral propuesta por el gobierno fue criticada por responder a los intereses de los empresarios y está siendo resistida por la CGT.»



«Más aún, tal vez sea una buena o una mala reforma en materia de aportes jubilatorios, lo que afectaría no solo a los trabajadores, sino a los jubilados.»



⁴La posible disociación entre representados y representantes apareció con claridad en las últimas elecciones presidenciales. Pedro Rosemblat afirmó haber estado seguro de que Massa ganaría porque las “organizaciones libres del pueblo” lo apoyaban. Sin embargo, muchas de las personas representadas en esas organizaciones no compartieron ese apoyo. Allí, o estas organizaciones no representaron a la mayoría de la población, o lo hicieron defectuosamente.

Una Noche en el Honorable Senado Argentino

por Gustavo Maurino

El estruendoso silencio constitucional en la cocina de las leyes

13 de febrero de 2026

El senado argentino acaba de dar media sanción a un proyecto de ley que transforma sustancialmente la estructura, principios, dinámicas y regulaciones de las relaciones individuales y colectivas de trabajo.

La sesión —de esas típicamente catalogadas como “maratónica” por la prensa— comenzó por la mañana, duró más de 15 horas, contó con varias decenas de oradores y finalizó cerca de la 4:00 AM.

En el transcurso del trámite parlamentario diversas negociaciones secretas, presuntamente con líderes políticos y sindicales y gobiernos provinciales, dieron lugar a algunas modificaciones al proyecto y permitieron una aprobación con una mayoría cómoda formada por diversos partidos.

Una sesión extraña: ¡Hay fuego en la cocina!

En la extensa sesión —se puede consultar aquí la versión taquigráfica del 11/02/26— ocurrió algo llamativo: Una decena de senadorxs, de diversas bancadas, afirmó que el proyecto de ley contenía disposiciones incompatibles con la Constitución Nacional y que violaba y desconocía gravemente derechos constitucionales. Desde el comienzo mismo del debate, unx tras otrx, con diversos tonos y énfasis, insistieron en este punto —por ejemplo, lxs Senadorxs Recalde, Lousteau, Mayans, Lewandowski, Fernández Sagasti, Marks, Capitanich, Bensusán, Rejal, Bahl.

En un sistema de gobierno constitucional, donde el respeto por —y cumplimiento de— las promesas y garantías constitucionales son la base de legitimidad y obligatoriedad de toda decisión pública y de todo acto de gobierno, esta cla-

se de manifestaciones, reclamos y alertas, debería equivaler a que alguien grite “¡fuego!”. Al menos para quienes tienen la Constitución en mente.

Dicho sea de paso, las alertas resultaban evidentes, dado que los fines y los medios del proyecto de ley se enfrentan de manera bastante directa y aparente con los compromisos constitucionales del Art. 14 bis – e.g. una ley para la cual se reivindica la finalidad de facilitar y abaratar en todo lo posible los despidos sin causa frente a una Constitución que ordena proteger a los trabajadores contra los despidos arbitrarios; una ley cuyas medidas restringen significativamente el ejercicio del derecho de huelga garantizado por la Constitución, etc. No es mi punto aquí, analizar si las alarmas eran o no correctas —y efectivamente hay fuego y se está incendiando la Constitución. Lo que me interesa destacar es que en nuestro sistema institucional, tales alarmas son prácticamente lo más grave que puede ocurrir en un debate parlamentario.

Por eso, a medida que se sucedían las expresiones en ese sentido, aparecía la pregunta obvia: ¿Nadie había analizado la constitucionalidad de la ley durante el trámite previo? La respuesta también fue obvia.

El proyecto había sido considerado y dictaminado por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda. Como es bien sabido, el Senado tiene una Comisión de Asuntos Constitucionales a la que le corresponde “...dictaminar sobre lo relativo a todo asunto de directa e inmediata vinculación con la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional y de los principios en ella contenidos...También entenderá en todo otro asunto vinculado a la ciencia y al derecho cons-

titucional”. El proyecto de ley nunca fue tratado por dicha comisión.

Pero mientras la sesión avanzaba, sucedía algo que era aún más llamativo: sucedía el silencio.

En ningún momento, durante esas largas 15 horas, se registró alguna respuesta, argumentación o réplica que abordara con el mínimo detenimiento y consideración las alegaciones de vicios de inconstitucionalidad en el proyecto. Ninguna. Ni por parte de los miembros informantes, ni de ningún otro miembro del Senado.

Nadie ni nada parecía inmutarse ni conmoverse en lo más mínimo por el hecho de que la Cámara avanzaba, en una especie de marcha zombie, hacia la votación de una ley que explícitamente denunciada como inconstitucional por los voceros de diversas bancadas parlamentarias.

En la cocina donde se crean las leyes, esas que están sujetas a la Constitución, mientras se elabora una que es constitucionalmente trascendente, una docena de cocinerxs grita “¡fuego!, la receta no está permitida por la Constitución”, y el resto sigue cocinando, como sin nada, sin inmutarse, hasta terminar el plato, presumiblemente envenenado, para ofrecérselo a la ciudadanía.

¿Cómo es que nuestro sistema institucional funciona de esta manera?, ¿Cuál es el sentido de la supremacía constitucional en el poder legislativo?, ¿Qué deberes tiene el Congreso, y que tenemos derecho a esperar y exigirle cuando trata leyes que constitucionalmente controvertidas?, ¿Puede el Congreso simplemente ignorar la consideración de tales alarmas?, ¿Cuál es el valor de una ley constitucionalmente controvertida cuando el Congreso no provee razones para reivindicar la constitucionalidad?

Política y Derecho. Constitución y Democracia

A menudo acudimos a ciertas distinciones y simplificaciones analíticas para explicarnos mejor los presupuestos y funcionamientos de nuestras prácticas sociales e institucionales.

Así, se suele diferenciar el ámbito de la política —caracterizado como el espacio de la voluntad, el intercambio negociado y la lucha por el poder— y el del derecho —el espacio de la razón, la ponderación de principios y la imparcialidad. Del mismo modo, se diferencia el espacio de la democracia —el juego fluido de mayorías y minorías en busca de satisfacer las preferencias sociales— y el de la Constitución —el reino estable de las reglas y los principios normativizados, orientados a servir a la justicia.

Como toda simplificación analítica, estas distinciones pueden ayudar a la claridad conceptual, pero no permiten interpretar ni evaluar cabalmente las prácticas sociales, su sentido y justificación.

En nuestras sociedades esperamos que la política se desenvuelva dentro de un marco moral —si es la guerra por otros medios, la clave está en que esos medios sean diferentes—, y ese marco moral está institucionalizado en el derecho. También esperamos que el derecho sea sensible a —e incorpore funcionalmente— la evolución de los acuerdos políticos y morales de la sociedad y no esté desconectado de ellos como si las normas legales fueran un sistema autónomo (autopoyético).

Por otro lado, entendemos que la práctica del autogobierno democrático debe construir una sociedad justa, y que su legitimidad requiere que realice y honre nuestros derechos fundamentales. Y correlativamente entendemos que la Constitución solo es digna de respeto en cuanto es construida por —en— una democracia, y en la medida en que ella misma construye y fortalece el desarrollo de la institucionalidad democrática —y no la limita, o impide.

Nuestra práctica cívica, nuestras convenciones, presuposiciones y expectativas; nuestros acuerdos y desacuerdos acerca de lo que podemos o no hacer y lo que podemos o no esperar y exigir de nuestra vida social institucionalizada, son —necesariamente— interpretaciones acerca del sentido y valor de la política y el derecho, la constitución y la democracia.

«Lo que me interesa destacar es que en nuestro sistema institucional, tales alarmas son prácticamente lo más grave que puede ocurrir en un debate parlamentario.»

La política está juridificada, el derecho está politizado; la democracia debe estar constitucionalizada y la constitución debe estar democratizada.

Y cada comunidad política construye y consolida —o destruye y desintegra— su propio balance, en un experimento colectivo, intergeneracional, que no tiene fin.

Al final del día no hay nada más que nuestras prácticas y el sentido que construimos para ella. La tragedia ocurre cuando nuestras prácticas pierden sentido, cuando ya no podemos adscribirle valor, justificación. Cuando son un sinsentido.

Tristemente, desde hace tiempo se advierte que el Congreso argentino, como tantos otros entornos institucionales, discurre su existencia y funcionamiento cotidiano al borde del sinsentido —no me atrevo a decir desde qué lado del borde.

Volvamos ahora a la noche del Senado argentino.

¿Un Congreso al margen de la Constitución?

Cuando se discute sobre el “control de constitucionalidad de las leyes” en países —como Argentina— en los que el poder judicial cuenta con la atribución fundamental de ejecutar esa tarea, la conversación política y teórica gira fundamentalmente acerca de las condiciones y alcances que debe tener esa delicada competencia judicial, cómo balancearla para que la constitución no ahogue la democracia, cuál es el grado

de deferencia que debe tener frente a los órganos “políticos”, etc.

Enfocados en ese ámbito institucional específico, y en los deberes constitucionales del poder judicial, solemos perder de vista y quitar atención al punto acerca de qué es exigible y esperable del Congreso, de los órganos políticos en general, en la consideración de la constitucionalidad de las leyes que proponen, consideran y sancionan, y qué debería ocurrir cuando fallan en cumplir tales exigencias.

El caso de la pasada noche en el Senado nos provee un buen ejemplo para repasar algunas cosas que acaso deberían ser obvias, y que cuando son olvidadas y negadas, deberían generar consecuencias significativas, si es que la democracia y la constitución van a caminar juntas, y nuestras prácticas políticas van a tener algún sentido y valor de legitimidad.

El punto más importante para recordar aquí es que el Congreso tiene un deber fundamental, propio, e inexcusable de interpretar la Constitución, evaluar el alcance de sus mandatos y analizar si las leyes que trata son consistentes con ellos. Debe hacerlo de manera pública, detenida y expresa.

El Poder Legislativo —como toda institución pública— debe ser un intérprete —activo y fiel— de la Constitución.

Para volver a las distinciones analíticas previas, el Congreso no es —ni debe ser— un ámbito de “pura política” —de guerra— sin derecho, ni de “pura democracia” —preferencias de mayorías— sin Constitución.

El “silencio” —peor aún, el desdén— parlamentario ante una controversia constitucional sería, relativa a una ley que está considerando formalmente, es una defección institucional, una abdicación política y una traición constitucional.

El pueblo está sujeto a la obligatoriedad de las leyes que resultan de un proceso de discusión pública institucionalizado, en el que se construyen razones justificatorias suficientes, que son sometidas a la crítica pública. No está sujeto a la

imposición de caprichos mayoritarios sin razones. La mayoría no es una razón. Las razones de la mayoría lo son. Una mayoría sin razones no es autoridad democrática, es poder desnudo.

Bien puede ser que las razones justificatorias provistas para una ley no sean consideradas correctas, ganadoras, para una parte de la sociedad. De hecho es habitual en sociedades plurales. Pero no puede ser que no se provean justificaciones serias, especialmente cuando se requieran razones constitucionales.



Cuanto menor, menos intenso, meditado, detenido y razonado sea el análisis y la consideración constitucional de las leyes que realice el Congreso —y el silencio es el caso extremo—, menor será la deferencia que ellas merecen de parte de la ciudadanía y del poder judicial.

Ni la ciudadanía, ni el poder judicial tienen razones para ser deferentes al Congreso respecto de leyes que se consideren contrarias a la constitución cuando éste no asumió con la mínima responsabilidad la carga institucional de evaluar y justificar constitucionalmente su sanción.

«Por otro lado, entendemos que la práctica del autogobierno democrático debe construir una sociedad justa, y que su legitimidad requiere que realice y honre nuestros derechos fundamentales.»

Más aún, en supuestos particulares, en los que exista una controversia pública institucional acerca de la constitucionalidad de un proyecto de ley, la falta de intervención de las respectivas comisiones de Asuntos Constitucionales del Congreso es un indicio serio de un vicio procedimental significativo que afecta la validez constitucional de la ley que eventualmente se sancione.

En las próximas semanas, la Cámara de Diputados se avocará al tratamiento del proyecto. Esperemos que se permita hablar a la Constitución, en las comisiones y en el recinto.

Mientras la alarma constitucional —el grito de “¿fuego!”— no sea atendida en el debate público institucionalizado, la ley que se apruebe clamará a la ciudadanía por su judicialización, y por un poder judicial activo en el control de constitucionalidad, ante la defección de los órganos políticos. Si eso ocurriera —cuando eso ocurra— no tendrán sentido las quejas habituales sobre judicialización de la política y slogans parecidos.

Habrá sido la política quien abandonó sus deberes constitucionales; y corresponderá la ciudadanía y el poder judicial poner la primacía de las razones constitucionales en el sitio que corresponde.

Como dijera Carlos Nino, “Hay por cierto una línea fina entre la determinación de que haya una verdadera razón y que haya una razón verdadera, pero no por ser tenue el límite los jueces pueden ignorarlo...”. ■



¿Elegir al menos malo?

por Natalia Sobrevilla Perea

El Perú ante la coyuntura electoral del 2026

17 de febrero de 2026

A ocho semanas de las elecciones generales ninguno de los 36 candidatos presidenciales convence al electorado. La apatía es tan generalizada que es difícil imaginar que estamos en plena campaña para decidir quién ocupará la presidencia y como se compondrá el Congreso, que volverá a ser después de más de treinta años, bicameral. Los últimos senadores peruanos se enfrentaron al auto-golpe de Alberto Fujimori en 1992 y desde entonces solo 120 (luego 130) congresistas han compuesto, hasta esta última reforma, el legislativo. En las calles hay poquísima publicidad y de lo único de lo que se habla es de los excesos del actual presidente interino José Jerí, que en los cuatro meses que lleva en el cargo viene batiendo récord de acusaciones, que incluyen tanto sus encuentros clandestinos con empresarios chinos a altas horas de la noche, como reuniones nocturnas con mujeres jóvenes que inmediatamente quedan contratadas para puestos de confianza en el Estado peruano con sueldos fuera de proporción.

Nada de esto sorprende ya que el legislador elegido para convertirse en presidente ya estaba acusado de enriquecimiento ilícito y de violación cuando los partidos que controlan el legislativo optaron por él para dirigir el país. En la actualidad lo apoya solamente Fuerza Popular el partido de Keiko Fujimori que se opuso a debatir la censura a Jerí y que de momento controla la mesa directiva del Congreso. El jueves 12 de febrero se obtuvieron las 78 firmas que llaman a debatir la moción en un pleno extraordinario el martes 17 y mientras algunos consideran que solo se precisan 66 votos para censurarlo, la mitad más uno, los fujimoristas aseguran que se necesitarán 87 votos, dos tercios de la cámara para

hacer el cambio. En el Perú todo es posible y de momento se debate quien podría convertirse en presidente ya que no debe ser candidato en las elecciones, o en caso de serlo debería de renunciar.



Este torbellino político distrae de la campaña, no hay ni publicidad, ni debate, ni mítines políticos; la agenda está enteramente enfocada en una posible censura al presidente. Alguien podría tomar su puesto a la brevedad, acaparando toda la atención, en vez de en la necesidad de cerrar la prolongada crisis de representación que ha llevado a que tengamos siete presidentes en diez años. Pronto quizás ocho. Esta crisis comenzó cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó una ajustada elección en junio del 2016. Mientras que el partido de Keiko Fujimori, hija y heredera de Alberto (presidente entre 1990 y el 2000) dominó el legislativo con más del 70%. Ese año al perder la presidencia por segunda vez ella sentenció que gobernaría desde el Congreso y fue así que un legislativo dominado por su partido de derecha destruyó a un presidente abiertamente de derecha y se llevó de encuentro a la poca y débil institucionalidad del país.

El sistema híbrido peruano, ni plenamente presidencialista ni completamente parlamentario, dependía de un balance de fuerzas que en la última década se ha sido erosionado de tal manera, que, tras las últimas reformas a la constitución, el Congreso puede deshacerse del presidente con un número variable de votos, dependiendo de si se trata de un jefe del ejecutivo elegido en las urnas o en uno impuesto por el parlamento. Esto es lo que puede pasar en cualquier momento porque los partidos que lo sostienen desde el legislativo están haciendo el cálculo político de que conviene para cosechar más votos, dejarlo o sacarlo. Eso fue exactamente lo que le sucedió a su predecesora Dina Boluarte que no fue echada por las casi cincuenta muertes de inicios de su mandato entre fines del 2022 e inicios del 2023, ni por recibir joyas y relojes de manera ilegal de un gobernador regional. No fue siquiera por dejar el cargo abandonado para hacerse operaciones estéticas. La primera presidenta del Perú salió del cargo cuando la situación de inseguridad se hizo tan evidente, que quienes postulaban en las elecciones se dieron cuenta que ser cercanos a ella acabaría con cualquier opción de ser elegidos.

Cuando Kuczynski renunció en marzo del 2018 lo reemplazó su vicepresidente Martín Vizcarra, quien llamó a un referéndum para reformar la constitución y se enfrentó al Congreso. Logró cerrar el legislativo y en enero del 2020 se eligió uno nuevo. Pero poco tiempo después le cobraron la movida y los legisladores lo echaron del puesto cuando salió a la luz que había aprovechado de las vacunas chinas para él y su familia, vacunándose a escondidas. También se hizo evidente que su gobierno era corrupto y desde que salió del mando por vacancia en noviembre del 2020 ha sido inhabilitado de ejercer cargos públicos y está preso en espera de una sentencia por las acusaciones de corrupción. Su hermano Mario Vizcarra que postula en su nombre tiene cuatro por ciento en las encuestas y va empatado en el tercer puesto. Hace tan solo dos meses tenía siete por ciento.

Con la caída de Vizcarra estuvo cinco días en el poder Manuel Merino del tradicional partido Acción Popular, quien renunció obligado por marchas multitudinarias y el Congreso lo reemplazó con Francisco Sagasti, un tecnócrata de un partido moderado. En estas elecciones el partido que fundara Fernando Belaunde Terry en los 60s está dividido y no ha podido presentarse a las elecciones por problemas internos, aunque no se descarta que alguien de este partido podría obtener la presidencia interina. Mientras tanto el candidato del Partido Morado de Sagasti es un desconocido que no tiene ni un punto en las encuestas y el nieto del expresidente Rafael Belaunde que ha gastado mucho dinero y esfuerzo para lanzar su propio partido, Libertad Popular, tampoco aparece entre los presidenciables.

En el 2021, durante la parte final de la pandemia fue elegido en segunda vuelta Pedro Castillo, un profesor rural de un pueblo pequeño de los Andes por la agrupación de izquierda Perú Libre. Una vez más Keiko Fujimori fue derrotada por poco y lanzó una campaña acusándolo de fraude. Otra vez desde el Congreso le hizo la vida imposible al mandatario que desde el inicio dejó en claro su incapacidad para gobernar. El 7 de diciembre del 2022 dio un mensaje a la nación, inspirado en el de Fujimori de 1992 con la intención de dar un auto-golpe y cerrar el Congreso, pero su intento no duró más de un par de horas y fue arrestado en camino a la embajada mexicana a solicitar asilo. Lo reemplazó inmediatamente su primera vicepresidenta Dina Boluarte y el sur del país explotó en furia y los miembros del ejército dispararon a matar. Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre, que no pudo ser candidato en el 2021 por acusaciones de corrupción cuando fue gobernador de la región de Junín, postula hoy desde la clandestinidad, pero tampoco supera el punto porcentual en las encuestas.

Keiko Fujimori, quien una vez más anunció que no sería candidata intenta llegar a la presidencia una cuarta oportunidad, luego de haber sido derrotada por Ollanta Humala en el 2011,

por Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 y Pedro Castillo en el 2021. Quince años buscando conquistar el poder y habiendo servido trece meses de cárcel en prisión preventiva entre octubre del 2018 y noviembre del 2019 por irregularidades en el financiamiento de sus campañas electorales. A inicios del 2020 volvió a la cárcel, pero se le liberó por la crisis sanitaria del Covid-19. Keiko estaba acusada de recibir más de 17 millones de dólares de financiamiento ilícito. El 20 de octubre del 2025 el Tribunal Constitucional (elegido por sus congresistas) falló que se debía terminar con el juicio porque lo que había hecho en el 2011 no fue tipificado como delito hasta el 2016. Hoy está segunda en las encuestas con tan solo ocho por ciento. Ha caído cuatro puntos desde el año pasado en que lideraba las encuestas con doce puntos.

«Otra vez desde el Congreso le hizo la vida imposible al mandatario que desde el inicio dejó en claro su incapacidad para gobernar.»

En este momento quien tiene el primer puesto y parece sentirse ya el ganador por haber subido en un año de cuarto a doce por ciento es Rafael López Aliaga, que fue alcalde de Lima hasta hace solo unos meses en que renunció para poder postular a la presidencia, a pesar de haber jurado que no lo haría. 'Porky' como le gusta que lo llamen lidera la agrupación política Renovación Popular y es conocido por ser ultraconservador, ultracatólico y fanático de tomar tanto alcohol que no se le suele entender cuando habla por la tarde. Ha confesado estar enamorado de la virgen María y de aplicarse castigos físicos con el cilicio, pero más allá de eso su relación con el Opus Dei y con la desaparecida secta de origen peruano Sodalicio de Vida Cristiana es tan estrecho que ante la disolución de esta última, ha tomado control de muchos de sus negocios y pro-

piedades. López Aliaga es un empresario dedicado entre otras cosas al turismo, ya que tiene la concesión del tren a Machu Picchu y le debe 13 millones de soles en impuestos al Estado Peruano, pero asegura que eso es solo el 0.35% de su fortuna. De ser elegido sería el primer alcalde de Lima en llegar a la presidencia desde Guillermo Billingurst en 1912, y que fue derrocado dos años más tarde.

En el pelotón del 4 por ciento junto con Mario Vizcarra está el cómico Carlos Álvarez conocido por haber hecho carrera de imitador. Sin ninguna experiencia política según la hoja de vida que ha consignado al ente electoral, postula por el Partido País Para Todos que se define como 'conservadurismo popular antisistema', algo que suena un poco contradictorio porque quien fundó el partido hace dos años, el exalcalde de la provincia de Huaraz fue cercano al gobierno supuestamente de izquierda de Pedro Castillo y está acusado de corrupción durante su administración. Álvarez de 62 años se inició como comediante a los dieciocho y se hizo famoso en los 90s durante la dictadura de Fujimori. Uno de sus personajes más conocidos es la imitación a Fernando 'Popi' Olivera, un gran luchador contra la corrupción desde los ochenta con su partido el Frente Independiente Moralizador y su símbolo de la escoba que ahora se presenta a la presidencia, pero no figura en las encuestas. El cómico se ha visto cuestionado en los últimos días por el uso del dinero de la franja electoral financiada por el Estado y amenaza con renunciar a su postulación si el partido no esclarece el uso del dinero. A pesar de mantenerse tercero en las encuestas sus números han bajado del ocho al cuatro por ciento desde agosto.

También con cuatro por ciento está César Acuña, el multimillonario dueño de la Universidad César Vallejo y hasta su postulación, gobernador regional de La Libertad, en el norte del Perú. Inició su carrera política en el 2000 y tras la caída de Fujimori logró consolidarse políticamente hasta crear su partido Alianza Para el Progreso. Fue alcalde de Trujillo, gobernador de La Liber-

tad y en el 2016 fue escalando en las encuestas hasta llegar al tercer lugar. Pero en ese momento fue impedido de postular al descubrirse que sus dos tesis de maestría eran plagiadas. Pero su agrupación política se ha mantenido con representación congresal y actualmente son uno de los socios principales del Fujimorismo en el legislativo. 50 de los candidatos que lo acompañan en estas elecciones para puestos en el legislativo tienen sentencias firmes de todo tipo. Acuña, cuya ideología jamás ha sido muy clara, siempre está ahí y en el último mes ha subido de dos a cuatro por ciento.

El último candidato que parece separarse del pelotón es Alfonso López Chau, es el único entre los que sobresalen que se autodefine como de izquierda democrática. El que fuera rector de la Universidad Nacional de Ingeniería saltó a la palestra en enero del 2023 cuando le abrió las puertas del campus a los estudiantes y jóvenes del sur del Perú que fueron a Lima a protestar por el asesinato de sus compañeros en las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte. Fue desde entonces que comenzó a construir un partido político que tiene apoyo principalmente en provincias. Uno de sus pasos más acertados electoralmente fue convocar a las principales voces de la izquierda moderada para que participen en sus listas al parlamento. Es más, desde que se dio el anuncio de quienes lo apoyan y postulan al Congreso con su agrupación, ha dado un salto en las encuestas. Eso y los ataques sostenidos

desde los comentaristas de la derecha han hecho que se haga más conocido y habrá que ver cómo evoluciona su candidatura en las próximas semanas.

El escenario es entonces extremadamente complejo. Podríamos tener un nuevo presidente en menos de una semana. También es posible que alguien dé la sorpresa y a partir de los debates que no se darán hasta dos semanas antes de las elecciones. Eso fue lo que sucedió con Pedro Castillo en el 2021, nadie lo conocía hasta que apareció en televisión y destacó por su sombrero. Algunos candidatos podrían aún ser excluidos de la carrera porque el Jurado Nacional de Elecciones aún está resolviendo tachas y el padrón no se cerrará hasta el 12 de marzo, un mes exacto antes de la primera vuelta. La situación es entonces aún más volátil que de costumbre y a pesar de ello la economía peruana sigue con esa estabilidad que la ha caracterizado en los últimos veinte años. Los precios de las materias primas que exportamos están por los cielos, y por eso el país debería crecer a más del tres por ciento en el que seguimos estancados. El costo del desorden político y de la falta de institucionalidad es inmenso, la estabilidad es a nivel macro, la gente no la siente. La inseguridad campea y los peruanos y peruanas están más preocupados en sobrevivir su día a día que en pensar por quién votar en las próximas elecciones. Al final como siempre nos veremos obligados a elegir al que consideremos al último minuto el menos malo. ■



«El 20 de octubre del 2025 el Tribunal Constitucional (elegido por sus congresistas) falló que se debía terminar con el juicio porque lo que había hecho en el 2011 no fue»



La crisis estructural del diseño político del Perú

por Heber Joel Campos Bernal

Ocho presidentes en diez años no es casualidad. Son las instituciones.

24 de febrero de 2026

El Perú acaba de elegir a su octavo presidente en menos de diez años. Es la primera vez en su historia que enfrenta un escenario de estas características. Las razones que explican este desenlace son muchas. Quiero centrarme en este momento en las razones constitucionales.

El Perú posee un diseño orgánico incoherente y disfuncional. Este se remonta a principios de la república. Desde sus orígenes, el Perú adoptó un sistema de gobierno sin parangón en la región. Uno que prioriza la incorporación de injertos del sistema de gobierno parlamentario en un sistema de base presidencial. Su fin, sin duda, fue noble: evitar que el jefe de Estado se convierta en un monarca republicano, pero su ejecución fue errada. Da la impresión de que la imaginación institucional de los constituyentes se limitó a importar figuras del parlamentarismo para controlar los excesos del presidencialismo, puestos de relieve por los caudillos militares de los primeros años del siglo XIX.

Este peculiar diseño político tuvo su punto de partida con la Constitución de 1828 —la madre de todas las constituciones, según Manuel Vicente Villarán—. Las Cartas que la sucedieron son una recreación de sus instituciones basilares. En otras palabras, la Constitución de 1828 sentó las bases del diseño político y constitucional del Perú. Las constituciones posteriores trataron de “mejorar” sus alcances. Pero no lo lograron. Al contrario, exacerbaron sus defectos y contradicciones internas.

El punto es que nadie se dio cuenta... hasta que llegaron las crisis. Y, cuando llegaron, no se pudieron paliar sus efectos. Ello responde en parte a que, cuando el presidente es débil en el Congreso, no puede hacerle frente a este poder

del Estado. Por lo general, los presidentes del Perú han tendido a contar con mayoría en el Congreso, pero desde el 2016 esta regla cambió: tendieron, más bien, a ser extremadamente débiles. Es decir, carecieron del respaldo político mínimo para gozar de estabilidad.



Si a lo anterior se agrega que este Congreso abusa de sus potestades para obtener ventajas prebendarias o atarles las manos a los órganos responsables de controlar sus excesos, el resultado es nefasto: ocho presidentes en diez años y una Constitución hecha pedazos a causa de su instrumentalización arbitraria.

¿Qué hacer para salir de la crisis? Reparar el diseño político. Pero eso no pasa por sacar una pieza y poner otra en su lugar. Las reformas profundas no funcionan así. Pasa por repensar los presupuestos del modelo político, de los mecanismos de relacionamiento entre el Gobierno y el Congreso. Hace 200 años, la idea que inspiró a los constituyentes fue evitar la concentración del poder en cabeza del presidente. Ahora, esa idea debería complementarse con otra: evitar que una facción prepotente de políticos rentistas se haga de todas las llaves del poder y las use en su beneficio propio.

Se necesita, entonces, un diseño que ponga de relieve el rol que les corresponde asumir a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones políticas. No se puede seguir pensando el principio de separación de poderes con base únicamente en el paradigma de la separación estricta y los pesos y contrapesos. Se debe hacer también en armonía con el paradigma de la cooperación y la colaboración entre poderes y el control vertical. ¿Esto qué significa en términos llanos? Que el diseño político debe ser sensible a mecanismos que promuevan la participación ciudadana y el diálogo constitucional. Se ha puesto la aten-

«Su fin, sin duda, fue noble: evitar que el jefe de Estado se convierta en un monarca republicano, pero su ejecución fue errada.»

«Por lo general, los presidentes del Perú han tendido a contar con mayoría en el Congreso, pero desde el 2016 esta regla cambió: tendieron, más bien, a ser extremadamente débiles.»

ción en armar a los poderes para un hipotético enfrentamiento, pero no en equiparlos para la cooperación en función del interés público. El resultado: vacancias y censuras presidenciales, acusaciones constitucionales, disoluciones parlamentarias y un largo etcétera que evidencia el uso desproporcionado de las armas defensivas por parte de los órganos políticos, basado en una lógica de acumulación del poder que deja al margen a quienes, según la Constitución, somos los reales detentadores de la soberanía: *nosotros, el pueblo*.

■



John Marshall y la trastienda de "Marbury v. Madison"

por Gustavo Arballo

Le soplamos las velitas (223 ☒) al control de constitucionalidad

24 de febrero de 2026

1. El plan Marshall

Hay una observación que Bernard Schwartz pone al principio de su Historia de la Suprema Corte Norteamericana, donde postula que los distintos sistemas legales pueden analizarse a partir de los caracteres personales de los grandes "hacedores de leyes", *lawgivers*. En otros sistemas, han sido monarcas poderosos como Hammurabi y Justiniano, profetas de inspiración divina como Moisés, filósofos como Confucio, profesores como Hugo Grocio y William Blackstone; entre nosotros –dice Schwartz– la figura prominente es John Marshall. Ese detalle es altamente revelador del sistema legal norteamericano.¹

Es que John Marshall (1755-1835) fue, sin duda, el gran juez de ese tribunal. A diferencia de Gorostiaga, que sería su paralelo argentino, no llegó a la Corte con un currículum impresionante, más allá de haber participado con cierto relieve en los debates de ratificación de la Constitución y ser un protegido político de George Washington (cuyos herederos le encargarían luego la biografía "oficial", de la que Marshall –ya en la Corte– se encargó más que nada porque necesitaba el dinero, y que a pesar de constar de cinco tomos resultó bastante deficiente).



Era un veterano de la guerra de la independencia (luchó en varias batallas y llegó a ser capitán) que se volcó hacia el derecho a los 27 años. Y aunque los estudios de esos tiempos no deben evaluarse con parámetros actuales, ya que normalmente se limitaban a dos o tres años, la preparación académica de Marshall era pobre aún para los criterios de la época: había tomado cursos por tres meses. Lo cual, debe señalarse, no le impidió destacarse rápidamente en el foro.

¹Bernard Schwartz, *A history of the Supreme Court*, Oxford University Press, 1993, p. 32. Los nombres que menciona corresponden a algunos de los dieciocho personajes representados en los frontispicios de las paredes norte y sur del edificio de la Corte Suprema. John Marshall es el único estadounidense entre todos esos célebres juristas.

Sin experiencia judicial previa, su nominación surgió sólo porque el presidente John Adams no tenía a mano candidatos mejores luego de algunas deserciones (se le ofreció volver a Jay a la Corte –había sido el primer presidente– pero éste lo rechazó). En varios sentidos fue algo accidental. Como se suponía que iba a pasar poco tiempo para que quedara vacante la silla del *Chief Justice* Ellsworth, el “presidenciable” Jefferson tenía entre sus planes el llevar a un partidario suyo, Spencer Roane, a presidir la Corte. Pero Ellsworth renunció el 16 de octubre de 1800 y Adams, ya jugando en tiempo de descuento (saldría tercero en las elecciones de noviembre y entregaría el poder al año siguiente), le ganó de mano nominado a Marshall. Este y otros episodios fueron generando una indisimulada inquina entre ellos, a tal punto que, según Albert Beveridge, autor de una biografía canónica de Marshall de cuatro tomos ², Roane era uno de los dos hombres que lo odiaban personalmente. El otro “enemigo” que consigna era un célebre pariente de Marshall; se trata, desde luego, de Thomas Jefferson, que era su primo segundo y que le había dado la licencia de abogado cuando era gobernador de Virginia.

Adams diría luego que el acto que le daba más orgullo en toda su vida fue haberle obsequiado a John Marshall al pueblo de los Estados Unidos. Marshall iba a presidir la Corte durante treinta y cuatro años, en un tiempo donde en términos de doctrina constitucional casi todo estaba por hacerse. Su enérgica afirmación del *judicial review* iba a ser una revolución en la historia constitucional americana (y probablemente mundial). Ejerció un liderazgo monolítico sobre los más de quince jueces –de diferente extracción política– que en diferentes momentos integraron “su” corte, sin generar bloques partidarios o disidentes ideológicos, lo cual es considerado en los Estados Unidos como un indicador sensible de la eficacia de un Chief Justice. Inter-

vino en 1.215 fallos, la mitad de los cuales escribió personalmente (para comprender la magnitud de la cifra, nótese que cuando llegó para presidirla, la Corte registraba nada más que un centenar de fallos en sus anales) y sólo se encontró en minoría ocho veces.



La Corte tal como la conocemos fue una invención de Marshall (incluyendo la forma de votar con “voto de la corte”, y no en *seriatim*, cada uno por su voto, como se hacía hasta antes de su gestión, y que ahora está volviendo a suceder como norma en tribunales de todo el mundo, producto en parte de vocalías que aun llegando a la misma conclusión tienen **el narcisismo de las pequeñas diferencias**), producto del malestar en la cultura jurídica)

2. Breve digresión sobre federalistas y republicanos

Nunca se insistirá demasiado en la vinculación entre las cuestiones judiciales con las políticas al nivel de los Tribunales Superiores. Y ello es clave para entender el papel de Marshall y de su doctrina, que respondía a las ideas de un sector político que paradójicamente se encontraba en retirada, aunque impuso sus ideas por medio de la judicatura –una visión que fue el correlato de un proceso en el cual los Estados Unidos triplicaron su territorio y su población y que permitió la construcción de un Estado central dota-

² Albert Jeremiah Beveridge, *The life of John Marshall*, Boston, Houghton Mifflin, 1916-1919. Otras biografías importantes son las de Leonard Baker (*John Marshall: A life in Law*, New York, Macmillan, 1974) y de Edward S. Corwin (*John Marshall and the Constitution: A chronicle of the Supreme Court*, New Haven, Yale University Press, 1919).

do de los poderes necesarios para cohesionar la Unión federal.³

Todo esto nos lleva a la necesidad de dar un apresurado panorama de las tendencias políticas que se presentaron en los Estados Unidos a partir de la presidencia de Washington. La controversia no era estrictamente ideológica y no puede describirse con propiedad en términos de izquierdas y derechas. Aunque acaso sea demasiado respetuoso describirla como una controversia “técnica”, la divisoria de aguas era un asunto de interpretación constitucional. Los “federalistas” (Hamilton, Adams, y el propio John Marshall) propugnaban un sistema centralista de “supremacía nacional”, que privilegiara los poderes del gobierno nacional por sobre los estados. Los “republicanos” (Madison, Monroe, Jefferson) eran quienes buscaban la limitación más estricta a los poderes federales.⁴

En términos de clase, los “federalistas” suscribían la máxima de Jay, “aquellos que son propietarios del país son los que deben gobernarlo”, principio aristocrático al que se oponían los republicanos de Jefferson, “el hombre del pueblo”, adherentes a los postulados revolucionarios que se proclamaban en Francia.⁵

Sería también impropio decir que eran “partidos” en el sentido moderno del término, pues funcionaban como un agregado de lealtades, consensos y favores personales sin una estructura permanente. Además, en la práctica debían cogobernar: no se elegía una “fórmula”, porque la Constitución (luego enmendada en ese punto) disponía que el segundo más votado para presidente fuese el vicepresidente, dando lugar a la

“cohabitación” que tuvo lugar en el término presidencial de John Adams (el último presidente “federalista”) que fue elegido presidente en 1797 y tuvo como su vicepresidente a Jefferson. Luego Jefferson lograría imponerse a Adams en las elecciones de 1801, y la derrota de los federalistas tuvo entre sus coletazos los hechos que derivaron en el caso *Marbury vs Madison*.

3. Regalos de despedida

La última cosa que hizo Marshall antes de ser elegido para la Corte iba a ser también la causal del caso que más familiar nos resulta. Adams lo había nombrado Secretario de Estado en 1800 y permaneció en ese cargo hasta que Jefferson asumió la presidencia el 4 de Marzo de 1801. En ese cargo fue el encargado de ejecutar una estrategia inédita –luego usual– dentro del sistema de sucesión democrática: los federalistas derrotados querían condicionar al electo gobierno por vía judicial. En febrero sancionaron la *Judiciary Act* de 1801. Una de sus provisiones era la de que la Corte Suprema se reduciría a cinco miembros cuando se produjese la próxima vacante.

Esa cláusula en realidad tenía nombre: los federalistas pensaban que por sus achaques y enfermedades el juez William Cushing iba a dejar enseguida el cargo y querían evitar que los republicanos pusieran un juez de su partido para cubrirlo (pero Cushing, que en verdad estaba muy viejo, dependía de su sueldo en la Corte y permanecería allí hasta su muerte, que ocurrió recién en 1810; en el ínterin, el número de la Corte no sólo no se redujo sino que fue aumentado a siete miembros en 1807). Y también hicieron una reforma drástica en el Poder Judicial federal

³Una buena síntesis de ello es lo que diría Marshall en *Cohens v. Virginia* (19 U.S. 264, 1821): “Los Estados Unidos forman para muchos y los más importantes propósitos, una sola nación. En la guerra somos un solo pueblo; haciendo la paz somos un pueblo; regulando el comercio somos un solo y mismo pueblo. En muchos otros aspectos el pueblo americano es uno solo, y el gobierno, el cual es solo y capaz de controlar y dirigir sus intereses en todos sus aspectos, es el gobierno de la Unión. Este es su gobierno y en este carácter no tiene otro. América ha elegido ser, en muchos sentidos y en muchos propósitos, una Nación y para todos estos propósitos su gobierno es completo y para todos estos objetos es competente”.

⁴Nótese cómo aplicando la terminología argentina resultaría que los “republicanos” serían “federales” y los “federalistas”, “unitarios”. Es todo muy confuso.

⁵Cabe aclarar que la nomenclatura de los partidos del s. XIX en los Estados Unidos es un tanto desconcertante y el reconocimiento de las filiaciones desafía el sentido común. Los “Republicanos” de Jefferson comenzaron a llamarse luego “Demócratas” en 1828; los “federalistas” se denominaron “Whigs” entre 1836 y 1856, y a la vuelta de los años se conocerán como “Republicanos”, es decir, de la misma forma que lo hacían sus antiguos oponentes.

que creó decenas de vacantes, todas cubiertas por adeptos a su partido. Fueron instituidos además unos "Juzgados de Paz" que eran una combinación de tribunales de pequeños reclamos y de oficinas de naturaleza notarial. Estos se crearon en un número largamente excesivo con respecto a las necesidades reales, lo cual explica que se reputaran con acierto como una suerte de recompensa o compensación para esforzados partidarios federalistas.

Como había poco tiempo para proceder con todos los nombramientos, las designaciones se hicieron a todo vapor y se dice que Marshall estuvo firmando los poderes respectivos hasta la medianoche del 3 de marzo, cuando concluía la presidencia de Adams (se los conoció entonces como los "midnight judges"). En total, quedaron cuarenta y dos designaciones que debía completar el nuevo gobierno, cosa que no estaba dispuesto a hacer. Diecisiete de ellos fueron cajoneados por Jefferson, aunque sólo cuatro demandaron al gobierno federal, en la persona del Secretario de Estado Madison, para que les entregara los nombramientos. Los demandantes eran Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, William Harper y, por supuesto, William Marbury, designado juez de paz del Distrito de Columbia.

4. Marbury v. Madison****⁶

Marshall estaba frente a un dilema grave. No podía descalificar un nombramiento que él mismo había promovido, pero tampoco podía imponer a Marbury en su cargo porque tal decisión iba a encontrar una acogida nada simpática en

la sociedad norteamericana, conciente de la maniobra de los federalistas. La necesidad de encontrar un atajo político entre estos dos caminos fue el prosaico y nada noble origen de la doctrina judicial americana sobre el control de constitucionalidad.

La cuestión había generado tanta irritación que el Congreso dominado por los republicanos ordenó que la Corte pospusiera su período de sesiones por un año, mientras preparaban los cargos para los jueces nominados en el paquete. Y el resultado del caso no ofrecía a primera vista demasiadas alternativas: Marbury había sido nombrado en debida forma y la Ley Judicial (*Judiciary Act*) de 1789 autorizaba a la Corte a emitir mandamientos (*writ of mandamus*)⁷ a cualquier tribunal o persona designado en oficio bajo la autoridad de los Estados Unidos. Quizá fue por eso que Madison ni siquiera mandó un abogado que lo representara ante la Corte, y no puede descartarse que estuviera esperando ansiosamente que la Corte le diera la razón a Marbury granjeándose con ello el descrédito generalizado (lo cual le hubiera permitido un *impeachment* colectivo con ciertas posibilidades de éxito, y la subsiguiente posibilidad de formar un nuevo tribunal).

Las audiencias tuvieron lugar en los primeros días de febrero de 1803 y el abogado de Marbury fue el anterior procurador general Charles Lee, quien confiadamente planteó ante los jueces las mismas tres preguntas que Marshall retomó en el fallo: 1) ¿Tiene el solicitante derecho al nombramiento que demanda?; 2) si lo tiene, y ese de-

⁶Los casos de la Corte de los EE.UU. se pueden citar de tres formas. Así se podrá encontrar citado a *Marbury*, por ejemplo, mediante la referencia al reporter de la Corte que lo registró – "1 Cranch 137, 1803"–, en forma mixta – "5 U.S. (1 Cranch) 137, 1803"– o simplificada "5 U.S. 137, 1803". **MUY IMPORTANTE: la convención es que se escriba "v." y no "vs.", detalle que se aplica a todos los casos de la Corte EE.UU.**

⁷El *mandamus* es un peculiar instituto del Common Law que no tiene equivalentes en el derecho continental. Conviene por ello aclarar cuál era su alcance. En el fallo se cita la definición de Blackstone ("Commentaries", T. III, p. 110) que lo define como una orden dirigida en nombre del rey y dirigida a cualquier persona, corporación o corte inferior dentro de los dominios del rey, requiriéndoles hacer alguna cosa allí especificada que corresponda a sus funciones y deberes". Y la Corte cita luego un precedente británico (*The King vs. Baker et al.*, 3 Burrows, 1266) que lo caracteriza con una amplitud que lo acerca a los perfiles del amparo moderno. Lord Mansfield dijo en ese caso que "Siempre que haya un derecho de ejercer una función, ejecutar un servicio o ejercitar una concesión (especialmente si es un asunto de beneficio o interés público) y una persona es excluida de la posesión o desposeída de ese derecho, y no haya ningún otro remedio legal específico, la corte debe asistirlo por medio del *mandamus*, en la forma en que la orden lo exprese sobre razones de política pública, para preservar la paz, orden y buen gobierno".

recho ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio a esa violación?; 3) si lo proveen, ¿es dicho remedio un mandamiento que corresponda a esta Corte emitir?. Lee se concentró en las preguntas uno y dos, casi sin dedicarle espacio a la tercera, que era aparentemente trivial.

Pero la Corte no hizo lo que se esperaba que hiciera. Marshall consiguió un fallo unánime, que anunció el 24 de febrero de 1803, y que fue un magistral pase de muletas. El obstáculo que encontró era que la Corte no podía emitir la orden que Marbury le pedía, simplemente porque la disposición que habilitaba a la Corte a dar el mandamiento al Secretario de Estado era inconstitucional. Como lo hace nuestra Constitución, la americana limita la jurisdicción originaria de la Corte Suprema a los casos que involucran a embajadores, cónsules, y estados extranjeros; y es sólo en esos casos –según sostuvo Marshall– donde la Corte podía emitir válidamente el *mandamus*, porque “si el Congreso tiene la libertad de asignar a esta Corte competencia por apelación en los casos en los que la Constitución le asigna competencia originaria y fijarle competencia originaria en los casos en que corresponde ejercerla por apelación, la distribución hecha en la Constitución es forma carente de contenido”. Por ello, la demanda que solicitaba que se emitiera la orden sólo podía darse en el marco de una acción originaria expresamente mencio-

nada en la constitución, que no era el caso de la petición de Marbury.

Aquí cabe detenerse para observar que la *judiciary act* había sido votada prácticamente por las mismas personas que dos años antes habían votado la Constitución, y en esa oportunidad no se formularon objeciones.⁸

«Fueron instituidos además unos ‘Juzgados de Paz’ que eran una combinación de tribunales de pequeños reclamos y de oficinas de naturaleza notarial.»

Marshall tuvo que aferrarse a una visión restrictiva para poder sostener la invalidación de la ley, y no podrá para ello invocar más razones que su afirmación dogmática al respecto. Este es el punto más débil de todo el desarrollo, y cuando Marshall más adelante cite un precedente de la Corte a propósito del alcance de su competencia, lo va a glosar sin mencionar el hecho de que la Corte había dado por buena la constitucionalidad de la ley ahora desahuciada.⁹

Habiendo ya adelantado la retirada estratégica –finalmente, Marbury no iba a recibir el *mandamus*– y acaso consciente de la fragilidad de

⁸Insólitamente Marshall iba a reconocer ese principio de autoridad... claro que muchos años más tarde. En el caso *Cohens v. Virginia* (19 U.S. 264) de 1821 propugnaría el criterio de que las dudas en la constitución deben interpretarse a la luz de los documentos contemporáneos a ella, y en tal sentido señala en primer lugar a los ensayos de *El Federalista* escritos por Hamilton, Madison y Jay. Y a continuación, alude a la *Judiciary Act* de 1789 que había declarado inconstitucional en *Marbury v. Madison*, diciendo que es “Una exposición (...) ciertamente de no menos autoridad de la que acaba de citarse” y subrayando el hecho de que “en el Congreso que sancionó esa ley había muchos eminentes miembros de la Convención que formó la Constitución” y “ni uno de ellos” se opuso.

⁹Marshall no era muy afecto a citar. Tres razones confluieron para ello: primero, no había muchos precedentes sobre derecho constitucional, ni de la propia Corte ni del paradójico constitucionalismo sin constitución que tenían los británicos. Segundo, Marshall no tenía un conocimiento de jurisprudencia muy destacable. Finalmente, el no citar era indudablemente una cuestión estilística: en una saludable práctica, cada fallo de Marshall confronta los problemas y los resuelve sin escudarse en precedentes, de manera que el voto se explica y se basta a sí mismo. Pues bien, en *Marbury* se citan solo dos casos. Uno es del derecho inglés, *Rex v. Barker*, 3 Burr. 1265 (1762), en el que Lord Mansfield establecía un alcance muy amplio sobre el remedio del *mandamus*. El otro es un caso de pensiones, que Marshall cita deficientemente, no nombra a las partes ni al año (dice textual “en un caso decidido por esta Corte”) y que en realidad no existe de la forma en que lo relata. Susan Low Bloch y Maeva Marcus, de la Supreme Court Historical Association, han demostrado que es un collage de tres casos distintos en el cual Marshall habría tomado –en un “uso selectivo de la historia”– las partes que más se prestaban a su línea de argumentación.

sus argumentos, Marshall buscó sobrecompensar con una profusa justificación del control de constitucionalidad (que era, después de todo, lo que más le interesaba sostener). Eso dio pie a los famosos silogismos de *Marbury vs. Madison*.

La pregunta acerca de si una ley contraria a la Constitución puede convertirse en ley vigente del país es profundamente interesante para los EEUU. pero, felizmente, su complicación no es proporcional a su interés. Para decidir esta cuestión parece necesario tan sólo reconocer ciertos principios que se suponen establecidos como resultado de una prolongada y serena elaboración. Todas las instituciones fundamentales del país se basan en la creencia de que el pueblo tiene el derecho preexistente de establecer para su gobierno futuro los principios que juzgue más adecuados a su propia felicidad. El ejercicio de ese derecho supone un gran esfuerzo, que no puede ni debe ser repetido con mucha frecuencia. Los principios así establecidos son considerados fundamentales. Y desde que la autoridad de la cual proceden es suprema, y puede raramente manifestarse, están destinados a ser permanentes.

(...) Hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquella, o la legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes, y, por lo pronto, como cualquiera de ellas puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; pero si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza.

(...) Si una ley contraria a la Constitución es nula, ¿obliga a los tribunales a aplicarla no obstante su invalidez?. O bien, en otras palabras, no siendo ley, ¿constituye una norma operativa como lo sería una ley válida? Ello anularía en la práctica lo que se estableció en la teoría y constituiría, a

primera vista, un absurdo demasiado grueso para insistir en él.

Esas preguntas no son inocentes. Montesquieu –a todo evento, el ideólogo de la división de poderes– decía en *El espíritu de las leyes* (LIV, XI, Cap. VI) que los jueces eran *la bouche qui prononce les paroles de la loi*: “la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar la fuerza de ésta ni su rigor”. Marshall, en cambio, da vuelta el paradigma, inventa lo que hoy conocemos como “activismo” judicial y afirma enfáticamente que son los jueces los que deben decir qué cosa es la ley.

Definitivamente, la competencia y la obligación del Poder Judicial es decir qué es ley. Los que aplican las normas a casos particulares deben por necesidad exponer e interpretar esa norma. Si dos leyes entran en conflicto entre sí el tribunal debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada una. Del mismo modo cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables a un caso, de modo que la Corte debe decidirlo conforme a la ley desechando la Constitución, o conforme a la Constitución desechando la ley, la Corte debe determinar cuál de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de administrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el caso al cual ambas normas se refieren.

Quienes niegan el principio de que la Corte debe considerar la Constitución como la ley suprema, se ven reducidos a la necesidad de sostener que los tribunales deben cerrar los ojos a la Constitución y mirar sólo a la ley. Esta doctrina subvertiría los fundamentos mismos de toda constitución escrita. Equivaldría a declarar que una ley totalmente nula conforme a los principios y teorías de nuestro gobierno es, en la práctica, completamente obligatoria. Significaría sostener que si el Gobierno actúa de un modo que le está expresamente prohibido la ley así sancionada sería, no obstante tal prohibición, eficaz. Estaría confirmando

práctica y realmente al Congreso una omnipotencia total con el mismo aliento con el cual profesa la restricción de sus poderes dentro de límites estrechos. Equivaldría a establecer al mismo tiempo los límites y el poder de transgredirlos a discreción.

Debe resaltarse que, más allá de las distancias que imponen la época, la fragmentaria cita y la traducción, el estilo de estas frases es extraño, empalagoso, amanerado. Marshall claramente sobreargumenta: dice que va a decir algo; luego lo dice; y finalmente repite lo que ha dicho. Lo cual no sería nada si no fuera porque viene a dar automáticamente por sentado que es la Corte quien debe hacerse cargo del control de constitucionalidad, algo que la Convención Constituyente había negado tres veces durante los debates.¹⁰

Doscientos años después seguimos discutiendo cosas que a Marshall le parecían totalmente fuera de discusión. No es este el lugar para detenernos en las profusas observaciones que la moderna teoría jurídica ha formulado sobre ello, pero sí cabe citar brevemente el corolario de las reflexiones de Nino: la “lógica de Marshall” no es tan lógica porque es perfectamente concebible que haya una Constitución que sea la ley suprema y defina qué otras normas son leyes, no pudiéndose derogar por procedimientos ordinarios; y que, sin embargo, si una ley que tiene “coloración de derecho” es dictada fuera de las condiciones que esa Constitución establece, su

observancia sea obligatoria aún para los jueces mientras el Parlamento no la derogue.¹¹

Lo que es más, Marshall apoya su petición de principio en un despliegue razonativo que no aparece necesario ni pertinente para decidir el caso. Ello nos lleva a una conclusión: tanta insistencia en el poder de la Corte (que ésta, en verdad, se autoarrogaba) era en realidad una advertencia a los otros poderes que trascendía el asunto que se estaba decidiendo.

Esta doctrina le permitió a Marshall evitar respaldar al cuestionado nombramiento (como dice Nino, evitando generar un conflicto de poderes del que habría salido perdidosa), pero al mismo tiempo condicionar aún más intensamente al nuevo gobierno, que en lo sucesivo tendría pendiente sobre su cabeza la posibilidad de que la Corte Suprema declarare inconstitucionales las leyes del Congreso y sus propios actos. Puede decirse además que Marshall tiró la piedra y escondió la mano, porque pocos días después la Corte aceptó la constitucionalidad de la Ley Judicial de 1802, por la que la legislatura controlada por Jefferson revocó la reducción de miembros que se había dispuesto en el último período de la presidencia saliente de Adams, de manera que la Corte seguiría teniendo seis miembros.

5. Después de *Marbury*

En cualquier caso ese condicionamiento funcionó tan bien que no fue sino implícito (habría que esperar hasta 1857 para que la Corte decretara otra vez la inconstitucionalidad de una ley fe-

¹⁰Se suele aludir como precedente lejano al fallo del Juez Coke en el *Dr Bonham's case* (8 Co. Rep. 113b, 1610). Ocurrió cuando el Real Colegio de Médicos de Londres había sancionado a Thomas Bonham con arresto y multa por ejercer la profesión sin su autorización. Existía al respecto una ley del Parlamento que confería al Colegio las facultades para imponer esas sanciones a los efectos de regular el ejercicio profesional. Pero Bonham argumentó que esa norma violaba el postulado de que nadie podía ser al mismo tiempo juez y parte, porque una parte de la multa aplicada era retenida por el propio Colegio que la imponía. Coke admitió entonces que el *common law* establecía limitaciones implícitas sobre las normas de la Corona y del Parlamento, cuando estas violaran algún principio fundamental (“cuando sean contrarias al derecho y a la razón, o repugnantes, o imposibles de ejecutarse”, decía). Aunque el principio de Coke no tuvo mayor acogida en las Islas Británicas (porque finalmente se impuso la teoría de Blackstone que otorgaba al Parlamento una soberanía absoluta, tal como la presenta en sus famosos *Commentaries on the Laws of England*, publicados entre 1765 y 1769, que fueron los evangelios del *common law*), sí tuvo una fervorosa adhesión entre los revolucionarios americanos (“era nuestro coloso juvenil”, decía John Adams padre en 1816), que leyeron con devoción sus *Institutas*. Y en 1765, la Asamblea de Massachussets invocó los principios de Coke para invalidar en el territorio americano la aplicación de la *Stamp Act* (ley de sellos) votada por el Parlamento Inglés.

¹¹Carlos S. NINO, *Fundamentos de derecho constitucional*, Astrea, 1993, p. 679.

deral). De hecho, para muchos contemporáneos la doctrina pasó inadvertida, el episodio generalmente está ausente hoy en los libros de historia no jurídicos, y la propia Corte citó a *Marbury vs. Madison* sólo dos veces durante todo el siglo XIX.¹² Como tantos eventos históricos, la importancia magna es una construcción retrospectiva, y no una percepción ajustada a las impresiones de la época, ni siquiera en los ámbitos especializados.

Pero Jefferson comprendió enseguida la importancia del fallo, y estaba convencido que la doctrina del control judicial de constitucionalidad desquiciaba el equilibrio de poderes. En carta a Roane, decía que "según esta opinión, la Constitución habría dado a sólo uno de ellos el derecho a prescribir reglas para el gobierno de los otros, y justamente a aquel no elegido e independiente de la nación, cuando la experiencia ha mostrado que el impeachment no es ni siquiera un espantapájaros... La Constitución es según esta hipótesis un mero objeto de cera en manos de la judicatura, que puede retorcerla y darle forma a su gusto". Como el principio de Marshall, la objeción contramayoritaria de Jefferson se sigue debatiendo todavía hoy.¹³

Me permito cerrar estas líneas con una última advertencia, planteada en el terreno de las hipótesis como historia conjetural. He señalado todo el trasfondo político para que se comprendiese mejor el caso, pero es difícil sostener que el comportamiento de Marshall haya sido sola y puramente estratégico. Para ponerlo más claro: aunque Marbury y los otros tres designados sí hubieran tenido tiempo de recibir sus designaciones, y ese caso no hubiera tenido lugar, Marshall se las habría arreglado para encontrar un caso apropiado y terminar afirmando el *judicial review*. Todo lo que podemos observar en el comportamiento ulterior de Marshall como juez nos muestra un perfil netamente activista, que no hubiera podido cabalmente protagonizar si se autorestringía a hablar de temas no constitucionales y de distribución de competencias. Si, como dijimos antes, la designación de Marshall pudo haber sido un accidente (como también lo fue, qué duda cabe, el hecho de que haya tenido la salud para presidir la Corte durante un tercio de siglo e imponer así sus criterios en muchísimos temas fundacionales)¹⁴, el *judicial review* que este se encargó de imponer no fue para nada una contingencia histórica.



¹²Y la primera vez que lo citó fue en *Mugler v. Kansas*, (123 U.S. 623, 661, de 1887), que fue un despropósito –en un *obiter* dentro de la sentencia, se la refiere como avalando la incipiente idea del “debido proceso sustantivo”, cuando en *Marbury* no hay ninguna mención que permita avalar la pertinencia del precedente.

¹³Ver, al respecto, el libro de Roberto Gargarella, *La justicia frente al gobierno*, Ariel, 1996.

¹⁴Por citar algunos ejemplos: en *Fletcher vs Peck* (10 U.S. 87, 1810) afirmó el derecho de propiedad declarando la inconstitucionalidad de las leyes estatales que venían a revisar los contratos; en *McCulloch v. Maryland* (17 U.S. 316, 1819) admitió la constitucionalidad de un Banco Nacional sentando la doctrina de los “poderes implícitos” del gobierno federal para ejecutar los objetivos que le marca la Constitución; en *Sturges v. Crowninshield* (17 U.S. 122, 1819) declaró inconstitucional una ley del Estado de Nueva York que favorecía a los deudores insolventes; en *Gibbons v. Ogden* (22 U.S. 1, 1824) afirmó una interpretación extensiva de la “cláusula comercial”, invalidando un monopolio concedido para el transporte de ferrys por el Estado de Nueva York y que fue la piedra fundamental para que el Estado Federal pudiera intervenir luego en muchos asuntos de la vida económica para “regular el comercio”. Todos ellos han sido tomados como precedentes por la Corte Suprema Argentina.

Castigar más, comprender menos

por Luciana Ginga · Marco Gaiero

Entre la consolidación del sentido común y el descrédito de las Ciencias Sociales

27 de febrero de 2026

En contextos de gobiernos de extrema derecha, como el que fue electo en diciembre de 2023 en Argentina, la voracidad por castigar se vuelve explícita y desembozada. Aunque no siempre se logra, estos sectores políticos no cesan de intentarlo. En febrero de 2026 en Argentina se debatió la reforma del Régimen Penal Juvenil para bajar de la edad de punibilidad de niños/as y adolescentes a 14 años impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.

El Congreso de la Nación aprobó, días después, el proyecto de Reforma logrando los consensos y las alianzas con otros sectores políticos para el acompañamiento. De modo que, si bien dicha reforma fue impulsada por el gobierno nacional, vastos sectores políticos, sociales e institucionales han dado su apoyo explícito e implícito.

No obstante, diversas organizaciones sociales -como Amnistía Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)-, partidos políticos -como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda- o agentes intermedios de la sociedad civil -sectores de la Iglesia católica, tales como Cáritas Nacional y las Comisiones Episcopales de Pastoral Carcelaria y Social-, manifestaron públicamente estar en contra (y votar en clara oposición en el Congreso) de dicha reforma con argumentos sólidos y apelando a la experiencia histórica como fundamentos considerables para expresar su repudio. Sin embargo, aquella posición normativa punitivista y profundamente política muestra una notoria predisposición social que ha “elegido distribuir sanciones mucho más punitivas a

aquellos que se han definido como objetivos adecuados para el ‘reparto del dolor’” (Hallsworth, 2006, p.1).

El propósito de este escrito gira en torno a comprender el complejo panorama en el que se ha debatido la reforma del Régimen Penal Juvenil en Argentina. En este sentido, nos preguntamos, siguiendo a Lahire: “para qué sirve entender” (2016, p. 36) ¿Cuál es el sentido de complejizar el análisis colocando sobre la mesa una serie de variables que permitan ampliar la comprensión de un fenómeno? ¿Sobre qué evidencias, estudios o investigaciones se apoyan quienes han defendido la reforma de Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de punibilidad? ¿Es necesario acudir a fuentes estadísticas, a registros nacionales e internacionales, a consultas de especialistas que estudian el tema desde hace años? ¿Qué pueden aportar estas fuentes que no se sepa ya, o que los medios de comunicación o las redes sociales no hayan puesto de relieve?



No son tiempos favorables o sencillos para apostar a las Ciencias Sociales como motor y fuente que abreva de datos, estadísticas, documentación y análisis basados en evidencia para diagramar políticas públicas o diversas intervenciones que emerjan de los Estados. Hace unos años, las Ciencias Sociales vienen sufriendo - desde los centros mismos del poder- embates que pretenden deslegitimar sus producciones y resultados para, entre otras cosas, desfinanciarla tanto como desprestigiar los avances y descubrimientos que -en muchos casos- contradicen postulados o “verdades” que se sostienen desde el sentido común y que son impulsadas por los sectores más reaccionarios a nivel mundial.

Ahora bien, por qué es imperioso acudir a las Ciencias Sociales para entender. A propósito, Lahire plantea que “entender sirve para resolver los problemas de un modo que no implique la exclusión (encarcelamiento, apartamiento o confinamiento psiquiátrico) o la destrucción del otro (pena de muerte). Tomar distancia de la consideración generalizada permite tener en cuenta la totalidad de un problema cuando todos tienen la mirada puesta en los actos de los delinquentes o criminales y la “personalidad” de los actores de determinados actos. Sólo el distanciamiento y la desindividualización del problema permiten considerar soluciones definitivas y duraderas. Probablemente esta sea una de las lecciones políticas más importantes de las ciencias sociales” (2026, p. 36)

En este sentido, es pertinente abordar los causantes de dicha reforma, en relación con los tratamientos de las cuestiones en materia de justicia y seguridad en nuestro país, así como mencionar el rol que las Ciencias Sociales deben llevar a cabo en los tiempos actuales.

Punitivismo, reduccionismo y sensacionalismo: opinión y dramatismo mata al dato

Los casos de jóvenes que han cometido delitos graves son resonantes y revisten una importancia que no pretendemos soslayar. En Rosario en 2024, por ejemplo, un joven ingresó a una esta-

ción de servicio y asesinó a quemarropa a uno de los trabajadores -Bruno Bussanich- en el marco de una oleada de asesinatos que sucedieron en la ciudad (Maggi, 2024). También el asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata en febrero de 2025, donde dos jóvenes de 17 y 14 años roban el auto que conducía la madre de Kim, con ella en el asiento trasero ubicada con cinturón de seguridad. Como no pudieron despedir a la niña del auto porque quedó enganchada con el cinturón, la arrastraron más de un kilómetro y murió (La Nación, 2026).

A su vez, también es dable mencionar el conmocionante homicidio de Jeremías Monzón, un joven santafesino torturado y asesinado brutalmente por tres adolescentes (Balonga, 2025), que reactivó el tratamiento de la reforma del Régimen Penal Juvenil en la que se destaca, principalmente, la baja de la edad de imputabilidad -la cual, como ya se mencionó, cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso de la República Argentina (El País, 2026). Este proyecto, lejos de discutir las condicionantes que llevan a que un niño/a o joven sea capaz de realizar un hecho de semejante envergadura y con ello reflexionar en torno a la importancia de un esquema ex ante, se centra en una lógica de castigo que sólo responde a lo que “el sentido común” y la “emocionalidad” demanda ante una situación de tal magnitud.

Desde hace varios años -y con mayor incidencia luego de la pandemia-, la formulación e implementación de políticas públicas, particularmente en materia de justicia o seguridad, no es producto de diagnósticos rigurosos ni de esquemas de planificación de mediano o largo plazo. Por el contrario, las medidas ejecutadas son resultado de acciones reactivas ante hechos que suscitan una gran indignación en vastos sectores de la sociedad. En este sentido, el sensacionalismo, el dramatismo social y la necesidad que tiene la dirigencia política -en particular, pero no exclusivamente, la que forma parte del amplio espectro de las derechas- en demostrar de manera pírrica y dramática que se “encuen-

tra a la altura de las circunstancias” tiene como consecuencia el desarrollo de políticas sin ningún tipo de sustento empírico, con una perspectiva claramente punitivista y centrada en hechos individuales o en “casos aislados”, lo que supone un enorme riesgo por distintas razones.

En primer lugar, esta perspectiva de intervención tiende a la generalización y al establecimiento de patrones a partir de hechos dispersos en el tiempo y que no corresponden a lo que las estadísticas o a lo que las investigaciones, tanto académicas como divulgativas, reflejan. Esto, además, bajo el establecimiento de slogans o consignas que muestran cierta solidaridad/sensibilidad (muchas veces sobreactuada), que son eficaces para la discusión en redes sociales y en contextos de contiendas electorales, pero que carecen de sustento científico y que tienden a perpetuar prejuicios y estigmas, particularmente, sobre los sectores más vulnerables.

Como señala Claudia Cesaroni, una de las abogadas del fotoreportero Pablo Grillo a quien la Gendarmería hirió gravemente en el cráneo en unas de las manifestaciones contra el gobierno nacional: “no está en el debate público que porque un gendarme le voló la tapa de los sesos a un fotoperiodista que estaba haciendo su trabajo en una protesta, haya que terminar con toda una fuerza” (Canal abierto, Instagram, 12 de febrero 2026). Esta reflexión nos permite establecer que no es posible ni recomendable, cuando se trata de diagramar una política pública, una reforma o una ley (que impacta en la vida de las personas, en su presente y en su futuro) tomar un puñado de casos como el todo, aunque estos sean inadmisibles y generen un gran repudio social.

Al respecto de la situación de jóvenes y su participación en distintos delitos, la información producida en 2023 por la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina señala que en ese año, alrededor de 4 mil jóvenes estuvieron sujetos a medidas del sistema penal juvenil en todo el país, lo que representa no más que el 0,1% del universo total de adolescentes de entre 14 y 17

años (Kerz, 2026). Con respecto a la participación en delitos contra la propiedad, el Ministerio de Seguridad de la República Argentina (2025) señala, para el período 2018-2024, la participación de 55.925 menores de 15 años en estos ilícitos y 72.439 de entre 16 y 17 años que, en conjunto, representan casi el 8,76% del total de delitos contra la propiedad registrados. En cuanto a los homicidios dolosos, esta misma agencia menciona que en la cohorte 2017-2024 se cometieron 17.325 hechos en todo el territorio nacional, de los cuales el 0.68% involucró a personas menores a los 14 años (Ministerio de Seguridad de la República Argentina, 2025; La Vanguardia, 2026).

«El propósito de este escrito gira en torno a comprender el complejo panorama en el que se ha debatido la reforma del Régimen Penal Juvenil en Argentina.»

Esto permite mostrar que, aunque en nuestro país es imprescindible debatir el funcionamiento del sistema penal juvenil —incluyendo el estado de los establecimientos de detención, el desempeño de las áreas encargadas del abordaje de niños/as y adolescentes, las medidas de encierro aplicadas y el trato hacia las víctimas— una aproximación empírica mínima evidencia que los problemas de seguridad y justicia en la Argentina no se explican principalmente por la participación de jóvenes menores de edad. El dramatismo que generan ciertos hechos, en especial los homicidios cometidos por niños/as o adolescentes, no justifica —o no debería justificar— la adopción de respuestas reactivas con escaso o nulo énfasis en la prevención.

Por otro lado, si bien es difícil pensar políticas en la materia sin considerar el rol de las agencias policiales, penitenciarias y judiciales, la primacía de un enfoque tradicionalista (Binder, 2012)

o populista penal (Garland, 2005) suele dejar de lado los factores sociales, económicos, políticos, culturales y urbanísticos que posibilitan la comisión de ciertos delitos. La centralidad otorgada a lo policial y penal —dimensiones esenciales, pero no suficientes para una política de seguridad— no sólo produce una mirada parcial al abordar estas problemáticas, sino que también revela la intención de ciertos sectores de invisibilizar las asimetrías, relaciones de poder y desigualdades que, en gran medida, estructuran estos fenómenos. Como advierte Lahire (2016), un enfoque basado en el “libre albedrío” tiende a responsabilizar individualmente estos hechos y, en consecuencia, a ofrecer una lectura sesgada de fenómenos criminales cuyo desarrollo remite a cuestiones estructurales.

Por ejemplo, la criminalidad organizada —fenómeno que ha tomado una gran relevancia en la opinión pública argentina a partir de la situación de violencia en Rosario— involucra tanto a actores criminales violentos como a funcionarios estatales de distinta índole y a profesionales vinculados al mundo de las finanzas. Sin embargo, su tratamiento mediático y político se suele centrar casi siempre en los eslabones más visibles, rudimentarios y precarios de estos entramados (constituido muchas veces por jóvenes y pobres), lo cual desemboca en que se la conciba como una problemática limitada territorialmente y socialmente a los sectores populares, llegando a desconocer (muchas veces por ignorancia o desidia, pero también intencionalmente) que quienes constituyen la demanda de bienes y servicios producidos e intercambiados ilegalmente suelen pertenecer a los estratos medios y altos.

Esta situación lleva a que un fenómeno con altos niveles de rentabilidad, que afecta el funcionamiento de nuestras democracias y que posee un carácter sumamente desigual y heterogéneo en términos sociales, económicos y territoriales, sea abordado como un hecho homogéneo que tiende a perpetuar dos grandes “vicios” de los sistemas policiales, penitenciarios y penales, ya descritos por dos grandes académicos en

la materia (Sutherland, 1999; Garland, 2005): la tendencia a investigar, juzgar y condenar siempre a los mismos actores (selectividad penal) y la construcción de que los delitos son un problema de “otros” ajenos a cierta idea de civilización y generalmente pertenecientes a los sectores más vulnerables (criminología del otro).

Dicha concepción es observable en el comportamiento de gran parte de la dirigencia política argentina —en particular, pero no exclusivamente— de los sectores pertenecientes al espectro de la derecha, quienes no contemplan en sus iniciativas el uso de información fidedigna para la formulación de políticas. Esto se debe a que lo esencial en sus iniciativas no se encuentra en discutir los factores estructurantes que hacen al desarrollo de estos asuntos, sino satisfacer aquello que la opinión pública demanda al respecto.

En otras palabras, en lugar de hablar de gestión de los asuntos de seguridad pública o de justicia, se debe mencionar que dichas políticas parten de la “gestión de la emocionalidad” que estos hechos producen en distintos sectores de la sociedad y la necesidad de establecer “escenarios” favorables para la captación de votantes. Por lo tanto, los “diagnósticos” más que sustentarse en información cuantitativa o cualitativa que permita —con sus limitaciones— un conocimiento lo más certero posible a la realidad delictiva —en función de sus manifestaciones y heterogeneidades—, se basan en los resultados de diversos estudios de opinión pública, los cuáles carecen de los criterios teóricos y metodológicos aprobados para medir la denominada “sensación de inseguridad” (Kessler, 2009), y cuyo desarrollo tiene como disparador hechos con una alta carga emocional que no permiten —ni para aquellos/as que nos dedicamos a la investigación de estos asuntos— un abordaje certero y los más objetivo posible de estos asuntos.

Las ciencias sociales en crisis. La importancia (e incomodidad) de comprender y problematizar

En un contexto en donde el “sentido común” se impone ante toda información producida en base a principios técnicos y científicos, en particular en lo referido a las violencias y a la seguridad, las ciencias sociales se encuentran en el banquillo de los acusados. En este sentido, se las suele considerar explícitamente como “defensoras” de delincuentes, terroristas o incivilizados (parafraseando a Lahire, 2016) al intentar, mediante sus distintos métodos y técnicas explicar, con igual rigurosidad, por qué un joven proveniente de un barrio marginal termina convirtiéndose en delincuente o cuáles son los hechos que llevan a que una persona del mismo origen social pueda terminar siendo un agente policial que -probablemente- ejecute prácticas de tortura o que se vincule a grupos criminales.

Por lo tanto, su propósito no es el de justificar o condenar dichos actos, sino el de atender los factores -principalmente contextuales- que permiten comprender dicho comportamiento develando las asimetrías que explican por qué y cómo ciertos delitos son criminalizados y otros no o por qué algunos actores criminales suelen ser enjuiciados y condenados con altas penas de prisión, mientras que otros delincuentes, de un origen social opuesto, suelen no desfilar por los pasillos de los tribunales penales o, en el mejor de los casos, terminan siendo penados con multas económicas o estancias cortas de prisión.

En este sentido, las Ciencias Sociales, en su ambición de comprender, discuten -o deberían- con el poder al hacer aquello que más lo incomoda: visibilizarlo. Esto, con el riesgo de que su potencial capacidad de poner en cuestión aquello que se considera como una “verdad universal”, ocasione su demonización o su destrucción, mediante la reforma regresiva o desfinanciamiento de los organismos o agencias encargadas de su desarrollo.

Por lo tanto, realizar producciones en Ciencias Sociales, en tiempos como en el que vivimos, debe ser considerada una suerte de activismo cuya función no es justificar la opinión de quienes la ejercen o adecuarse a lo considerado “políticamente correcto” por los sectores más ilustrados, sino poner a consideración otras maneras de comprender los hechos que generan una enorme preocupación social. Para tal fin, se debe valer de los criterios y rigurosidad metodológica de cualquier ciencia y buscar que dichos resultados o discusiones no se limiten a los ámbitos tradicionales de la academia. Por el contrario, es pertinente encontrar el lenguaje o manera que mejor se ajuste para interpelar a toda la ciudadanía, independientemente de su origen social o grado de formación académica, con el horizonte de problematizar sobre lo considerado “natural” y de hacer visible las innumerables desigualdades subyacentes al momento de pensar y ejecutar políticas públicas, principalmente, en materia de justicia y de seguridad.

Referencias bibliográficas

- Balonga, M. L. (2025, diciembre 28). El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: más de 20 puñaladas, tres chicos implicados y videos del ataque. Infobae. <https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2025/12/28/el-crimen-de-jeremias-monzon-en-santa-fe-mas-de-20-punaladas-tres-chicos-implicados-y-videos-del-ataque/>
- Becker, H. (2005). ¿De qué lado estamos?. (2016). *Delito Y Sociedad*, 1(21), 89-100. <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DelitoYSociedad/es/article/view/5369>.
- Binder, A. (2012). El rompecabezas de la seguridad democrática. *Voces en el Fénix*, 3(15), 6-11.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2023). Niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores Informe estadístico 2023. <https://www.csjn.gov.ar/bgd/archivos/verDocumento?idDocumento=8595>

El País. (2026, 12 febrero). La Cámara de Diputados de Argentina baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para delitos penales. <https://elpais.com/argentina/2026-02-12/la-camara-de-diputados-de-argentina-baja-de-16-a-14-anos-la-edad-de-imputabilidad-para-delitos-penales.html>

Garland, D. (2005). La Cultura Del Control. Crimen y orden Social en la sociedad contemporánea. Gedisa Editorial.

Hallsworth, S. (2006). Repensando el giro punitivo. Delito y Sociedad, 1(22), 57-74. <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DelitoYSociedad/article/view/5344/8031>

Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina (2026, 12 de febrero) La cámara de diputados le dio media sanción al Nuevo Régimen Penal Juvenil. LA CÁMARA DE DIPUTADOS LE DIO MEDIA SANCIÓN AL NUEVO RÉGIMEN PENAL JUVENIL

Kerz, J. (2026, 18 de febrero). La reforma penal juvenil frente a la evidencia. Análisis Digital. <https://www.analisisdigital.com.ar/opinion/2026/02/18/la-reforma-penal-juvenil-frente-la-evidencia>

Kessler, G. (2009). El sentimiento de inseguridad: sociología del temor al delito. Siglo XXI Editores.

Lahire, B. (2016) En defensa de la sociología. Contra el mito de que los sociólogos son unos charlatanes, justifican a los delincuentes y distorsionan la realidad. Siglo XXI editores.

«Por el contrario, las medidas ejecutadas son resultado de acciones reactivas ante hechos que suscitan una gran indignación en vastos sectores de la sociedad.»

La Nación (2026, 18 de febrero) Cómo fue el asesinato de Kim Gómez, la niña que fue arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto. Diario La Nación. Cómo fue el asesinato de Kim Gómez, la niña que fue arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto - LA NACION

La Vanguardia. (2026, febrero 15). Baja de la edad de imputabilidad: radiografía de los delitos cometidos por menores en Argentina. Diario La Vanguardia. <https://www.diariolavanguardia.com/especiales/19414-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-radiografia-de-los-delitos-cometidos-por-menores-en-argentina/>

Maggi, J. (2024, 30 de marzo) Violencia en Rosario: detuvieron al joven sospechado de haber disparado contra el playero Bruno Bussanich. Diario Página 12. Violencia en Rosario: detuvieron al joven sospechado de haber disparado contra el playero Bruno Bussanich – Página|12

Ministerio de Seguridad de la República Argentina. (2025). Sistema de Alerta Temprana Sistema Nacional de Información Criminal Delitos contra la propiedad Años 2018-2024. https://cloud-snic.minseg.gob.ar/Informes/SAT/SAT%20PROP/Informe_SAT-Propiedad_2024.pdf

Ministerio de Seguridad de la República Argentina. (2025). Sistema de Alerta Temprana Sistema Nacional de Información Criminal Homicidios Dolosos Años 2017 - 2024 https://cloud-snic.minseg.gob.ar/Informes/SAT/SAT%20HD/Informe_Homicidios-Dolosos_2023.pdf.

Sutherland, E. (1999). El delito de cuello blanco. La Piqueta. ■



Eliminar al líder

por Catalina Pérez Correa

El ataque contra el Cartel Jalisco Nueva Generación desató el caos. Réditos políticos a ambos lados del río y víctimas al desamparo.

28 de febrero de 2026

La noche del domingo 22 de febrero, el gobierno de México informó que había realizado un operativo en contra del Cartel Jalisco Nueva Generación, actualmente la organización criminal más grande de México. En el operativo fue matado Nemesio Oseguera Cervantes —El Mencho— junto con otras dos personas. Para la noche, el gobierno comunicó que se habían registrado “252 bloqueos en 20 entidades” del país, con carros y autobuses incendiados. Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas registraron “eventos focalizados y bloqueos aislados”. Tan solo en el estado de Jalisco hubo 65 bloqueos en “carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas”, sin contar las que continuaron durante la noche y madrugada. Durante su conferencia matutina del lunes, la Presidenta Sheinbaum informó que, además de estos hechos, se documentaron en distintas partes del país, 27 ataques directos en contra de autoridades, que murieron 27 elementos de seguridad (25 de la Guardia Nacional) y 30 personas que el ejército identificó como “presuntos” delincuentes, y se detuvieron a 70 personas.

El operativo en contra del CJNG mostró que la organización tiene capacidad de movilizar a personal en más de la mitad del país, e inmovilizarlo. El mapa de carros, autobuses, comercios incendiados, de bloqueos en carreteras y balacearas, es un mapa de la crisis de gobernanza que vive el país, y de la debilidad del estado de dere-

cho. Es evidencia también de las redes de colusión que existen entre autoridades y criminales.

El arresto (o ejecución) de objetivos prioritarios no es algo nuevo en México, y sus consecuencias son bien conocidas. Estamos a pocos meses de cumplir 20 años de la declaración de la guerra en contra del narcotráfico que hizo el entonces presidente, Felipe Calderón en diciembre de 2006. Durante su gobierno, Calderón implementó dos estrategias principales en contra del crimen organizado: la detención de líderes de las principales organizaciones criminales y los despliegues militar. El saldo de esta decisión está bien documentado: se produjo más violencia homicida a corto, mediano y largo plazo; las organizaciones criminales se atomizaron, las organizaciones diversificaron sus negocios hacia otras economías ilícitas, aumentaron su capacidad de armamento —para poder competir entre sí y con el Estado—; disminuyeron las capacidades de instituciones de seguridad civiles; y hubo un empuje hacia un estado más punitivo, más militarizado y con más reglas de excepción procesales (o dicho de otra forma, menos control sobre el actuar de la autoridad y menos derechos y garantías para la ciudadanía).

El caso reciente de Sinaloa sirve como ejemplo para entender el efecto que tiene específicamente la detención de objetivos prioritarios. Hace más de un año se detuvo a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del cartel de Sinaloa. A 10 meses de su detención se habían registrado 723 homicidios dolosos en el estado, 1,400 personas desaparecidas y 44 policías asesinados. Hoy la prensa reporta un éxodo de trabajadores agrícolas, quienes abandonan el campo por miedo,

escuelas y negocios cerradas, balaceras, “levantones”, y cuerpos mutilados y abandonados en los caminos y carreteras como parte de la cotidianidad. Hoy Sinaloa vive niveles de violencia inaceptables.

Al igual que el arresto de “El Mayo” Zambada, el arresto de “El Chapo” Guzmán, la “eliminación” de Arturo Beltrán Leyva hace 17 años, la muerte de “El Mencho” a manos del Estado mexicano, aumentará la violencia porque los mercados ilícitos que sus organizaciones controlan y las redes criminales que posibilitan que estas economías ilegales existan, quedan intactas. Actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) **participa en** minería ilegal; tráfico y venta de armas; robo y venta de combustible; producción, transporte y comercio de sustancias ilícitas; extorsión de negocios, agricultores y ganaderos; tráfico de migrantes; secuestro y desaparición de personas; tala clandestina; negocios inmobiliarios, plantación de aguacates, y más. Entre su nómina tiene a autoridades de todos los niveles. Tiene presencia en varios países y organizado en distintas empresas criminales. La muerte de su líder, puede cambiar las estructuras internas de la organización, pero no va disminuir las conductas criminales si el Estado no toma control de las economías y negocios ilegales. Eso pasa, por investigar y dismantelar las estructuras criminales (en las que participan autoridades) que posibilitan que estos existan.

Nadie, pienso, critica que sea detenido un delincuente, líder o no de una organización criminal y llamado a cuentas para dar cuenta y responder por los delitos que haya cometido. Miles

de familias, sobre todo mujeres, buscan a sus hijos, hijas, parejas, desaparecidos por miembros de CJNG. Algunas investigaciones han mostrado cómo el Cartel participa en reclutamiento forzado de jóvenes, especialmente adolescentes de entre 15 y 19 años. El descubrimiento el año pasado del Rancho Izaguirre usado para este fin y como centro de exterminio, estremeció al país. Las imágenes de pilas de zapatos, mochilas y ropa dan cuenta de los crímenes terribles en los que han participado miembros del Cártel. Miles de familias han perdido sus casas y negocios. Defensores de la tierra han sido asesinados por miembros del Cártel. Detener esa violencia, acompañar y reparar a las víctimas, obtener información sobre los desaparecidos, debiera ser prioridad del estado.

¿Tiene el Estado mexicano capacidad para tomar control de los mercados ilícitos, detener el ingreso de armas, la extorsión, la minería ilegal o el huachicol? ¿Habrá investigaciones sobre autoridades coludidas con esta organización? ¿Cómo se va a evitar que no se replique el desastre de Sinaloa o que el CJNG no se atomice en muchas organizaciones? Cada economía ilícita requiere una respuesta (estrategia) distintas. No es lo mismo atender el problema de las armas ilegales que del huachicol o el del fentanilo. Lo cierto es que despliegue de más militares y la detención de nuevos líderes, no los resuelve. Se trata de una estrategia que quizás reedita políticamente en ambos lados de la frontera pero trae consigo peores resultados en materia de seguridad y deja a las víctimas en el desamparo. ■



«El caso reciente de Sinaloa sirve como ejemplo para entender el efecto que tiene específicamente la detención de objetivos prioritarios.»

Puntos de vista

por Ramiro Álvarez Ugarte

La increíble vida—interna y externa—del filósofo del derecho más influyente del siglo veinte.

6 de febrero de 2026

Terminé hace algunas noches la extraordinaria biografía de H.L.A. Hart, el filósofo del derecho británico que a mediados del siglo XX revitalizó a la disciplina desde su puesto de profesor en Oxford, generó cientos de discípulos y críticos (en casi igual medida) y cambió, para siempre, la forma en que entendemos lo que el derecho es.

El libro es notable por varias razones. Por un lado, porque está en gran parte basado en libretas de anotaciones personales que Hart mantuvo con cierta regularidad a lo largo de su vida, lo que le da—a la autora—una ventana insólita a una vida. Los sentimientos personales más detallados y profundos se ponen por escrito, las formas de pensar los problemas filosóficos, las dudas, las sensaciones de no pertenecer a los círculos sociales en los que se movía, y la sensación de ser un fraude saltan de notas tomadas con fines de análisis personal y reflexión a un libro publicado, sin demasiada justificación más que el acuerdo y la colaboración de Jennifer, la esposa de Hart, figura central en su vida. Nicola Lacey, la autora del libro, lleva adelante la tarea y la responsabilidad implícita en ese acceso privilegiado con precisión y elegancia.

Lacey no es autora de biografías, sino que es profesora de derecho en la London School of Economics, de pasado *oxiense*, de vínculo con Hart en los últimos años de su vida. Y este es un dato clave para leer la biografía, que puede abordarse

en distintas claves de lectura, de las que yo voy a destacar tres.

Primero, la biografía de alguien como H.L.A. Hart puede leerse en clave de élite británica moderna, de los patrones de acceso a instituciones y procesos históricamente cerrados y excluyentes que—sin embargo—podían abrirse ante el talento y ciertas cualidades que Hart indudablemente tenía. Su vida se cruza y se mezcla con múltiples colegas y amigos, y la biografía es generosa en ofrecernos pinceladas de talentos parecidos a los de Hart, posiblemente distintos, pero también hechos de sentimientos y emociones que se dejan ver a través de relatos y notas en diarios personales y cartas —las cientos de cartas. Bajo esta luz, el libro es un relato de los dilemas y los deseos del hijo de un sastre judío que logró ingresar a esos círculos sin alcanzar a sentirse plenamente parte de ellos. A pesar de haber tenido una exitosa carrera como abogado en Londres, de haber servido a su país en el MI5 durante la Segunda Guerra Mundial, y de haber ingresado *tarde* a la vida académica plena del derecho *desde* la filosofía, las dudas y sentimientos de no adecuación parecen haberlo acompañado durante gran parte de su vida. Su alianza con Jennifer—nacida en una familia ya insertada en la élite inglesa—es una parte notable de esta vida, un vínculo que se sugiere complejo, intenso, ambiguo, pero central en la vida de Herbert.

Una segunda clave de lectura se podría vincular, más directamente, con la vida académi-

ca. Allí el libro ofrece una mirada a un tipo de universidad que aquí no tenemos: inmersivo, intenso, cercano, comunitario y durante la vida de Hart casi exclusivamente masculino. Oxford emerge como un club de varones, muchos de ellos bastante inadaptados, que viven donde estudian y trabajan. El famoso sistema de tutorías personalizadas aparece superpuesto con la vida personal, que cuesta distinguir del trabajo. Las discusiones o reuniones académicas ocurren después de las cenas, los grupos de trabajo se reúnen sábados o domingos, las charlas son en los cuartos de los profesores e investigadores y pueden durar horas o hasta la madrugada. Para quienes aman las universidades y las bibliotecas y han tenido la oportunidad de conocer distintas instituciones (pero no la de Oxford, como yo), el modelo *oxiense* aparece especialmente peculiar y extraño. El capítulo dedicado a los viajes de Hart por Estados Unidos a mediados de la década del cincuenta es especialmente iluminador para resaltar un contraste entre dos modelos distintos de universidad. (Dos modelos, por cierto, atractivos y alejados de nuestra propia realidad de enseñanza *part time* del derecho, de profesores que van y vienen pero nunca *se quedan*).

Finalmente, el libro es ideal para acercarse a Hart *por primera vez*, y—creo—podría servir de base para un curso de filosofía del derecho. Aquí la pluma de Lacey se vuelve central, porque la

vida intelectual de Hart se interpreta de manera hábil, se enmarca en discusiones y tradiciones más largas — Bentham, la filosofía analítica del siglo XIX, Wittengstein y su influencia en Inglaterra, JL Austin y el *giro lingüístico* del que Hart fue protagonista. Su viaje a Estados Unidos cruza a Hart con el realismo jurídico (la *pesadilla*) y con la escuela del proceso de Hart y Sacks, con Lon Fuller y así los debates entre positivismo y *iusnaturalismo* de esos años emergen anotados por las cartas personales que unos se enviaban a otros. La aparición de Ronald Dworkin y su *sueño noble*—pero, en última instancia, fallido para Herbert—toma un rol central en los últimos capítulos. Hart impulsó a que Dworkin sea su sucesor, a pesar de que éste se presentó como uno de sus principales críticos. Y si bien tuvieron un período de cercanía, ese vínculo no pudo cristalizarse en una amistad como las muchas que Herbert tendió a lo largo de su vida. Su necesidad de *responder a los críticos* se vuelve una carga pesada en la edad madura, y Lacey sugiere que el famoso *postscript* editado en 1994 por Joseph Raz y Penelope Bulloch no refleja al mejor Herbert sobre la base de un manuscrito inconcluso, que en años previos—antes de sufrir una dura depresión—había bosquejado de manera más precisa y eficiente, en presentaciones públicas y clases, una respuesta más articulada y asertiva. ■

«Por un lado, porque está en gran parte basado en libretas de anotaciones personales que Hart mantuvo con cierta regularidad a lo largo de su vida, lo que le da—a la autora—una ventana insólita a una vida.»



La Crítica del Derecho

Año 2, Vol. 2 — febrero de 2026

En este número: Abel Gilbert, Adriana Soria, Antonia Fratini Lagos, Catalina Pérez Correa, Clyde W. Barrow, Emiliano Vitaliani, Fernando Gauna Alsina, Gustavo Arballo, Gustavo Maurino, Heber Joel Campos Bernal, Irwin Stotzky, Luciana Ginga, Marco Gaiero, Mariela Puga, Mario Ackerman, María Valeria Berros, Máximo Lanusse Noguera, Natalia Sobrevilla Perea, Pablo Alabarces, Ramiro Álvarez Ugarte, Roberto Gargarella, Sebastián Guidi, Tomás Fernández Fiks, Valeria Vegh Weis.

WWW.LACRITICA.AR